الكافي في فقه الإمام أحمد

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٣

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، المكتب الاسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

1 كتاب النكاح 1

النكاح مشروع أمر الله به ورسوله فقال تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ وقال سبحانه ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء وقال عليه السلام إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال سعد بن أبي وقاص لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا متفق عليها والتبتل ترك النكاح وقد روي عن أحمد أن النكاح واجب اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوص فظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور فيلزمه النكاح لأنه يجب عليه اجتناب المحظور وطريقة النكاح ولا يجب على غيره لقوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة لظاهر الأخبار فإن أقل أحوالها الندب إلى النكاح

والكراهة لتركه إلا أن يكون ممن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان أحدهما النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار والثاني تركه أفضل لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها

فصل

ولا يصح إلا من جائز التصرف لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولأنه ينقص قيمته ويوجب المهر والنفقة وفيه ضرر على سيده فلم يجز بغير إذنه كبيعه وعنه أنه يصح ويقف على إجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي ويجوز نكاحه بإذن مولاه لدلالة الحديث ولأن المنع لحقه فزال بإذنه

فصل

ومن أراد نكاح امرأة فله النظر إليها لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أبو داود وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة وفي النظر إلى ما يظهر عادة من الكفين [ج ٣ - ص ٤]

والقدمين ونحوهما روايتان إحداهما يباح لأنه يظهر عادة أشبه الوجه والثانية لا يباح لأنه عورة أشبه مالا يظهر ولا يجوز النظر إلى مالا يظهر عادة لأنه عورة ولا حاجة إلى نظره ويجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النظر فلا يجوز تقييده وفي حديث جابر قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها وليس له الخلوة بها لان الخبر إنما ورد بالنظر فبقيت الخلوة على أصل التحريم ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتها للحاجة إلى معرفتها ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملها لحاجته إلى معرفتها للمطالبة بحقوق العقد ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتها للتحمل والأداء ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدنها حتى الفرج لأنه موضع ضرورة فأشبه الحاجة إلى الختان

فصل

وله أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرأس والرقبة والكفين والقدمين لقوله تعالى ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ﴾ وقال تعالى ﴿ لا جناح عليهن في آبائهن ﴾ وذات المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأم الزوجة وابنتها فأما أم المزني بها

والموطوءة بشبهة وبنتها فلا يباح النظر إليها لأنها حرمت بسبب

[ج ٣ - ص ٥]

غير مباح فلا تلحق بذوات الأنساب وأما عبد المرأة فليس بمحرم لها لأنها لا تحرم عليه على التأبيد لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى ﴿ ما ملكت أيمانهن ﴾ وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه رواه الترمذي وقال حديث صحيح وفيه دلالة على أنها لا تحتجب منه قبل ذلك ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لحاجتها لخدمته فأشبه ذا المحرم

فصل

ومن لا تمييز له من الأطفال لا يجب التستر منه في شيء لقوله تعالى ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ وفي المميز روايتان إحداهما هو كالبالغ لهذه الآية والثانية هو كذي المحرم لقوله تعالى ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ﴾ ثم قال ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ ففرق بينه وبين البالغ وحكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل مع النساء والتي صلحت للنكاح كالمميز من الأطفال لما روى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في [ج ٣ - ص ٦]

ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه

فصل

والعجوز التي لا يشتهى مثلها يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى ﴿ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ﴾ قال ابن عباس استثناهن الله تعالى من قوله ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في حقها فأشبهت ذوات المحارم وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو مرض أو تخنيث فحكمه حكم ذي المحرم في النظر لقوله تعالى ﴿ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ﴾ أي الذي لا إرب له في النساء كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها دخل على أزواج رسول الله مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا رواه أبو داود فأجاز دخوله عليهن حين عده من غير أولي الإربة فلما علم ذلك منه حجبه [ج ٣ - ص ٧]

فصل

ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه وكذلك السيد مع أمته المباحة له لأنه أبيح له الاستمتاع به فأبيح له النظر إليه كالوجه وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منا وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك رواه النسائي ويكره النظر إلى الفرج فإن زوج أمته حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة رواه أبو داود

فصل

فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة لأن تخصيص العورة بالنهي دليل على إباحة النظر إلى غيرها ويكره النظر إلى الغلام الجميل لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليه والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما أن المسلم مع الكافر كالمسلمين وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى ﴿ أو نسائهن ﴾ فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك [ج ٣ - ص ٨]

فصل

وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان إحداهما يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه لما روت أم سلمة قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن منه فقلت يا رسول الله ضرير ولا يبصر قال أفعمياوان أنتما ألا تبصرانه أخرجه أبو داود والنسائي وقال النسائي حديث صحيح والثانية يجوز لها النظر منه إلى ما ليس بعورة لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليهما وهذا أصح وحديث أم سلمة يحتمل أنه خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فان قدر عمومه فهذه الأحاديث أصح منه فتقديمها أولى وكل من أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ لأنه داعية إلى الفتنة [ج ٣ - ص ٩]

وهي خمسة أحدها الولي فإن عقدته المرأة لنفسها أو لغيرها بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح لماروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أحمد ويحيى هذا حديث صحيح وقد روى عن أحمد أن للمرأة تزويج معتقها فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أبو داود والترمذي فمفهومه صحته بإذنه ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه كنكاح العبد والأول المذهب لعموم الخبر الأول ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال بخلاف العبد فإن المنع لحق المولى خاصة وإنما ذكر تزويجها بغير إذن وليها لأنه الغالب إذ لو رضي لكان هو المباشر له دونها

فصل

فإن تزوج بغير إذن ولي فالنكاح فاسد لا يحل الوطء فيه وعليه

فراقها فإن وطىء فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمد لأنه وطء مختلف في حله فلم يجب به حد كوطء التي تزوجها في عدة أختها وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه أشبه ما لو تزوج ذات زوج وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان أحدهما لا يجوز نقضه لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار والثاني ينقض لأنه خالف النص

فصل

فإن كانت أمة فوليها سيدها لأنه عقد على نفعها فكان إلى سيدها كإجارتها فإن كان لها سيدان لم يجز تزويجها إلا بإذنهما وإن كانت سيدتها امرأة فوليها ولي سيدتها يزوجها بإذن سيدتها لأنه تصرف فيها فلم يجز بغير إذنه كبيعها وعنه رواية أخرى أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لأن سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة فكان لها التوكيل كالولي الغائب ونقل عنه أنه قيل له هل تزوج المرأة أمتها قال قد قيل ذلك هي مالها وهذا يحتمل رواية ثالثة فإن كانت سيدتها غير رشيدة أو كانت لغلام أو لمجنون فوليها من يلي ما لهم لأنه تصرف في بضعها أشبه إجارتها [ج ٣ - ص ١١]

فصل

وإن كانت حرة فأولى الناس بها أبوها لأنه أشفق عصباتها ويلي مالها عند عدم رشدها ثم الجد أبو الأب وان علا لأنه أب وعنه الابن يقدم على الجد لأنه أقوى تعصيبا منه وعنه أن الأخ يقدم على الجد لأنه يدلي ببنوة الأب والبنوة أقوى وعنه أن الجد والأخ سواء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب والمذهب الأول لأن للجد إيلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالأب ولأنه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما ثم ابنها ثم ابنه وان نزل لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحها كابنها وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأب ثم لأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث لأن الولاية لدفع العار عن النسب والنسب في العصبات وقدم الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديمه في الإرث ولأنه أشفق فقدم كالأب فإذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق ثم عصابته الأقرب فالأقرب ثم مولى المولى ثم عصباته لأن الولاء كالنسب في التعصيب فكان مثله في التزويج ويقدم ابن المولى على ابنه لأنه أقوى تعصيبا وإنما قدم الأب المناسب لزيادة شفقته وتحكم الأصل على فرعه وهذا معدوم في أبي المولى فرجع فيه إلى الأصل وإذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها لأنه لما لم [ج ٣ - ص ١٢]

يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة وعنه أنها تولي رجلا في تزويجها لما ذكرنا في أمتها ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

فصل

فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما من أبوين والآخر من أب كالأخوين والعمين ففيه روايتان إحداهما يقدم ذو الأبوين اختاره أبو بكر لأنه حق يستفاد بالتعصيب فأشبه الميراث بالولاء والثانية هما سواء اختارها الخرقي لأن الولاية بقرابة الأب وهما سواء فيها فإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فذكر القاضي أنهما كذلك والصحيح أن الإخوة لا تؤثر في التقديم لاستوائهما في التعصيب والإرث به بخلاف التي قبلها من كل وجه فإن استويا من كل وجه فالولاية ثابتة لكل واحد منهما أيهما زوج صح تزويجه لأن السبب متحقق في كل واحد لكن يستحب تقديم أسنهما وأعلمهما وأتقاهما لأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما لأنهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهما كالمرأتين في السفر فإن قرع أحدهما فزوج الآخر صح لأن القرعة لم تبطل ولايته فلم يبطل نكاحه وذكر أبو الخطاب فيه وجها آخر أنه لا يصح

فصل

فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة فهما باطلان لأن الجمع يتعذر فبطلا كالعقد على أختين ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما وإن سبق أحدهما فالصحيح السابق لما روى سمرة وعقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أبو داود ولأن الأول خلا عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فعليه مهرها لأنه وطء بشبهة وترد إلى الأول لأنها زوجته ولا يحل له وطؤها حتى تقضي عدتها من وطء الثاني فإن جهل الأول منهما ففيه روايتان إحداهما يفسخ النكاحان لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح ولا سبيل إلى الجمع ولا إلى معرفة الزوج فيفسخ لإزالة الزوجية ثم لها أن تتزوج من شاءت منهما أو من غيرهما والثانية يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه فإن كانت زوجته لم يضره ذلك وإن لم تكن صارت زوجته بالتجديد وكلا الطريقين لا بأس به وسواء علم السابق ثم نسي أو جهل الحال لأن المعنى في الجميع واحد وإن أقرت المرأة لاحدهما بالسبق لم يقبل إقرارها لأن الخصم غيرها فلم يقبل قولها عليه كما لو أقرت ذات زوج لآخر أنه زوجها وإن ادعى عليها العلم [ج ٣ - ص ١٤]

بالسابق لم يلزمها يمين لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره

فصل

ويشترط للولي ثمانية شروط أحدها العقل فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون والثاني الحرية فلا ولاية لعبد الثالث الذكورية فلا ولاية لامرأة لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى الرابع البلوغ فلا يلي الصبي بحال وعنه أن الصبي المميز إذا بلغ عشرا صح تزويجه لأنه يصح بيعه والأول أولى لأنه مولى عليه فلا يلي كالمرأة الخامس اتفاق الدين فلا يلي كافر مسلمة بحال لقوله تعالى ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ إلا أم ولد الذمي المسلمة ففيها وجهان أحدهما يملك تزويجها لأنه يملكها فأشبه المسلم إذا كان سيد كافرة والثاني لا يليه للآية ويليه الحاكم ولا يلي مسلم كافرة لقوله تعالى ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ولأن ولايته عامة عليهم وسيد الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلما لأنه عقد عليها فوليه كبيعها وولي سيد الكافرة أو سيدتها يزوجها لأنه يقوم مقامهما ويلي الكفار أهل دينهم للآية التي تلوناها وهل تعتبر عدالتهم في دينهم على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين [ج ٣ - ص ١٥]

السادس العدالة فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى الروايتين لأنها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال والثانية يلي لأنه قريب ناظر فكان وليا كالعدل ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر بل يكفي كونه مستور الحال ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة

السابع التعصيب أو ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم كالأخ من الأم والخال وسائر من عدا العصبات لأن الولاية تثبت لحفظ النسب فيعتبر فيها المناسب ولا تثبت الولاية للرجل علي المرأة التي تسلم على يديه وعنه أنها تثبت ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء

الثامن عدم من هو أولى منه فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب فإن مات الأقرب أو جن أو فسق انتقلت إلى من بعده لأن ولايته بطلت فانتقلت إلى الأبعد كما لو مات فإن عقل المجنون وعدل الفاسق عادت ولايته لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح ولاية زوجها بعد زوال ولايته ويحتمل أن تصح بناء على الوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء فعضلها فللأبعد تزويجها نص عليه وعنه لا يزوجها إلا السلطان وهو اختيار أبي بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن [ج ٣ - ص ١٦]

اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولأن التزويج حق عليه امتنع منه فقام الحاكم مقامه في إيفائه كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه واختار الخرقي الرواية الأولى لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد كما لو فسق والحديث دليل على أن السلطان لا يزوج هاهنا لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها فللأبعد تزويجها لما ذكرنا والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد واختيار أبي بكر وذكر الخرقي أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه أو يصل فلا يجيب عنه لأن غير هذا يمكن مراجعته وقال القاضي حدها مالا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة لأن الكفء ينتظر عاما ولا ينتظر أكثر منه وقال أبو الخطاب يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة لأن أحمد قال إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر والأولى المنصوص والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع فأما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لأنه في حكم الحاضر إلا أن تتعذر مراجعته لأسر أو حبس لا يوصل إليه ونحوهما فيكون كالبعيد لكونه في معناه ولا يشترط في الولاية البصر لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى لموسى عليه السلام ولأن الأعمى من أهل الرواية [ج ٣ - ص ١٧]

والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير فأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية وإن لم يمنعها لم يزل الولاية لأن الأخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق

فصل

وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع أو زوج أجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل في أصح الروايتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر وفي لفظ فنكاحه باطل ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة والثانية هو موقوف على إجازة من له الإذن فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع ولما روى ابن ماجه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود وقال هذا حديث مرسل رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا ابن عباس فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول ويكفي في إذن المرأة النطق أو ما يدل على الرضى من التمكين من الوطء والمطالبة بالمهر والنفقة بكرا كانت أو ثيبا لأن أدلة

الرضى تقوم مقام النطق به بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة

[ج ٣ - ص ١٨]

إن وطئك زوجك فلا خيار لك فأما إن زوجت المرأة نفسها أو زوجها طفل أو مجنون أو فاسق فهو باطل لا يقف على الإجازة لأنه تصرف صادر من غير أهله وذكر أصحابنا تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلف في وقوفها والأولى أنها ليست منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولأنه تصرف لو قارنه الإذن لم يصح فلم يصح بالإذن اللاحق كتصرف المجنون

فصل

ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان الموكل أو غائبا ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل وخرج القاضي ذلك على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل وليس كذلك فإن الولي ليس بوكيل للمرأة ولا تثبت ولايته من جهتها فلم يقف جواز توكيله على إذنها كالسلطان ولأنه ولي في النكاح فملك الإذن فيه من غير إذنها كالسلطان ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقا كإذن المرأة ويجوز التوكيل في تزويج معين واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية على روايتين ذكرناهما في الوصايا ولا يصير وصيا في النكاح بالوصيه إليه في المال لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى كالأخرى [ج ٣ - ص ١٩]

فصل

وإذا لم يكن للمرأة ولي ولا للبلد قاض ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ويزوجها فإنه قال في دهقان قرية يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض إذا احتاط لها في الكفء والمهر ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية فوجب أن لا يشترط وعنه لا يصح إلا بولي لعموم الخبر فيه

فصل

وإذا أراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها أو مولاها جعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام فإن زوج نفسه بإذنها ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لحديث المغيرة ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجز أن يتولى طرفيه كالوكيل في البيع والثانية يجوز لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لامته وإن قال السيد قد أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال قد جعلت عتق

أمتي صداقها ففيه روايتان إحداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها لما روي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وفي رواية أصدقها نفسها والثانية لا يصح حتى يبتدىء العقد عليها بإذنها لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها لأنه إنما أعتقها بعوض لم يسلم له ولم يمكن إبطال العتق فرجعنا إلى القيمة ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا إلا السيد يزوج عبده من أمته فإن كان وكيلا للزوج والولي أو وكيلا للزوج وليا للمرأة أو وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيع

فصل

الشرط الثاني من شرائط النكاح أن يحضره شاهدان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الخلال وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان رواه الدارقطني وعن أحمد أن الشهادة ليست شرطا فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود ولأنه عقد معاوضة فلم تشترط الشهادة فيه كالبيع [ج ٣ - ص ٢١]

فصل

ويشترط في الشهود سبع صفات أحدها العقل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة والثاني السمع لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به والثالث النطق لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة

الرابع البلوغ لأن الصبي لا شهادة له وعنه أنه ينعقد بحضور مراهقين بناء على أنهما من أهل الشهادة والأول أصح

الخامس الإسلام ويتخرج أن ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض والأول المذهب لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

والسادس العدالة للخبر وعنه ينعقد بحضور فاسقين لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات والأول أولى للخبر ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي إلا أننا لا نعتبر العدالة باطنا ويكفي أن يكون مستور الحال وكذلك العدالة المشروطة في الولي لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق

السابع الذكورية وعنه ينعقد بشهادة رجل وامرأتين لأنه عقد معاوضة أشبه البيع والأول المذهب لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهل يشترط عدم العداوة والولادة وهو أن [ج ٣ - ص ٢٢]

لا يكون الشاهدان عدوين للزوجين أو لأحدهما ولا ابنين لهما أو لأحدهما على وجهين ولا تشترط الحرية ولا البصر لأنها شهادة لا توجب حدا فقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه بالاستفاضة ويعتبر أن يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما وهل يشترط كون الشاهد من غير أهل الصنائع الزرية كالحجام ونحوه على وجهين بناء على قبول شهادتهم

فصل

الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين لأن المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب تعيينهما فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه صح لأن الإشارة تكفي في التعيين فإن زاد على ذلك فقال ابنتي أو فاطمة كان تأكيدا وإن سماها بغير اسمها صح لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة فأشبه ما لو قال زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة وان كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة وإن سماها باسمها أو وصفها بصفتها كان تأكيدا وإن سماها بغير اسمها صح أيضا لأن الاسم لا حكم له مع التعيين فلا يؤثر الغلط فيه وإن كان له ابنتان فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما تتميز به لأن التعيين لا يحصل بدونه فإن قال ابنتي فاطمة [ج ٣ - ص ٢٣]

أو ابنتي الكبرى صح لأنها تعينت به وإن نويا ذلك من غير لفظ لم يصح لأن الشهادة في النكاح شرط ولا يقع إلا على اللفظ ولا تعيين فيه وإن خطب الرجل امرأة فزوج غيرها لم ينعقد النكاح لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإيجاب فلم يصح كما لو قال قد زوجتك ابنتي فاطمة فقال قبلت تزويج عائشة فإن كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنتي عائشة فقبله الزوج ينويان الصغرى ولم يصح لأنهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه ولم يذكر المنوية بما تتميز به وإن نوى أحدهما الكبرى والآخر الصغرى لم يصح لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه الإيجاب وإن قال زوجتك حمل امرأتي لم يصح لأنه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة ولا يتحقق كونها بنتا وإن قال إن ولدت زوجتي بنتا زوجتكها كان وعدا لا عقدا لأن النكاح لا يتعلق على الشروط

فصل

الشرط الرابع التراضي من الزوجين أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع فإن كان الزوج بالغا عاقلا لم يجز بغير رضاه وإن كان عبدا لم يملك السيد إجباره عليه لأنه خالص حقه وهو من أهل مباشرته فلم يجبر عليه كالطلاق وإن كان العبد صغيرا فلسيده تزويجه لأنه

إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده أولى قال أبو الخطاب ويحتمل أن

[ج ٣ - ص ٢٤]

لا يملكه أيضا قياسا على الكبير ويملك الأب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ لما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة وسواء كان عاقلا أو معتوها لانه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى ويملك الأب أيضا تزويج ابنه البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخرقي لأنه غير مكلف فأشبه الصغير وقال القاضي لا يجوز تزويجه إلا إذا ظهر منه أمارات الشهوة باتباع النساء ونحوه فقال أبو بكر لا يجوز تزويجه بحال لنه رجل فلم يجز تزويجه بغير إذنه كالعاقل والأول أولى لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إلى قضاء شهوته وحفظه عن الزنى فالبالغ أولى ولا يجوز تزويجه إلا إذا رأى وليه المصلحة في تزويجه لاحتياجه إلى الحفظ والإيواء أو قضاء الشهوة ونحو ذلك فأما من له إفاقة في بعض أحيانه فلا يجوز إجباره على النكاح لأنه يمكن استئذانه ووصي الأب كالأب في تزويج الصغير والمعتوه لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل ولا يملك غير الأب ووصية تزويج صغير ولا معتوه لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى وقال ابن حامد للحاكم تزويج المعتوه الذي يشتهي النساء لأنه يلي ماله فملك تزويجه كالوصي وقال القاضي له تزويج الصغير الذي يشتهي كذلك ولا يجوز إلا إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه ناظر له في مصالحه وهذا منها فأشبه عقده على ماله [ج ٣ - ص ٢٥]

فصل

فأما المرأة فإن السيد يملك تزويج أمته بكرا كانت أو ثيبا بغير رضاها لأنه عقد على منافعها فملكه كإجارتها وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست متفق عليه ولم يستأذنها وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولي مع الثيب أمر رواهما أبو داود وفي البكر البالغة روايتان إحداهما له إجبارها لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر والثانية لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وأما الثيب الصغيرة ففيها وجهان أحدهما لا يجوز تزويجها لعموم الأحاديث فيها والأخرى يجوز تزويجها لأنها ولد صغير فملك الأب تزويجها كالغلام والثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو حراما لأنه لو أوصى للثيب بوصية دخل فيها من ذكرناه ولا تدخل في

وصيته الأبكار ووصي الأب إذا نص له على التزويج كالأب لأنه قائم مقامه

فصل

فأما غيرهما فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها جدا كان أو غيره لعموم الأحاديث ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم وفي الصغيرة ثلاث روايات إحداهن ليس لهم تزويجها لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها والصغيرة لا إذن لها والثانية لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت لقوله تعالى ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ دلت بمفهومها على أن له تزوجها إذا أقسط لها وقد فسرته عائشة بذلك والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسعا بإذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو داود وجمعنا بين الأدلة والأخبار وقيدنا ذلك بابنة تسع لأن عائشة قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات أو الكلام في حق الأب وغيره لما تقدم من الحديث وهو [ج ٣ - ص ٢٧]

صريح في الحكم وروى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها رواه الأثرم وابن ماجه ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعا

فصل

الشرط الخامس الإيجاب والقبول ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ النكاح أو التزويج فيقول زوجتك ابنتي أو أنكحتكها لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح عن الشهادة

وأما القبول فيقول قبلت هذا النكاح وإن اقتصر على قبلت صح لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع وإن قيل للولي أزوجت قال نعم وقيل للمتزوج أقبلت قال نعم أنعقد النكاح لأن نعم جواب للسؤال والسؤال مضمر معاد فيه ولهذا لو قيل له أسرقت قال نعم كان مقرا بالسرقة حتى يلزمه القطع الذي يندرىء بالشبهات فهاهنا أولى ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن يحسنها لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهما فلم يصح لما ذكرنا ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي [ج ٣ - ص ٢٨]

فأشبه ما لو أتى به وليس عليه تعلمهما بالعربية لأن النكاح غير واجب فلا يلزم تعلم أركانه كالبيع ولأن المقصود المعنى دون اللفظ المعجوز وهو حاصل بخلاف القراءة وقال أبو الخطاب يلزمه التعلم لأن ما كانت العربية شرطا فيه عند الإمكان لزمه تعلمه كالتكبير وإذا فهمت إشارة الأخرس صح النكاح بها لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبيعه وإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح لأن القبول إنما هو بالإيجاب فيشترط تأخره عنه وإن تراخي القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه فإن تفرقا قبله أو تشاغلا بغيره قبل القبول بطل الإيجاب لأنهما أعرضا عنه بتفرقهما أو تشاعلهما فبطل كما لو طال التراخي ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا زوج فلانا على ألف فقال قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقبل هل يكون هذا نكاحا قال نعم فجعل أبو بكر هذا رواية ثانية وقال القاضي هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون أو إغماء أو موت قبل القبول بطل لأنه لم ينعقد فبطل بهذه المعاني كايجاب البيع ومتى عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح [ج ٣ - ص ٢٩]

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي وقال حديث حسن

فصل

وفي الكفاءة روايتان إحداهما هي شرط لصحة النكاح فإذا فاتت لم يصح وإن رضوا به لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء وقال عمر لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح كما لو زوجها وليها بغير رضاها

والثانية ليست شرطا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا مولاه ابنة عمته زينب بنت جحش وزوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية رواه مسلم وقالت عائشة إن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة أخرجه البخاري لكن إن لم ترض المرأة ولم يرض بعض الأولياء ففيه روايتان إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي والثانية يصح ولمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت البنت كان

للاخوة الفسخ لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين

فصل

والكفء ذو الدين والمنصب فلا يكون الفاسق كفئا لعفيفة لأنه مردود الشهادة والرواية غير مأمون على النفس والمال ولا يكون المولى والعجمي كفئا لعربية لما ذكرنا من قول عمر وقال سلمان لجرير إنكم معشر العرب لا تتقدم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم والعرب بعضهم لبعض أكفاء والعجم بعضهم لبعض أكفاء لان المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة ابنة الزبير بن عمة رسول الله وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب وعنه أن غير قريش لا يكافئهم وغير بني هاشم لا يكافئهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واختلفت الرواية في ثلاثة أمور أحدها الحرية فروي أنها ليست شرطا في الكفاءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته لو راجعتيه قالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شفيع ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة وروي أنها [ج ٣ - ص ٣١]

شرط وهي أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد فإذا ثبت لها الخيار بالحرية الطارئة فبالسابقة أولى ولأن فيه نقصا في المنصب والاستمتاع والإنفاق ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب والثاني اليسار ففيه روايتان إحداهما هو من شروط الكفاءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال وقال إن أحساب الناس بينهم هذا المال رواه النسائي بمعناه ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها والثانية ليس منها لأن الفقر شرف في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا رواه الترمذي وليس هو أمرا لازما فأشبه العافية من المرض واليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها حسب ما يجب لها والثالث الصناعة وفيها روايتان إحداهما أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافؤون من هو أعلى منهم فالحائك والحجام والكساح والزبال وقيم الحمام لا يكون كفئا لمن هو أعلى منه لأنه نقص في عرف الناس ونتعير المرأة به فأشبه نقص النسب والثانية ليس هذا شرطا لأنه ليس بنقص في الدين ولا هو بلازم فأشبه المرض وقد أنشدوا % وليس على عبد تقي نقيصة % إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم % [ج ٣ - ص ٣٢]

فصل

ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف لما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح رواه النسائي فإن أسروه وتواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وقال أبو بكر لا يصح للحديث ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل مفهومه صحته بهما والحديث محمول على الندب جمعا بين الخبرين ولأن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف إنما يكون بعد العقد وصحته ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد كسائر شروطه وقال أحمد لا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار % أتيناكم أتيناكم % فحيانا وحياكم % % ولولا الذهب الأحمر % ما حلت نواديكم % % ولولا الحنطة السمرا % ء ماسمنت عذاراكم %

فصل

ويستحب عقده يوم الجمعة لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك والمساية أولى لما روى أبو حفص بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ب الحمد لله فهو أقطع ويستحب أن [ج ٣ - ص ٣٣]

يخطب بخطبة ابن مسعود التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ﴿ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ ﴿ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ﴾ رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب الواهبة زوجتكها بما معك من القرآن ولم يذكر خطبة

فصل

ويستحب أن يقال للمتزوج ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أبو داود وإذا زفت إليه قال ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه رواه أبو داود وعن

أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فخضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله [ج ٣ - ص ٣٤]

صلى الله عليه وسلم فقالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك

فصل

ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك متفق عليه ويختار الجملية لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدوم لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح وروى سعيد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها ويختير الحسيبة لنجب ولدها وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم ويختار البكر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير رواه ابن ماجه ويختار الولود لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة رواه سعيد ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء لأنه ربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء قال [ج ٣ - ص ٣٥]

أبو الخطاب ويختار الأجنبية لأن ولدها أنجب وقد قيل إن الغرائب أنجب وبنات العم أصبر

2 باب ما يحرم من النكاح 2

المحرمات في النكاح عشرة أشياء أحدها المحرمات بالنسب وهن سبع ذكرهن الله سبحانه وتعالى بقوله ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ فالأمهات كل امرأة انتسبت إليها بولادة وهي الأم والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علون والبنات كل من انتسب إليك بولادة وهي ابنة الصلب وأولادها وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن والأخت من الجهات الثلاث والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علون من جهة الأب والأم والخالات كل من أدلى بالخؤ ولة من أخوات الأم وأخوات الجدات وإن علون من جهة الأب والأم وبنات الأخ كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلت درجتهن وكذلك بنات الأخ لأن الاسم ينطلق على البعيد والقريب لقوله تعالى ﴿ يا بني آدم ﴾ و ﴿ يا بني إسرائيل ﴾ وقال ﴿ ملة أبيكم إبراهيم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ارموا بني إسماعيل فإن

أباكم كان راميا ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام فتحرم عليه ابنته من الزنى لدخولها في عموم اللفظ ولأنها مخلوقة من مائة فحرمت كتحريم الزانية على ولدها وتحرم المنفية باللعان لأنها ربيبته ولاحتمال أنها ابنته

فصل

النوع الثاني المحرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب سواء لقوله تعالى ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ نص على هاتين وقسنا عيهما سائر المحرمات بالنسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه

فصل

النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع أمهات النساء لقوله تعالى ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ فمتى عقد النكاح على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون على ما ذكرنا وسواء دخل بالمرأة أو لم يدخل لعموم اللفظ فيهن ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها رواه ابن ماجه الثانية الربائب وهن بنات النساء ولا تحرم ربيبته إلا أن يدخل بأمها فإن فارق أمها قبل أن يدخل بها حلت له ابنتها لقوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ وإن ماتت قبل دخوله بها

لم تحرم ابنتها للآية وعنه تحرم لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق والعدة فكذا هاهنا وإن خلا بها ثم طلقها ولم يطأها فعنه تحرم ابنتها كذلك وقال القاضي وهذا محمول على أنه حصل نظرا لشهوة أو مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين فأما مع عدم ذلك فلا تحرم لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد والنسب والرضاع في هذا سواء

الثالثة حلائل الأبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع لقوله تعالى ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ ويحرمن بمجرد العقد لعموم الآية فيهن

الرابعة زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾ وسواء دخل بهن أو لم يدخل لعموم الآية

فصل

كل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع تحرم ابنتها وإن نزلت درجتها إلا بنات العمات والخالات فإنهن محللات لقوله تعالى ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ﴾ وكذلك بنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات فيجوز للرجل نكاح ربيبته أبيه وابنه لقوله ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ج ٣ - ص ٣٨]

فصل

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فتحريم الوطء أولى وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى كذلك ولأن الوطء آكد في التحريم من العقد وكذلك تحرم به الربيبة ولأنه سبب للبعضية أشبه الوطء في النكاح ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر لأن كل واحد منهما وطء في فرج يجب الحد بجنسه فاستويا في التحريم به وإن وطء صغيرة لا يوطأ مثلها أو ميتة ففيه وجهان أحدهما ينشر الحرمة لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة أشبه الرضاع والثاني لا ينشرها لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه النظر وفي القبلة واللمس لشهوة والنظر إلى الفرج لشهوة روايتان إحداهما يحرم لأنها مباشرة لا تباح إلا بملك فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء والثانية لا تحرم لقوله تعالى ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ يريد بالدخول الوطء وإن تلوط بغلام فاختار أبو الخطاب أن حكمه في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطئا في غير محله وقال غيره من أصحابنا حكمه حكم الزنى فيحرم على الواطىء أم الغلام وابنته ويحرم على الغلام أم الواطىء وابنته لأنه وطء في فرج [ج ٣ - ص ٣٩]

آدمي أشبه الزنا بالمرأة وإن وطىء أم امرأته أو ابنتها انفسخ النكاح لأنه طرأ عليها ما يحرمها أشبه الرضاع

فصل

النوع الرابع تحريم الجمع وهو ضربان جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين وهو ثابت في أربع بين الأختين لقوله تعالى ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ﴾ وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع لعموم الآية في الجميع والثاني بين الأم وبنتها لان تحريم الجمع بين الأختين تنبيه على تحريم الجمع بين الأم وبنتها والثالث الجمع بين المرأة وعمتها والرابع الجمع بينها وبين خالتها لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى فحرم الجمع بينهما كالأختين ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم لما بين الزوجات من التغاير والتنافر والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد فكذلك تحريم الجمع فإن تزوج أختين في عقد واحد بطل فيهما لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما كما لو باع درهما بدرهمين وإن تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد ففيها وجهان أحدهما يبطل فيهما كالأختين [ج ٣ - ص ٤٠]

والثاني يبطل في الأم وحدها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها والبنت لا تحرم بمجرد العقد فكانت الأم أولى بالبطلان فاختصت به وإن تزوج امرأة ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما لم يصح نكاح الثانية وحدها لأنها اختصت بالجمع

فصل

وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو بائنة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته لم يقبل قوله في إسقاط نفقتها وسكناها ويقبل في سقوط رجعتها لأنه يقر بسقوط حقه وفي جواز نكاح أختها لأنه حق لله تعالى وهو مقلد فيه ولو أسلم زوج المجوسية أو الوثنية لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختها ثم أسلما في عدة الأولى اختار منهما واحدة كما لو تزوجهما معا وإن أسلما بعد عدة الأولى بانت منه والثانية زوجته

فصل

وإن ملك أختين جاز لأن الملك لا يختص مقصوده بالاستمتاع

ولذلك جاز أن يملك من لا يحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع وله وطء إحداهما أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا فلم يكن جامعا بينهما في الفراش فإذا وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بإخراج عنه ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست حاملا لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو يكون جامعا ماءه في رحم أختين فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل له أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما وإن رهنها أو ظاهر منها لم تحل أختها لأنه متى شاء فك الرهن وكفر فأحلها وكذلك إن كاتبها لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهما فأشبه ما لو رهنها وروي عن أحمد أنه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء وإنما يكره لقوله تعالى ﴿ وما ملكت أيمانكم ﴾ والمذهب الأول لكونه إذا حرم الجمع في النكاح لكونه طريقا إلى الوطء ففي الوطء أولى وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها جاز ولا تحل له الأمة لأن أختها على فراشه فإن وطئها لم تحل له الزوجة حتى يستبرىء الأمة ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة عن ملكه أو يزوجها لأنهما قد صارت فراشا وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن النكاح لا يصح لأن النكاح سبب يصير به فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء قال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يصح لأن النكاح سبب يستباح به [ج ٣ - ص ٤٢]

الوطء فجاز أن يرد على وطء الأخت كالشراء ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الأمة بإخراج عن ملكه أو تزويج لما ذكرنا في التي قبلها وإن باع الموطوءة أو زوجها ثم تزوج أختها ثم عادت الموطوءة إلى ملكة لم تحل له كما لو اشتراها ابتداء ولا تحرم الزوجة لأن النكاح أقوى وعنه ما يدل على تحريمها أيضا حتى يخرج الأمة عن ملكه لأن هذه فراش والمنكوحة فراش فلا يحل وطء واحدة منهما كما لو كانتا أمتين ولو كانت له أمة يطأها فزوجها أو باعها ثم تسرى أختها فعادت الأولى إليه لم يبح له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه فلم يبح له واحدة منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش فإن ملك أختين فوطئهما فقد أتى محرما ولا حد عليه لأنه وطىء مملوكته فأشبه وطء المظاهر منها ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى كما يحرم وطء الأولى الثانية

فصل

إذا تزوج أختين في عقدين ثم جهل السابقة منهما حرمتا جميعا لأن المحللة اشتبهت بالمحرمة فحرمتا جميعا كما لو اشتبهت بأجنبية وعليه فراق كل واحدة منهما بطلقة لتحل لغيره ويزول حبسه عنها إلا أن يريد إمساك إحداهما فيطلق الأخرى ويجدد العقد للتي يمسكها فإن طلقهما معا قبل

الدخول فعليه نصف المهر لإحداهما لأن نكاحها صحيح ولا يعلم أيتهما هي فيقرع بينهما فيه لأنهما سواء فيقرع بينهما كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه فمن خرجت لها القرعة فلها نصف صداقها وقال أبو بكر يتوجه ألا يلزمه لهما صداق لأنه مجبر على طلاقهما فلم يلزمه صداقهما كما لو فسخ نكاحه برضاع أو غيره قال وهذا اختياري وإن كان دخل بهما فعليه كمال الصداقين لهما إلا أن لإحداهما المسمى وفي الأخرى روايتان إحداهما لها المسمى أيضا والثانية لها مهر المثل لأنه واجب بالإصابة لا بالعقد فإن قلنا يجب مهر المثل أقرعنا بينهما فيه وإن أراد نكاح إحداهما طلق الأخرى وعقد النكاح للثانية إلا أنه إن كان لم يدخل بواحدة منهما فله أن يعقد النكاح في الحال وإن كان دخل بها لم يعقده حتى تنقضي عدتها لئلا يكون ناكحا لإحداهما في عدة أختها أو ناكحا لمعتدة من وطئه لها في غير ملكه

فصل

ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا ابنتي الخال لقوله تعالى ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ولأن إحداهما لو كانت ذكرا حلت له الأخرى لكن يكره لما روى عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة وهذا محمول على الكراهة لما ذكرناه

ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها للآية وفعله عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية ويجوز للرجل أن يتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه وربيبة أمه للآية ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب محرم

فصل

الضرب الثاني تحريم الجمع لكثرة العدد فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بلا خلاف لقوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن رواه الترمذي وليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين لما روي عن الحكم بن عيينة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين وروى الإمام أحمد أن عمر سأل الناس عن ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف لا يتزوج إلا اثنتين وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا والحكم فيمن تزوج خمسا أو نكح خامسة في عدة الرابعة ونحو ذلك من الفروع كالحكم في الجامع بين أختين على ما مضى فيه

فصل

ويباح التسري من الإماء من غير حصر لقوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ ولأن القسم بينهن غير

[ج ٣ - ص ٤٥]

واجب فلم ينحصرن في عدد وللعبد أن يتسرى بإذن سيده نص عليه أحمد لأن ذلك قول ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده وأذن له في التسري قال القاضي يجب أن يكون تسري العبد مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده لأن الوطء لا يباح إلا بنكاح أو ملك يمين لقوله تعالى ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ والمكاتب كالقن سواء لأنه عبد ما بقي عليه درهم فأما من بعضه حر فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن السيد لقوله تعالى ﴿ أو ما ملكت أيمانهم ﴾ ولأن ملكه عليها تام فأما تزويجه فإنه يلزمه حقوق تتعلق بجميعه فاعتبر رضى السيد به ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه وإذا تسرى العبد بإذن سيده ثم رجع لم يكن له الرجوع نص عليه لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخه كالنكاح وقال القاضي ويحتمل أنه أراد التزويج وله الرجوع في التسري لأنه رجوع فيما ملكه لعبده فأشبه سائر المال

فصل

النوع الخامس المحرمات لاختلاف الدين فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ج ٣ - ص ٤٦]

وقوله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها ولا مجوسية لأنه لم يثبت لهم كتاب ولا كتابية أحد أبويها غير كتابي لأنها لم تمحض كتابية أشبهت المجوسية ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود أو كتاب غير التوراة والإنجيل لقوله تعالى ﴿ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال ويباح نكاح حرائر الكتابيات لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى وفي نصارى بني تغلب روايتان إحداهما إباحة نسائهم لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية والثانية تحريمهن لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال كتابيا كان أو غير كتابي لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ وقوله ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع

فصل

النوع السادس التحريم لأجل الرق وهو ضربان أحدهما تحريم الإماء وهن نوعان كتابيات فلا يحل لمسلم نكاحهن ولو كان عبدا وعنه يجوز والأول المذهب لقوله تعالى ﴿ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ فشرط في إباحتهن إيمانهن ولأنهن ناقصات من وجهين أشبه المشركات والثاني الأمة المسلمة فللعبد نكاحها لأنها تساويه ولا يحل لحر نكاحها إلا بشرطين عدم الطول وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة والثاني خشية العنت وهو الزنى لقوله تعالى ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ إلى قوله ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة لأنه لا يخشى العنت ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة وإن تزوج أمة تحل له ثم وجد الطول ففيه وجهان أحدهما نكاحه باق اختاره الخرقي لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله كما لو أمن العنت والثاني يبطل لأنه أبيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة وإن تزوج حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين كذلك فإن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول [ج ٣ - ص ٤٨]

الحرة وفي نكاح الحرة روايتان أصلهما تفريق الصفقة وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة كأجنبية وأخته من الرضاع فإن كانت الحرة لا تعفه ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه ففي نكاح الأمة روايتان إحداهما لا يصح لأنه واجد لطول حرة والثانية يصح لأنه خائف العنت عادم لطول حرة تعفه فحلت له الأمة كالعاجز عن نكاح حرة فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعا وكذلك الحكم إن كانت تحته حرة لا تعفه فيتزوج عليها أمة أو كان تحته أمة لا تعفه فيتزوج عليها ثانية ففيها روايتان قال الخرقي وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ووجه الروايتين ما تقدم وإن تزوج أمتين 0 في عقد واحد وإحداهما تعفه بطل فيهما لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين

فصل

الضرب الثاني أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره بسفرها وطاعته إياها ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك فيتنافيان ولا يصح أن يتزوج الحر أمته لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من القسم والمبيت فبطل فإن ملكت المرأة زوجها أو جزءا منه أو ملك [ج ٣ - ص ٤٩]

الرجل زوجته أو جزءا منها انفسخ النكاح لما ذكرنا ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها فلم يحل له نكاحها كالمشتركة بينه وبين غيره وللابن أن يتزوج أمة أبيه لعدم ذلك فيه وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيه وجهان أحدهما يبطل النكاح لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح والثاني لا يبطل لأنه يملكها بملك الابن فلم يبطل نكاحه كما لو ملكها أجنبي

فصل

النوع السابع منكوحة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه لقوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ولقوله ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فلو جوزنا تزويجها لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطىء الأول ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زنى لم ينفسح نكاحه لأن النكاح سابق فكان أولى ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي

ماؤه زرع غيره رواه الترمذي وقال حديث حسن وأبو داود وزاد يعني إتيان الحبالى ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه قال أحمد وإذا علم الرجل من جاريته الفجور فلا يطؤها لعلها تلحق به ولدا ليس منه

فصل

ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية لأنها زوجة فأشبهت ما قبل الطلاق ويجوز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة والطلاق الثلاث لقوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقيني بنفسك ويحرم التصريح لأن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها بخلاف التعريض فأما البائن بخلع فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض لأنه يحل له نكاحها في عدتها إذ لا يصان ماؤه عن مائه ولا يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها فيه وجهان أحدهما لا يحل لأن الزوج يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية والثاني يحل لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمرأة كالرجل فيما يحل لها من الجواب ويحرم والتصريح أن يقول زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك [ج ٣ - ص ٥١]

ونحوه والتعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تسبقيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك ونحوه وتجيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوه

فصل

ومن خطب امرأة فأجيب حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن أو يترك لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك متفق عليه وفي حديث أو يأذن له فيخطب ولأن في ذلك إفسادا على أخيه وإيقاعا للعدواة بينهما فحرم كبيعه على بيعه وإن لم يسكن إليه فلغيره خطبتها لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة متفق عليه فخطبها بعد خطبتهما وإن لم يعلم هل أجابت أم لا ففيه وجهان أحدهما التحريم لعموم النهي والثاني الإباحة لأن الأصل عدم الاجابة المحرمة والتعويل في الإجابة والرد عليها إن كانت غير مجبرة وعلى وليها إن كانت مجبرة

فصل

النوع الثامن الملاعنة تحرم على الملاعن ويذكر في بابه

النوع التاسع الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب لقوله تعالى ﴿ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ ولأنه لا يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره فحرم نكاحها كالمعتدة ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره لأن ولدها لا يلحق نسبه بأحد فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب فأما الموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فهل يحرم فظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ لقوله في الذي تزوج امرأه في عدتهاله ان ينكحها بعد إنقضاء العدتين وذلك لأنه وطء في غير ملك أشبه الوطء المحرم ويحتمل أن لا تحرم على الواطىء لأن نسب ولدها لاحق به فأشبهت المعتدة من النكاح

فصل

واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقال أبو بكر لا يصح نكاحه ونص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني لأنه مشكوك في حله للرجال والنساء فلم يحل كما لو اشتبهت الأجنبية بالأخت وقال الخرقي يرجع إلى قوله فإن قال إني رجل حل له النساء وإن قال أنا امرأة لأنه لم ينكح الارجلا لأنه معنى لايعرف إلا من جهته وليس فيه [ج ٣ - ص ٥٣]

إيجاب حق على غيره فوجب أن يقبل منه كما يقبل قول المرأة في انقضاء عدتها فعلى هذا إن عاد بعد نكاح المرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء وإن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا زال النكاح فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه وسواء دخل به أو لم يدخل ويحرم عليه النكاح بعد ذلك لما ذكرناه

فصل

النوع العاشر التحريم للإحرام فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة ولا يجوز عقد المحرم نكاح غيره ومتى عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة أو عقد المحرم نكاحا لغيره أو لنفسه فالعقد باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح كالعدة وعنه أن عقد المحرم النكاح لغيره صحيح لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء ولا يحصل ذلك بكونه وليا والأول أصح لعموم الخبر فأما إن كان شاهدا في النكاح [ج ٣ - ص ٥٤]

انعقد بشهادته لأنه من أهل الشهادة فأشبه الحلال وتكره له الشهادة والخطبة للخبر في الخطبة والشهادة في معناها لأنها معونة على النكاح

2 باب الشروط في النكاح 2

وهي قسمان صحيح وفاسد فالصحيح نوعان أحدهما شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المرأة إليه وتمكينه من استمتاعها فهذا لا يؤثر في العقد ووجوده كعدمه والثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها معلومة أو نقد معين أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها ولا بلدها فهذا صحيح يلزم الوفاء به لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذا يطلقننا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزيادة في المهر فإن لم يف به فلها فسخ النكاح لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع [ج ٣ - ص ٥٥]

فصل

القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع أحدها ما يبطل في نفسه ويصح النكاح مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لها أو الرجوع عليها بمهرها أو لا نفقة لها عليه أو أن نفقته عليها أو لا يطؤها أو يعزل عنها أو يقسم لها دون قسم صاحبتها أو ألا يقسم لها إلا في النهار أو ليلة في الأسبوع ونحوه فهذه الشروط باطلة في نفسها لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كإسقاط الشفعة قبل البيع وقد نقل عن أحمد في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام وهذا يحتمل إفساد العقد فيتخرج عليه سائر الشروط الفاسدة أنها تفسده لأنها شروط فاسدة فأفسدت العقد كما لو زوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته وهذا يحتمل أن يفسد بشرطها عليه ترك الوطء لأنه ينافي مقتضى العقد ومقصوده ولو شرط عليها ألا يطأها لم يفسد لأن الوطء حقه عليها وهي لا تملكه

فصل

النوع الثاني ما يفسد النكاح من أصله وهو أربعة أمور أحدها أن يشرطا تأقيت النكاح وذلك نكاح المتعة مثل أن يقول زوجتك ابنتي

شهرا أو نحوه فالنكاح باطل نص عليه ما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود ولأنه لم يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة قال أبو بكر فيه رواية أخرى أنها مكروهة لأن أحمد قال في رواية ابن منصور يجتنبها أحب إلي فظاهرها الكراهية لا التحريم وغيره من أصحابنا يقول المسألة رواية واحدة في تحريمها ولو شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط ألا يطأها

فصل

الأمر الثاني أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته فهذا نكاح الشغار ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي فإن سميا مع ذلك صداقا فقال زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ومهر كل واحدة [ج ٣ - ص ٥٧]

مائة فالمنصوص عن أحمد صحته لحديث ابن عمر وقال الخرقي لا يصح لما روى الأعرج أن العباس بن عبيد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه وإن سمى لأحدهما مهرا دون الأخرى فقال أبو بكر النكاح فاسد فيهما وقال القاضي يجب أن يكون في التي سمى لها مهرا روايتان

فصل

الشرط الثالث أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله ثم يطلقها فيكون النكاح حراما باطلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له قال الترمذي هذا حديث صحيح فإن تواطآ على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضا نص عليه وقال متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث وروى نافع أن رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ولم يأمرني ولم تعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا ولا يزالان زانيين وإن مكثا

عشرين سنة وإن شرط عليه سابقا إحلالها فنوى غير ذلك صح لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج لم يؤثر في العقد لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق فلم يؤثر بنيتهما كالأجنبي وإن زوجها عبده بنية أن يهبها إياه لينفسخ نكاحه فهو نكاح المحلل لأنه قصد به التحليل وذكر القاضي فيما إذا خلا العقد عن شرط التحليل وجها آخر أنه يصح وخرجه أبو الخطاب رواية لأنه روي عن أحمد أنه كرهه فظاهره الصحة مع الكراهة لأن مجرد النية لا يفسد العقد كما لو اشترى عبدا ينوي أن يبيعه

فصل

النوع الثالث فاسد وفي فساد النكاح به روايتان وهو أن يتزوجها بشرط الخيار أو إن رضيت أمها أو إنسان ذكره أو بشرط ألا يكره فلان أو إن جاءها بالمهر إلى كذا وإلا فلا نكاح بينهما فنقل عنه ابناه وحنبل نكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد لأن عقد النكاح يجب أن يكون ثابتا لازما فنافاه هذا الشرط كالخلع ونقل عنه أن العقد صحيح والشرط باطل لإن النكاح يصح في المجهول فلم يفسد بالشرط الفاسد كالعتق ونقل عنه فيمن شرط إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أن الشرط صحيح لأن لها فيه نفعا أشبه ما لو شرط ألا يخرجها من دارها [ج ٣ - ص ٥٩]

2 باب الخيار في النكاح 2

وأسبابه أربعة أحدها أن يجد أحدهما بصاحبه عيبا يمنع الوطء وهو سبعة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون مطبقا كان أو غير مطبق والجذام والبرص واثنان في الرجل الجب والعنة واثنان في المرأة الرتق وهو انسداد الفرج والفتق وهو انخراق ما بين مخرج البول والمني وقيل انخراق ما بين القبل والدبر فمن وجد بصاحبه عيبا منها فله الخيار في فسخ النكاح لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به ويغيب منه في الفرج قدر الحشفة فلا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المرأة لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء [ج ٣ - ص ٦٠]

فصل

وإن وجد أحدهما الآخر خنثى أو وجدت زوجها خصيا ففيه وجهان أحدهما لها الخيار لأنه يثير نفرة وفيه نقص وعار فأشبه البرص والثاني لا خيار لها لأنه لا يمنع الاستمتاع واختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه فقال أبو بكر يثبت به الخيار لأنه ينفر عن الاستمتاع ويتعدى ضرره ونجاسته وقال غيره لا خيار فيه لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه ويتخرج عليه الناصور والباسور والقروح السيالة في الفرج لأنها في معناه واختلفوا في العفل وقيل هو رغوة في الفرج يمنع لذة الوطء فعده الخرقي مانعا كذلك ولم يعده القاضي في الموانع لأنه لا يمنع الاستمتاع وكذلك يخرج في الرائحة الكريهة التي في الفرج تثور عند الوطء وما عدا هذه العيوب كالقرع والعمى والعرج لا يثبت به خيار لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه

فصل

ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه وإن وجد بصاحبه عيبا به مثله ففيه وجهان أحدهما لكل واحد منهما الخيار لوجود سببه فأشبه العبد المغرور بأمة ولأنه قد يعاف عيب غيره وإن كان به مثله والثاني لا خيار له لأنهما [ج ٣ - ص ٦١]

متساويان في النقص فأشبها القفيزين وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد ففيه وجهان أحدهما لا خيار له وهو قول أبي بكر لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع والثاني يثبت به الخيار وهو ظاهر قول الخرقي لأنه عيب لو قارن أثبت الخيار فإذا حدث أثبته كالإعسار

فصل

وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ لم يبطل خياره وقال القاضي يبطل وأصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع وإن قال رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى كالاستمتاع أو التمكين منه بطل خياره

فصل

وإن فسخ قبل المسيس فلا مهر لها لأنه إن كان الفسخ منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان من الزوج فهو لمعنى من جهتها لحصوله بتدليسها فأشبه ما لو باشرتها وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى فيه كما لو ارتدت وذكر القاضي أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد وليس هذا بفاسد إذ

لو كان فاسدا لما ثبت الخيار فيه ويرجع بالمهر على من غره لما روي عن عمر أنه قال أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها غرم على وليها ولأنه غره في النكاح بما يجب به المهر فكان المهر عليه كما لو غره بحرية أمة وعنه لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه فإن لم يعلم الولي فالغرور من المرأة وإن طلق الزوج ثم علم بها عيبا فعليه المهر لا يرجع به على أحد لأنه رضي بالتزامه

فصل

ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للاعسار فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد المشتري وإن اتفقا على الرجعة لم يجز إلا بنكاح جديد ويرجع على طلاق ثلاث وقال أبو بكر فيها قول آخر إنها تحرم على التأبيد لأنه فرقة حاكم فأشبهت فرقة اللعان ولنا أنها فرقة لعيب أشبهت فرقة المعتقة تحت عبد

فصل

وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب لأن فيه ضررا بهم وعليه النظر في الحظ لهم ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأن فيه ضررا بها فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك

منعها لأن الضرر يختص بها وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها لأن عليه ضررا وعارا ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها ويحتمل أنه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة فإن رضيا به جاز ويكره قال أحمد ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت وإن حدث العيب بالرجل أو وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه ولهذا يملك منعها من نكاح العبد ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ

فصل

وإذا اختلفا في عيب المرأة أريت النساء الثقات فرجع إلى قولهن فإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل السلامة وإن اعترف أجله الحاكم عاما منذ رافعته لما روى سعيد بن المسيب إن عمر أجل العنين سنة وعن علي والمغيرة مثله ولأن العجز قد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فإذا مضت السنة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقه ولا تثبت المدة إلا بالحاكم لأنها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الإيلاء فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأها خيرت في المقام معه أو فراقه لأن الحق لها فإن رضيته عنينا أو قالت في وقت قد رضيته عنينا لم يكن لها خيار بعد ذلك لأنها رضيت العيب [ج ٣ - ص ٦٤]

فأشبه ما لو رضيت المبيع المعيب وإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا وإن ادعى أنه وطئها فادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت فالقول قولها وإلا فالقول قوله وإن اختلفا وهي ثيب فالقول قوله لأن الأصل السلامة وعنه القول قولها لأن الأصل عدم الإصابة وعنه يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن عجز عن ذلك فالقول قولها وإن فعل فالقول قوله فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها لأنه شبيه ببياض البيض وذاك إذا وضع على النار يجمع ويبس وهذا يذوب فيتميز بذلك أحدهما من الآخر فيختبر به لأن هذا قول عطاء وإن اعترفت أنه وطىء غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح والدبر ليس بمحل للوطء فأشبه ما دون الفرج ويقتضي قول أبي بكر أنها متى اعترفت بوطئه لغيرها أو لها في أي نكاح كان زالت عنته وهذا اختيار ابن عقيل لأن العنة جبلة وخلقة فلا تبقى مع ما ينافيها وأدنى الوطء الذي يخرج به من العنة إيلاج الحشفة في الفرج لأنه الوطء الذي تتعلق به الأحكام دون غيره وهل يحلف من القول قوله يحتمل وجهين بناء على الاستحلاف في غير دعوى المال [ج ٣ - ص ٦٥]

فصل

السبب الثاني إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح لما روت عائشة قالت كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها قال عروة ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مالك في موطئه وأبو داود في سننه وإن عتقت وزوجها حر فلا خيار لها للخبر ولأنها كملت تحت كامل فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم بخلاف زوجة العبد ولها الفسخ بنفسها لأنه خيار ثبت بالنص والإجماع ولما روى الحسن عن عمرو بن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته فإن وطئها فلا خيار لها رواه الإمام أحمد في المسند وخيارها على التراخي للخبر ما لم يطأها فإن أمكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر ولأنه دليل على رضاها به فبطل خيارها كما لو نطقت به وإن لم تعلم بطل خيارها أيضا نص عليه أحمد للخبر وقال القاضي وأبو الخطاب لا يبطل لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به وإن لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففيه وجهان كالتي قبلها فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها لبعدها عن المعتق فالقول قولها مع يمينها وإن كانت ممن لا يخفى عليها ذلك لقربه واشتهاره لم يقبل قولها فإن ادعت [ج ٣ - ص ٦٦]

الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها لأنه لا يعلمه إلا خواص الناس وإن أعتق العبد قبل اختيارها بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه فزال كرد المعيب إذا زال عيبه ولو أعتقا معا فلا خيار لها وعنه لها الخيار والأول أولى لأنها لو عتقت تحت حر لم يثبت لها خيار لعدم الضرر فكذا هاهنا ويستحب لمن أراد عتق عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل لئلا يكون للمرأة عليه خيار وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان غلام وجارية فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما فقال لها فابدئي بالرجل

فصل

فإن أعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما لأنهما لا عقل لهما ولا قول معتبر ولا يملكه وليهما لأن هذا طريقه الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص فإذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما والحكم في وطئهما كالحكم في وطء الجاهلة بالعتق

فصل

إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين اختارها الخرقي لأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على من عتق جميعها لأنها أكمل

منها والثانية لها الخيار اختارها أبو بكر لأنها أكمل من زوجها فأشبهت الكاملة العتق

فصل

إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ من جهتها وعنه يجب نصف المهر للسيد لأنه المستحق له فلا يسقط نصفه من جهة غيره وإن رضيته فالمهر للسيد لأنه استحقه بالعقد وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لأنه وجب له بالعقد واستقر بالدخول فأشبه ما لو ارتدت وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه ولسيدها نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده وقال القاضي طلاقه موقوف إن فسخت تبينا أنه لم يقع وإن لم تفسخ وقع ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح فوقع كما لو لم يعتق

فصل

وإن طلقها الزوج طلاقا بائنا ثم أعتقت فلا خيار لها لأنه لا نكاح بينهما يفسخ وإن كان رجعيا فلها الفسخ في العدة لأن نكاحها باق ويمكن فسخه فإذا فسخت انقطعت الرجعة وبنت على ما مضى من العدة كما لو طلقها بائنة وإن اختارت المقام معه بطل خيارها لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح [ج ٣ - ص ٦٨]

فصل

السبب الثالث الغرر فلو تزوجت المرأة رجلا مطلقا أو على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح لأنها إذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة فللسابقة أولى ولها الفسخ من غير حاكم كما لو عتقت تحت عبد ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة والكفاءة من شروط النكاح أبطله لفوات شرطه

فصل

وإن تزوج أمة على أنها حرة أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء فالنكاح فاسد وعليه فراقها متى علم وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وغيره وإن كان ممن تحل له الإماء فالنكاح صحيح لأن فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد كما لو تزوجها على أنها بيضاء فبانت سوداء وفي الموضعين متى أصابها فولدت منه فالولد حر حرا كان الزوج أو عبدا لأنه اعتقد حريتها وعليه فداء أولاده لأن عمر وعليا وابن عباس قضوا بذلك وعنه ليس عليه فداؤهم لأن الولد ينعقد حرا فلم يضمنه لسيدها لأنه لم يملكه وعنه يقال للزوج افتد ولدك وإلا فهم يتبعون الأم والمذهب الأول وله فسخ نكاحها إن أحب لأنه غرور بالحرية أشبه غرور المرأة فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه لأن الفسخ لسبب [ج ٣ - ص ٦٩]

من جهتها وإن فارقها بعد الدخول فعليه المهر بما أصاب منها ويرجع بما غرمه من المهر وفداء الأولاد في الموضعين على من غره نص عليه أحمد وذكره الخرقي لأن الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به وعن أحمد لا يرجع بالمهر وهو اختيار أبي بكر لأنه يروى عن علي رضي الله عنه ولأنه وجب في مقابلة نفع وصل إليه وظاهر المذهب الاول لان العاقد ضمن له سلامه الوطء كما ضن له سلامة الولد أن يرجع به كقيمة الولد

فصل

ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه ولأنه محكوم بحريتهم يوم وضعهم فاعتبر فداؤهم يومئذ وتجب القيمة لأنه ضمان وجب لفوات حرية فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سرى العتق إليه وعنه يفديهم بعبيد مثلهم لأنه يروى عن عمر أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة مكان كل غلام غلام ومكان كل جارية جارية ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار وعنه أنه مخير بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم لأن الأمرين يرويان جميعا عن عمر فإن فداهم بمثلهم وجب مثلهم في القيمة اختاره أبو بكر لأن الحق ينجبر بذلك ويحتمل أن ينظر إلى صفاتهم تقريبا لأن الآدمي ليس من ذوات الأمثال ولا يفدى منهم إلا من ولد حيا في [ج ٣ - ص ٧٠]

وقت يعيش مثله سواء عاش أو مات بعد ذلك لأن غير ذلك لا قيمة له

فصل

وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار لأنه وطئها يعتقد حريتها فكان ولده حرا كولد الحر وعليه فداؤهم لأنه فوت رقهم وهل يتعلق فداؤهم برقبته أو بذمته على وجهين أحدهما برقبته كأرش جنايته والثاني بذمته كعوض الخلع من الأمة ويرجع به على من غره فإن قلنا برقبته رجع به في الحال لأنه يؤخذ من سيده في الحال وإن قلنا يتعلق بذمته لم يلزمه أداؤه حتى يعتق ولا يرجع به حتى يغرمه لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه وتتعجل حريتهم في الحال وللعبد الخيار إذا علم ويحتمل أن لا يثبت لأنه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته فأشبه ما لو شرط نسب امرأة فبان خلافه والأول ظاهر المذهب لأنه مغرور بحرية فملك الفسخ كالحر الذي يباح له نكاح الإماء وإن غرت الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر فلها الخيار أيضا لأنها مغرورة بحرية من ليس بحر أشبهت المرأة الحرة والعبد المغرور ويحتمل ألا يثبت لها خيار لأنه يكافئها ولا يؤثر رقه في إرقاق ولدها فأشبه ما لو شرطته أشرف نسبا منها فتبين أنه مثلها [ج ٣ - ص ٧١]

فصل

فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه وإن لم يخل بها ففيه وجهان أحدهما لا خيار لها لأن زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته فأشبه ما لو شرطته جميلا أو فقيها فبان بخلافه والثاني لها الخيار لأنها شرطت ما يقصد فأشبه شرط الصفة المقصودة في المبيع

فصل

وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا أو نسيبة أو جميلة أو بيضاء فبانت بخلافه ففيه وجهان أحدهما لا خيار له لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل والثاني له الخيار لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد فملك الخيار به إذا شرط عدمه كالرق وإن تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له لأنها زيادة وقال أبو بكر له الخيار لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها فيضره فواته وإن تزوجها على أنها أمة فبانت حرة فلا خيار له لأنها زيادة وكذلك لو شرطها على صفة فبانت خيرا منها لأنه نفع فلم يثبت به الخيار كما لو شرطه في المبيع [ج ٣ - ص ٧٢]

فصل

والسبب الرابع الإعسار بالنفقة ونحوها على ما نذكره في موضعه ومخالفته شرطها اللازم كاشتراطها دارها ونحوها على ما مضى و الله أعلم

2 باب نكاح الكفار 2

أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم وإن خالفت أنكحة المسلمين فهي صحيحة إلا أن يتزوج محرمة عليه لأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم وعن أ حمد في مجوسي تزوج نصرانية أو ملك نصرانية يحول بينهما الإمام فيخرج من هذا أنه يفرق بينهم وبين ذوات المحارم لأن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وإن ملك نصراني مجوسية لم يحل بينهما لأنه أعلى منها وقال أبو بكر يمنع من وطئها أيضا كما يمنع المجوسي من النصرانية فأما إن أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ينظر في كيفية عقدهم ونظرنا في الحال فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال أقررناهما وإن كانت ممن يحرم نكاحها في الحال كذات محرمة والمعتدة والمطلقة ثلاثا فرقنا بينهما وإن [ج ٣ - ص ٧٣]

تزوجها بشرط الخيار مدة أو في عدتها ثم أسلما في المدة أو العدة فرقنا بينهما كذلك وإن أسلما بعد انقضائهما أقررناهما عليه وإن قهر حربي حربية فوطئها وطاوعته واعتقداه نكاحا أقررناهما عليه وإلا فلا وإن أسلما وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه الخيار متى شاء لم يقرا عليه لأنهما لا يعتقدان لزومه ولا تأبيده وإن اعتقدا فساد الشرط وحده أقرا عليه

فصل

وإذا أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما سواء أسلما قبل الدخول أو بعده لأن ذلك إجماع ولأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين يقتضي الفرقة وإن سبق أحدهما صاحبه وكان المسلم زوج كتابية فالنكاح بحاله لأنه يحل له ابتداء نكاحها وإن أسلمت المرأة قبله أو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول بانت منه امرأته لقوله تعالى ﴿ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾ وقوله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر بلفظه لأنه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمه الإسلام دفعة واحدة فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه روايتان إحداهما تتعجل الفرقة

لما ذكرنا والثانية تقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول بحيث لو كان وطئها في عدتها ولم يسلم أدب ولها عليه مهر مثلها لما روى ابن شبرمة قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين أسلما مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم منهم أبو سفيان وجماعة أسلم أزواجهن قبلهم منهم صفوان بن أمية وعكرمة وأبو العاص بن الربيع والفرقة الواقعة بينهما فسخ لأنها فرقة عريت عن الطلاق فكانت فسخا كسائر الفسوخ

فصل

وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه أو كن كتابيات أمر أن يختار منهن أربعا ويخلي سائرهن سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة وسواء اختار أول من عقد عليها أو آخرهن لما روى قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن أربعا رواه أبو داود فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير لأنه حق عليه يمكنه إيفاؤه فأجبر عليه كالدين ولا يملك الحاكم الاختيار عنه [ج ٣ - ص ٧٥]

لأنه حق لغير معين فإن جن خلي حتى يفيق ثم يخير لأنه عجز عن الاختيار فأشبه العاجز عن الدين بالإعسار وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح فإن مات قبل الاختيار لم يقم وارثه مقامه لما ذكرنا ولزم جميعهن العدة لأن كل واحدة يجوز أن تكون زوجة وعدة الحامل وضع حملها وعدة ذوات الأشهر أربعة أشهر وعشرا وعدة ذوات الأقراء أطول الأجلين من ثلاثة قروء وعدة الوفاة ليسقط الفرض بيقين والميراث لأربع منهن بالقرعة إلا أن يصطلحن عليه فيكون بينهن على ذلك

فصل

والاختيار أن يقول قد اخترت هؤلاء أو نكاح هؤلاء أو أمسكتهن أو نحو هذا وإن قال اخترت فسخ نكاح هؤلاء كان اختيارا لغيرهن وإن طلق واحدة كان اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة وإن قال فارقت هذه ففيه وجهان أحدهما يكون اختيارا لنكاحها لأن الفراق طلاق والثاني يكون فسخا لنكاحها واختيارا لغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا في ترك نكاحها وإن وطىء إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب كما لو وطىء الجارية المعيبة في مدة الخيار [ج ٣ - ص ٧٦]

وإن آلى أو ظاهر منها لم يكن اختيارا لها لأنه يصح في غير زوجتة ويحتمل أنه اختيار لها لأنه لا يؤثر إلا في زوجه فإن طلق الجميع أقرع بينهن فإذا وقعت القرعة على أربع منهن فهن المختارات فيقع طلاقه بهن وينفسخ طلاق البواقي وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات وإن أسلم قبلهن وقال كلما أسلمت واحدة منهن فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحها لم يصح لان الاختيار والفسخ لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين لأنه كالعقد ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على الأربع وقد يجوز ألا يسلم أكثر من أربع وإن قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان أحدهما يصح لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط وكلما أسلمت واحدة طلقت وكان اختيارا لها والثاني لا يصح لأنه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط وإن قال اخترت فلانة أو فسخت نكاحها قبل إسلامها لم يصح لأنه ليس بوقت لاختيار ولا فسخ وإن طلقها كان موقوفا إن أسلمت تبينا وقوع طلاقه وإلا فلا وإن وطىء واحدة فأسلمت في عدتها تبينا أنه وطىء زوجته وإن لم تسلم فقد وطىء أجنبية وإن طلق الجميع فأسلمن في العدة أمر باختيار أربع منهن فيتبين وقوع طلاقه بهن ويعتددن من حين طلاقه وبان سائرهن بغير طلاق

فصل

وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمن معه لزمه اختيار اثنتين لأنهما في حقه كالأربع في حق الحر فإن عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد وإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم لزمه نكاح أربع لأنه في وقت الاختيار ممن له نكاح أربع

فصل

ومن أسلم وتحته أختان لزمه أن يختار إحداهما لما روى الضحاك ابن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيهما شئت رواه أبو داود ولأن الجمع بينهما محرم فأشبه الزيادة على الأربع وهذا القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأن جمعهما محرم وإن أسلم وتحته امرأة وبنتها ولم يدخل بالأم انفسخ نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها وثبت نكاح بنتها لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها وإن كان قد دخل بالأم انفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد

فصل

ولو أسلم حر وتحته إماء فأسلمن معه وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاح الإماء وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار منهن واحدة

لأنه يملك ابتداء نكاحها فملك اختيارها كالحرة ولو أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام فاعتبر حاله حينئذ وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له الاختيار منهن كذلك فإن أسلمت معه واحدة فله اختيارها وله انتظار الباقيات لأن له غرضا صحيحا فيه فإن اختار الأولى ثبت نكاحها وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلف دينهن وان اختار فسخ نكاح المسلمة لم يكن له ذلك لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها ولا فضل فإن فسخ ولم تسلم البواقي لزمه نكاحها وبطل الفسخ وان أسلمن فله اختيار واحدة فإن اختار التي فسخ نكاحها ففيه وجهان أحدهما له ذلك لأن الفسخ كان قبل وقته فوجوده كعدمه والثاني ليس له ذلك لأننا إنما منعنا الفسخ فيها لكونها غير فاضلة وبإسلام غيرها صارت فاضلة فصح فسخ نكاحها

فصل

وإن أسلم وتحته حرة وأمة فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الأمة إن كان ممن له نكاح الإماء وإن أسلمتا في العدة ثم ماتت الحرة أو عتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة لأن

نكاحها انفسخ بإسلام الحرة وإن عتقت الأمة قبل إسلامها فله إمساكها لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام وهي حرة حينئذ وإن أسلمت قبله وعتقت ثم أسلم الزوج فله إمساكها كذلك ولو أسلم وتحته إماء فعتقت إحداهن ثم أسلمن كلهن لزم نكاح الحرة وانفسخ نكاح الإماء وإن أسلمت إحداهن ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن لأن الاعتبار بحالة الاختيار وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام وهي أمة حينئذ

فصل

وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح لاختلاف دينهما أو كون المرأة بحال لا يحل نكاحها وإن كان بعده ففيه روايتان إحداهما تتعجل الفرقة والثانية تقف على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يجتمعا وقعت الفرقة من حين الردة لأنه انتقال عن دين يمنع ابتداء النكاح فكان حكمه ما ذكرنا كإسلام أحد الزوجين

فصل

وإن انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب كالمجوسية وغيرها ففيه ثلاث روايات إحداهن يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره لأن [ج ٣ - ص ٨٠]

ما سواه باطل اعترف ببطلانه لأنه لما كان على دينه اعترف ببطلان ما سواه ثم اعترف ببطلان دينه حين انتقل عنه فلم يبق إلا الإسلام والثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه لأننا أقررناه عليه أولا فنقره عليه ثانيا والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين أهل الكتاب لأنه دين أهل كتاب فيقر عليه كغيره من أهل ذلك الدين وإن انتقل المجوسي إلى دين أهل الكتاب أو انتقل كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب ففيه ثلاث روايات إحداهن لا يقبل منه إلا الإسلام لما ذكرنا والثانية يقر على ما انتقل إليه والثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم وإذا قلنا لا يقبل منه إلا الإسلام ففيه روايتان إحداهما أنه يجبر عليه بالقتل كالمرتد والثانية أنه إن انتقل إلى المجوسية أجبر بالقتل وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب لم يجبر بالقتل لكن يجبر بالضرب والحبس لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب فلم يقبل كالباقي على دينه وكل موضع قلنا لا يقر فإذا انتقلت الكتابية المتزوجة للمسلم فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه

فصل

إذا أسلم الزوجان قبل الدخول فقالت المرأة أسلم أحدنا فانفسخ النكاح وقال بل أسلمنا معا ففيه وجهان أحدهما القول قول الزوج [ج ٣ - ص ٨١]

لأن الأصل بقاء النكاح والثاني القول قولها لأن الظاهر معها فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر بعيد وإن اتفقا على سبق أحدهما وقالت المرأة أنت السابق فعليك نصف المهر وقال الزوج بل أنت سبقت فلا مهر لك فالقول قول المرأة لأن الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه وإن أسلما بعد الدخول فقال الزوج أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل انقضت عدتي قبل إسلامك فالقول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وفيه وجه آخر أن القول قول المرأة لأن الأصل عدم إسلام الثاني وإن قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك فقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة ففيه وجهان أحدهما القول قولها لأن الأصل وجوب النفقة والثاني القول قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوبه

فصل

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول وإن أسلم الثاني في العدة فابتداء العدة من حين ارتد لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمن ثم ارتددن أو ارتد دونهن لم يكن له أن يختار منهن لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال [ج ٣ - ص ٨٢]

فصل

ولو أسلم عبد وتحته أمة كافرة فأعتقت أو أسلمت قبله ثم أعتقت فلها فسخ النكاح لأنها عتقت تحت عبد فإذا فسخت ثم أسلم الثاني في العدة بانت بفسخ النكاح وإن لم يسلم الثاني تبينا أنها بانت باختلاف الدين وعليها عدة حرة في الموضعين لأنها وجبت وهي حرة أو عتقت في أثناء عدة يمكن الزوج تلافي نكاحها فيها فأشبهت الرجعية وإن أخرت الفسخ حتى أسلم الثاني منهما لم يسقط حقها لأنها تركته اعتمادا على جريانها إلى البينونة فأشبهت الرجعية وإن قالت قد رضيت بالزوج فذكر القاضي أنه يسقط حقها لأنها رضيته في حال يمكن فسخه فصح كحالة اجتماعهما على الإسلام [ج ٣ - ص ٨٣]

1 كتاب الصداق 1

يستحب أن يعقد النكاح بصداق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته بصداق وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه ولأنه أقطع للنزاع فيه ويجوز من غير صداق لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ﴾ فأثبت الطلاق مع عدم الفرض ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع وهو حاصل بغير صداق

فصل

ويجوز أن يكون الصداق قليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما [ج ٣ - ص ٨٤]

من حديد ولأنه بدل منفعتها فكان تقديره إليها كأجرتها ويجوز أن يكون كثيرا لقوله تعالى ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ﴾ ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال سألت عائشة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ثنتا عشرة أوقيه ونش فقلت ومانش قالت نصف أوقية رواه مسلم وأبو داود ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت ويستحب تخفيفه لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أحمد

فصل

وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في إجارة من دين وعين وحال ومؤجل ومنفعة معلومة من حر أو عبد كرد عبدها من مكان معين وخدمتها في شيء معلوم جاز أن يكون صداقا لأن الله تعالى أخبر عن شعيب أنه قال ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ فجعل الرعي صداقا ولأنه عقد على المنفعة فجاز ما ذكرنا كالإجارة

فصل

وما لا يجوز أن يكون ثمنا ولا أجرة لا يجوز أن يكون صداقا

كالخمر وتعليم التوراة والإنجيل وتعليم الذمية القرآن والمعدوم وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع المعتبر قبضه قبل قبضه ومالا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء لأنه عوض في عقد فأشبه عوض البيع والإجارة ولا يصح أن يكون مجهولا كعبد وثوب وهذا اختيار أبي بكر وقال القاضي يصح في مجهول جهالة لا تزيد على مهر المثل كعبد أو فرس أو بعير أو ثوب هروي أو قفيز حنطة أو قنطار زيت لأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح مع كثرة الجهل فهذا أولى فإن زادت جهالته على جهالة مهر المثل كثوب ودابة وحكم إنسان ورد عبدها أين كان وخدمتها فيما أرادت لم يصح وقال أبو الخطاب إن تزوجها على عبد من عبيده صح ولها أحدهم بالقرعة نص عليه أحمد وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصا من قمصانه أو عمامة من عمائمه أو دابة من دوابه لأن الجهالة تقل فيه ولا تصح على عبد مطلق لأن الجهالة تكثر ولنا أنه عوض في عقد معاوضة فلم يصح مجهولا كثمن المبيع وتأول أبو بكر نص أحمد على أنه عين عبدا فأشكل عليه فإن أصدقها ما لا يجوز أن يكون صداقا لم يبطل النكاح ونقل المروذي عن أحمد إذا تزوج على مال بعينه غير طيب أنه كرهه ه وأعجبه استقبال النكاح وهذا يدل على أن النكاح لا يصح اختاره أبو بكر لأنه عقد معاوضة ففسد بفساد العوض كالبيع والأول أولى لأن فساده ليس بأكثر من عدمه وعدمه [ج ٣ - ص ٨٦]

لا يفسد العقد ويجب لها مهر المثل لأنها لم ترض إلا ببدله ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب رد بدله كما لو باعه سلعة بخمر فتلفت عند المشتري وعلى قول القاضي إذا أصدقها مجهولا وجب لها الوسط ووسط العبيد السندي فيجب ذلك لها وإن جاءها بقيمته لزم قبوله قياسا على الإبل في الدية

فصل

فإن أصدقها عبدا فخرج حرا أو مستحقا فلها قيمته لأن العقد وقع على التسمية لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا وقد تعذر تسليمه فكانت لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته وإن أصدقها مثليا فخرج مستحقا فلها مثله لأنه أقرب إليه ولذلك يضمن به في الإتلاف وإن أصدقها عصيرا فخرج خمرا فذكر القاضي أن لها قيمته لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال ويحتمل أن يلزمه مثل العصير المسمى لأنه مثلي فوجب إبداله بمثله كما لو أتلف ويفارق هذا ما إذا قال أصدقتك هذا الخمر أو هذا الحر لأنها رضيت بما لا قيمة له فأشبهت المفوضة ولم ترض هاهنا بذلك وإن قال أصدقتك هذا الخمر أشار إلى الخل أو هذا الحر وأشار إلى عبده صح ولها المشار إليه لأنه محل يصح العقد عليه فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته

لو ق ال أصدق تك ه ذا الأب يض وأش ار إ لى أس ود و إن تزوجها

على شيء فخرج معيبا فهي مخيرة بين أخذ أرشه وبين رده وأخذ قيمته أو مثله إن كان مثليا لما ذكرنا في أول الفصل

فصل

وإذا تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى ووجب مهر المثل لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم وإن كان بعد القبض برئت ذمته كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل فإن كان الصداق خنزيرين أو زقي خمر أو زق خمر وخنزيرا وقبضت أحدهما ففيه وجهان أحدهما يعتبر العدد لأنه لا قيمة له فكان الجميع واحدا فيقسط على عدده فيسقط نصف الصداق ويجب نصف مهر المثل والثاني يعتبر بقيمته عندهم أو بالكيل إن كان مكيلا لأنه أخصر

فصل

وإن تزوج امرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه صح لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين فإن لم يبع أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته لأنه تعذر تسليم المسمى فوجبت قيمته كما لو تلف وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح كذلك ومتى تعذر إعتاقه وجبت قيمته لما ذكرناه وفي المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطه فبذل قيمته لم [ج ٣ - ص ٨٨]

يلزمها قبوله لأن الحق ثبت لها في معين فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه كما لو قال أصدقتك هذا العبد وان تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح لأنه يصلح أن يكون عوضا في البيع ولا يلزمها قبول قيمته لأنها استحقت عبدا بعقد معاوضة فلم يلزمها قبول قيمته كالمبيع وعند القاضي يلزمها قبولها قياسا على الإبل في الدية

فصل

وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى لم يصح الصداق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صفحتها أوإنائها ولتنكح فإنما رزقها على الله رواه البخاري ومسلم وعنه يصح لأن لها فيه غرضا صحيحا أشبه عتق أبيها فإن فات طلاقها بموتها فقال أبو الخطاب قياس المذهب أن لها مهر الميتة لأن عوض طلاقها مهرها فأشبه قيمة العبد ويحتمل أن يجب مهر المثل لأن الطلاق لا قيمة له ولا مثل

فصل

وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا فالتسمية فاسدة لأنه في معنى بيعتين في بيعة وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كان له زوجة فقال أحمد تصح التسمية قال أبو بكر والقاضي في المسألتين جميعا روايتان جعلا نصه في احدى المسألتين رواية في [ج ٣ - ص ٨٩]

الأخرى لتماثلهما إحداهما فساد التسمية اختاره أبو بكر لأنه لم يعين العوض ففسد كبيعتين في بيعة والثانية يصح لأن الألف معلومة وإنما جهلت الثانية وهي معلقة على شرط فإن وجد كانت زيادة في الصداق والزيادة فيه صحيحة

فصل

فإن أصدقها تعليم شيء مباح كصناعة أو كتابة أو فقه أو حديث أو لغة أو شعر لها أو لغلامها صح لأنه أحد عوضي الإجارة فجاز صداقا كالأثمان فإن أصدقها تعليم شيء لا يحسنه نظرت فإن قال أحصل لك تعليمه صح لأنها منفعة في ذمته لا تختص به فأشبه ما لو أصدقها دينارا لا يقدر عليه وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح لأنه نعين بفعله وهو عاجز عنه وقال في المجرد يحتمل أن يصح لأنه يقع في ذمته فصح لما ذكرنا فإن تعلمتها من غيره أو تعذر عليه تعليمها فعليه أجرة تعليمها وإن أنته بغيرها ليعلمها مكانها لم يلزمه ذلك لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإبطائه ويحتمل أن يلزمه إذا أنته بمن يجري مجراها كمن اكترى شيئا جاز أن يوليه لمن يقوم مقامه وإن طلقها بعد الدخول قبل تعليمها ففيه وجهان أحدهما يعلمها من وراء حجاب كما يسمع الحديث من الأجنبية والثاني عليه أجرة التعليم لأنها صارت أجنبية فلا تؤمن من الفتنة عليهما في تعليمها أما

الحديث فإن الحاجة داعية إلى سماعه لأنه لا بدل له وإن كان قبل الدخول ففي تعليمه النصف الوجهان فإن طلقها بعد تعليمها رجع عليها بنصف أجرة التعليم

فصل

فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيء منه ففيه روايتان إحداهما يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن والثانية لا يجوز لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبه فلم يكن صداقا كتعليم الإيمان وقد روى النجاد بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا فإن قلنا بجوازه فأصدقها تعليم بعض القرآن فمن شرطه تعيين ذلك البعض لأن التعليم والمقاصد تختلف باختلافه وذكر أبو الخطاب وابن عقيل أنه إن كان في البلد قراءات افتقر إلى تعيين أحدها لأن حروف القرآن تختلف فأشبه تعيين الآيات والصحيح أنه لا يفتقر إليه لأنه اختلاف يسير وكل حرف ينوب مناب صاحبه فأشبه ما لو أصدقها قفيزا من صبره

فصل

ويصح أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا فإن أطلق ذكره كان حالا لأنه عوض في عقد معاوضة أشبه الثمن فإن شرطه مؤجلا إلى مدة

معلومة فهو إلى أجله وإن لم يذكر أجله فقال أبو الخطاب لا يصح ولها مهر المثل قياسا على الثمن في المبيع وقال القاضي يصح وهو ظاهر كلام أحمد لأنه قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولا فيما إذا تزوجها على مهر المثل فالتأجيل التابع له أولى فعلى هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره لأن المطلق يحمل على العرف والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة فحمل عند الإطلاق عليه

فصل

وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية فقال الخرقي يؤخذ بالعلانية لأن الزائد على صداق السر زياده زادها في الصداق وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة وقال القاضي الواجب مهر العقد الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية لأنه الذي انعقد به النكاح فكان الواجب المسمى فيه كما لو انفرد

فصل

وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة فإن زادها في صداقها شيئا بعد انبرام العقد جاز وكان الجميع صداقا لقوله تعالى ﴿ فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ [ج ٣ - ص ٩٢]

فصل

وإذا تزوج أربعا بصداق واحد صح لن جملة صداقهن معلوم فصح كما لو اشترى أربعة أعبد بثمن واحد ويقسم بينهن على قدر مهورهن كما يتقسط ثمن الأعبد على قيمتهم وقال أبو بكر يخرج فيه وجه آخر أنه يقسم بينهن على عددهن لأنه أضيف إليهن إضافة واحدة فأشبه ما لو أقر لهن وهذا القول فيما إذا خالعهن بعوض واحد أو كاتب عبده بعوض واحد

فصل

وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحا ومهر المثل في الموضع الذي يجب فيه لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك العوض به كالبيع وعنه رواية أخرى تدل على أنها لا تملك إلا نصفه لأنه لو طلقها لم يجب إلا نصفه والمذهب الأول فعلى هذا نماؤه وزيادته لها وزكاته عليها ونقصانه بعد قبضها إياه عليها وإن نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبضه فهو من ضمانه وإن لم يمنعها فنقص المكيل والموزون عليه لأنه يعتبر قبضه وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في المبيع قبل القبض سواء لأنه منتقل بعقد ينقل الملك فأشبه المبيع والثاني لها التصرف فيه لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالوصية

والميراث وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة زوجها صداقها قبل قبضه وهو تصرف

فصل

ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة وإلى من يلي مالها إن كانت غير رشيدة لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها وفي البكر البالغة العاقلة وجهان أحدهما لا يدفع الا إليها كذلك والثاني يجوز الدفع إلى أبيها لأنه العادة ولأنه يملك إجبارها على النكاح فأشبهت الصغيرة

فصل

ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع عن بذل الصداق فلا يمكن الرجوع فيه بخلاف المبيع ولها النفقة إذا امتنعت لأنه امتناع بحق فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع فقد توقف أحمد عن الجواب وذهب أبو عبد الله ابن بطة وأبو إسحاق بن شاقلا إلى أنه ليس لها ذلك لأنها سلمت تسليما استقر به العوض برضى المسلم فلم يكن لها المنع كما لو سلمت المبيع وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك لأنه تسليم بحكم عقد النكاح فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول فأما إن أكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع لأنه بغير

رضاها وإن قبضت صداقها فوجدته معيبا فردت فلها منع نفسها حتى يبذله لأن صداقها جيد وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع ففيه وجهان بناء على ما تقدم وإن كان صداقها مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه لأن رضاها بالتأجيل رضى منها بتسليم نفسها قبله كالثمن المؤجل وإن حل المؤجل قبلى تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقر فلم يسقط بحلوله

2 باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع 2

يستقر الصداق بثلاثة أمور أحدها الخلوة بعد العقد لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها كما لو وطئها فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها أو الزوج صغيرا أو أعمى لا يعلم دخولها عليه لم يكمل صداقها لأنه لم يحصل التمكين وكذلك إن نشزت عليه فمنعته وطأها لم يكمل صداقها لذلك ذكره ابن حامد وإن كان بهما عذر كالإحرام والصيام الواجب والمرض أو بأحدهما كالحيض والنفاس والرتق والجب والعنة [ج ٣ - ص ٩٥]

ففيه ثلاث روايات إحداهن يستقر الصداق لعموم ما ذكرنا ولأن التسليم المستحق قد وجد والمنع من غير جهتها فلم يؤثر في المهر كما لم يؤثر في إسقاط النفقة والثانية لا يستقر لأنه لا يتمكن من تسليمها فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها والثالثة إن كان المانع هو صوم رمضان لم يكمل الصداق وفي معناه ما يحرم دواعي الوطء كالإحرام وما لا يمنع دواعي الوطء كسائر الموانع لا يمنع استقرار الصداق

فصل

والثاني الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض كما لو اشترى طعاما فأكله وإن استمتع بغير الوطء كقبلة أو مباشرة دون الفرج أو نال منها ما لا يحل لغيره كالنظر إليها عريانة فقال أحمد يكمل الصداق به لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء وقال القاضي هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى لأنه لا يحرم المصاهرة فلم يقرر الصداق لرؤية الوجه

فصل

الثالث موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتله غيره لما روى معقل بن سنان أن [ج ٣ - ص ٩٦]

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة

ومتى استقر الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره

فصل

وإن افترقا قبل استقراره لم يخل من أربعة أقسام أحدها أن يكون بسبب من المرأة كردتها وإسلامها وإرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه وفسخها لعيب الزوج أو إعساره فيسقط مهرها لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه وفي معناه فسخ الزوج لعيبها لما مضى في موضعه الثاني أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها فيسقط نصف المسمى ويجب نصفه لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه وعن أحمد أنه إذا أسلم لا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب فكان من جهتها والأول المذهب لأن فسخ النكاح لاختلاف الدين [ج ٣ - ص ٩٧]

وذلك حاصل بإسلامه وإنما ينصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح به دونها وهو خلعه مع أجنبي فصار كالمنفرد به الثالث افترقا بسبب من أجنبي كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لأنه قرره عليه الرابع افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما ففيه روايتان وإن اشتراها زوجها ففيه وجهان أحدهما يسقط الصداق لأنها شاركت في الفسخ فسقط مهرها كالفسخ بعيب والثاني يتنصف لأن للزوج فيه اختيارا أشبه الخلع

فصل

ومتى سقط المهر أو نصفه بعد تسليمه إليها فله الرجوع عليها ولا يخلو إما أن يكون تالفا أو غير تالف فإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن لم يكن مثليا أقل ما كانت من حين العقد إلى حين القبض أو التمكين منه لأنه إن زاد بعد العقد فالزيادة لها وإن نقص فالنقص عليه فلم يرجع بما هو عليه وإن كان باقيا لم يخل من خمسة أحوال أحدها أن يكون باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حقا غيرها فإن الزوج يرجع فيه ويدخل في ملكه حكما وإن لم يجز ذلك كالميراث في قياس المذهب لقوله تعالى ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [ج ٣ - ص ٩٨]

فعلق تنصيفه بالطلاق وحده فيجب أن يتنصف به ويحتمل أن لا يملكه إلا باختياره لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا بالميراث فعلى هذا الوجه إن زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار فهو للزوجة لأن ملكها لم يزل عنه فنماؤها لها وعلى الأول نماء نصيب الزوج له لأنه نماء ملكه فإذا قال قد رجعت فيه أو اخترته ثبت الملك فيه على الوجهين وإن نقص في يدها بعد ثبوت ملكه عليه وكانت قد منعته منه فعليها ضمان نقصه لأن يدها عادية فتضمن كالغاصبة وإن لم تمنعه ففيه وجهان أصلهما الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به قال الزوج نقص قبل الطلاق فهو من ضمانك فأنكرته فالقول قولها لأن الأصل السلامة

فصل

الحال الثاني أن تجده ناقصا كعبد مرض أو نسي صناعته أو كبر كبرا ينقص قيمته فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصا لأنه يرضى بدون حقه وبين تركه ومطالبتها بقيمته أو نصفها يوم وقع العقد عليه لأن النقص حدث في ملكها فكان من ضمانها [ج ٣ - ص ٩٩]

فصل

الحال الثالث أن تجده زائدا فلا تخلو إما أن تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة واللبن والكسب ونحو ذلك فله نصف الأصل والزيادة لها لأنها زيادة متميزة حادثة من ملكها فلم تتبع الأصل في الرد كما في الرد بالعيب وإما أن تكون متصلة كالسمن والكبر والحمل في البطن والثمرة على الشجرة وتعلم صناعة أو كتابة ونحو ذلك فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه لأن حقه في نصف الفرض والزائد ليس بمفروض فوجب أخذ البدل إلا أن يكون محجورا عليها لسفه أو فلس أو صغر فليس له إلا نصف القيمة لأن الزيادة لها وليس لها التبرع بما لا يجب عليها وإن كانت مفلسة كان غريما بالقيمة وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه لأن عليه ضررا في بقاء الثمر عليها فلم يلزمه وإن قال الزوج أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمر عليه أو أترك الرجوع حتى تجذي ثمرتك ثم أرجع ففيه وجهان أحدهما لا تجبر على قبوله لأن الحق انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما والثانية تجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها وإن أصدقها أرضا فزرعتها فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء في قول القاضي وقال غيره

يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله لأن الزرع ينقص الأرض ويضعفها ولأنه ملكها أودعته في الأرض بخلاف الثمرة وإن أصدقها أرضا فبنتها أو ثوبا فصبغته فحكمها حكم الأرض المزروعة فإن بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ لتملكه فقال الخرقي يلزمها قبوله ويصير له نصف الجميع لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق فكان له تملكه بالقيمة كالشفيع والمعير وقال القاضي لا يملكه لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر

فصل

الحال الرابع وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه كعبد تعلم صناعة ومرض أو خشب شقته دفوفا أو حلي كسرته ثم صاغته على غير ما كان أو جارية حملت فإن الحمل نقص في الآدمية من وجه وزيادة من وجه بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة فهو كسمنها فإذا تراضيا على أخذ نصفه جاز لأن الحق لهما وأيهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه لأن عليه ضررا

الحال الخامس أن يتعلق به حق غيرهما وهو ثلاثة أنواع

أحدها ما يزيل ملكها كبيع العين وهبتها المقبوضة وعتقها ووقفها فحكم ذلك حكم تلفها فإن عادت العين إلى ملكها ثم طلقها فله الرجوع في

[ج ٣ - ص ١٠١]

نصفها لعدم المانع منه وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك كالرهن والكتابة

النوع الثاني ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض والوصية قبل الموت والتدبير فله الرجوع في نصفها لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة

النوع الثالث ما لا يزيل الملك كالنكاح والإجارة فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والإجارة وبين الرجوع بنصف القيمة لأنه نقص رضي به فأشبه نقصها بهزالها

فصل

فإن كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ففيه روايتان إحداهما يرجع عليها بنصفه لأنه عاد إليه بعقد مستأنف فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته أجنبيا ثم وهبه الأجنبي للزوج والثانية لا يرجع عليها بشيء لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها وقلنا لا يرجع ثم فها هنا أولى وإن قلنا يرجع ثم خرج هاهنا وجهان أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق فأشبه العين والثاني لا يرجع لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك وإن أصدقها عينا فوهبتها له أو دينا فأبرأته منه ثم ارتدت قبل الدخول ففي رجوعه به عليها وجهان بناء على الرجوع في النصف بالطلاق وإن باع رجلا عبدا

أو أبرأه من ثمنه فوجد به المشتري عيبا فرده وطالبه بثمنه أو أمسكه وأراد أرشه فهل له ذلك على وجهين بناء على الروايتين في الصداق وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع هاهنا في نصف الباقي من العبد وإن قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي جميعه

فصل

والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الأمر في ماله برىء منه صاحبه وكمل له الصداق جميعه وعنه ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة ثم قال تعالى ﴿ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي مالها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج والمذهب الأول قال أبو حفص ما أرى القول الآخر إلا قولا قديما ولا يجوز عفو الأب ولا غيره من الأولياء لما روى عمرو بن [ج ٣ - ص ١٠٣]

شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني ولأن الله تعالى قال ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴾ وليس عفو الولي عن صداق ابنته أقرب للتقوى ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ﴾ ولأن صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة فكذلك ولي الصغيرة

2 باب الحكم في المفوضة 2

وهو أن يزوج الرجل ابنته بغير صداق برضاها أو رضى أبيها سواء سكتا عن ذكره أو شرطا نفيه فالعقد صحيح لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا

ولم أعطها شيئا فإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود ويجب لها مهر نسائها بالعقد لأنه لم لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرضه قبله ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده ويلزمه إجابتها إليه فإن ترافعا إلى الحاكم لم يفرض إلا مهر المثل لأنه الواجب لها وإن تراضى الزوجان على فرضه جاز فإن فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره لأنه الواجب لها وإن فرض لها الحاكم أكثر منه جاز لأن له أن يزيدها في صداقها وان فرض لها أقل منه فرضيته جاز لأن الحق لها فملكت تنقيصه وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول وقراره بالدخول وغيره لأنه مهر مفروض فأشبه المفروض بالعقد وإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر امثل لأن الوطء في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب لما روى علقمة أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة منا مثل ما قضيت أخرجه أبو داود والترمذي

وقال حديث حسن صحيح وعن أحمد لا يكمل لها الصداق لأنها فرقة قبل فرض ومسيس فأشبهت الطلاق فعلى هذا يجب لها نصف مهر المثل

فصل

ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها ويعتبر الأقرب فالأقرب منهن فأقربهن الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بنات الأعمام ثم من بعدهن الأقرب فالأقرب ولا يعتبر ذوات الأرحام كالأم والخالة والأخت من الأم في إحدى الروايتين لأن المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن والأخرى يعتبر لأنهن من نسائها فيدخلن في الخبر فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين ويعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها وبلدها وعقلها وعفتها وجمالها ويسارها وبكارتها وثيوبتها لأنه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات فإن لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الأمور لم تعتبرها وإن كان يختلف فلم نجد إلا دونها زيد لها بقدر فضيلتها وإن لم يوجد إلا أعلى منها نقصت بقدر نقيصتها ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات فإن كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان أحدهما يفرض مؤجلا لأنه مهر نسائها والثاني يفرض حالا لأنه قيمة متلف وإن كان عادتهم انهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا وإذا زوجوا غيرهم ثقلوا [ج ٣ - ص ١٠٦]

أو عكس لك اعتبر لأنه مهر المثل فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل بلدها فإن عدم ذلك اعتبر أقرب الناس إليها من نساء اقرب البلدان إليها

فصل

وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة نص عليه أحمد في رواية جماعة وعنه لها نصف مهر المثل لانه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها والأول المذهب لقوله تعالى ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ﴾ ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها ولأنه حصل في مقابلة ابتذال المهر أو نصفه بخلاف مسألتنا وعنه لكل مطلقة متاع لقوله تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ﴾ وقال سبحانه ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ﴾ قال أبو بكر العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها فإنه لم يرو هذه إلا حنبل وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب [ج ٣ - ص ١٠٧]

جمعا بين دلالة الآيات المختلفات ولما ذكرنا من المعنى فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف لأن الآية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه

فصل

والمتعة معتبرة بحال الزوج ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ وحكى القاضي عن أحمد أنها مقدرة بنصف مهر المثل لأنها بدل عنه فتقدرت به والمذهب الأول لقوله تعالى ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل وفي قدرها روايتان إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة والثانية أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه

فصل

وكل فرقة أسقطت المسمى أسقطت المتعة وما نصفت المسمى أوجبت المتعة لأنها قائمة مقام نصف المسمى فاعتبر ذلك فيها وسئل أحمد

عن رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا ثم وهب لها غلاما ثم طلقها قال لها المتعة وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى

فصل

فأما المفوضة المهر وهي التي تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي أو بمهر فاسد أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنها فإنه يتنصف لها مهر المثل بالطلاق في ظاهر المذهب وهو اختيار الخرقي وعن أحمد ليس لها إلا المتعة لأنه نكاح خلا عن تسمية صحيحة فأشبه نكاح المفوضة البضع ولنا أنها لم ترض بغير صداق ولم يرض أبوها فلم تجب المتعة كالتي سمي لها بخلاف الراضية بغير صداق

فصل

وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا لأن عمر خطب الناس فقال ألا لا تغالوا في صدق النساء فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه أو بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وظاهره صحة تسمية من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قرشي ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود ولسي لغيره نقصها عن مهر نسائها إلا بإذنها لأنه متهم فإن زوج بغير صداق لم [ج ٣ - ص ١٠٩]

يكن تفويضا صحيحا لأنه اسقط ما ليس له التصرف فيه ويجب مهر المثل وإن فعله الأب كان تفويضا صحيحا

فصل

وللأب أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته لأن الله تعالى أخبر أن شعيبا زوج ابنته لموسى برعاية غنمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم قال الترمذي هذا حديث حسن فإن زوجها على ألف لها وألف له ثم طلقت قبل الدخول رجع الزوج بالألف التي لها لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقها فكأنها قبضته ثم وهبته لأبيها فإن شرط غير الأب شيئا لنفسه فالكل لها ولا شيء له لأنه عوض عنها فكان لها كالمسمى لها

فصل

وإن زوج الرجل ابنه الصغير فالمهر على الزوج لأنه المعوض له فكان العوض عليه كالكبير وكما لو اشترى له شيئا فإن كان الابن معسرا ففيه وجهان أحدهما هو عليه كذلك والثاني على الأب لأنه لما زوجه مع علمه بإعساره ووجوب الصداق عليه كان رضى منه بالتزامه [ج ٣ - ص ١١٠]

فصل

وإن تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر على المولى لأنه وجب بإذنه فكان عليه كالذي يجب بعقد الوكيل وإن تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه وإن دخل بها ففي رقبته صداقها لأنه وجب بجنايته فكان في رقبته كسائر جناياته وفي قدره روايتان إحداهما مهر مثلها لأنه وطء يوجب المهر فأوجب جميعه كوطء المكرهة والثانية يجب عليه خمسا المهر لما روى خلاس أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التيمي بغير إذن أبي موسى فكتب في ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فكتب إليه أن فرق بينهما وخذلها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة رواه أحمد ولأن المهر أحد موجبي الوطء فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد وقد روى حنبل عن أحمد أنه لا صداق عليه ويحتمل هذا أن يحمل على ما إذا فرق بينهما قبل الدخول ويحتمل أن لا يجب شيء في الحالين ولأن المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيح أشبه الزانية وهذا مذهب ابن عمر والمذهب الأول والسيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو الواجب من المهر كأرش جناياته وإذا زوج السيد عبده أمته وجب الصداق عليه ثم سقط لأن النكاح لا يخلو من مهر ولا يثبت للسيد [ج ٣ - ص ١١١]

على عبده مال فسقط وقال القاضي لا يثبت مهر أصلا لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده ثم باعها العبد أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة صح ويحول صداقها إلى ثمنه أو نصفه إن كان قبل الدخول وإن باعها إياه بصداقها صح لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر فكذلك هذا وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها فإن كان قبل الدخول رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها

2 باب اختلاف الزوجين في الصداق 2

إذا اختلفا في قدره ولا بينة على مبلغه ففيه روايتان إحداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما فإن ادعت مهر المثل أو أقل فالقول قولها وإن ادعى مهر مثلها أو أكثر فالقول قوله لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها ولأنه موجب العقد بدليل ما لو خلا عن الصداق فكان القول قول مدعيه كالمنكر في سائر الدعاوى فإن ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر من مهر المثل ردا إلى مهر المثل وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل وتحلف هي على إثبات ما نقص منه لأن دعوى كل واحد منهما محتملة فلا تدفع بغير يمين والرواية الثانية القول قول الزوج بكل حال [ج ٣ - ص ١١٢]

لأنه منكر فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه فإن مات الزوجان فورثتهما بمنزلتهما إلا أن من يحلف منهما على الإثبات يحلف على البت ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم لأنه يحلف على نفي فعل الغير وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة قام الأب مقامهما في اليمين لأنه يحلف على فعل نفسه فأشبه الوكيل فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة فاليمين عليهما دونه لأنه إنما حلف لتعذر اليمين من جهتهما فإذا أمكن الحلف منهما لزمهما كالوصي إذا بلغ الطفل

فصل

وإن أنكر الزوج تسمية الصداق وادعت تسمية مهر المثل وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدخول ففيه وجهان بناء على الروايتين فإن قلنا القول قول الزوج وجبت المتعة وإن قلنا بالرواية الأخرى فلها نصف مهر المثل وإن اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول فقد استقر لها مهر مثلها وإن كان قبله فلها المطالبة بفرض مهر المثل ولا يشرع التحالف وإن ادعت أكثر من مهر المثل حلف على نفي الزيادة [ج ٣ - ص ١١٣]

فصل

فإن قال أصدقتك هذا العبد قالت بل هذه الأمة لم تملك العبد لأنها لا تدعيه ولا الأمة لأنها لا تجب بمجرد الدعوى لكن إن قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد وإن قلنا القول قول من يدعي مهر المثل وكانت الأمة مهر المثل أو أقل حلفت ولها قيمتها وإن كانت أكثر والعبد مهر المثل أو أكثر حلف الزوج ولها قيمته وإن كانت الأمة أكثر والعبد أقل در إلى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم

فصل

وإن اختلفا في قبض الصداق أو إبرائه منه فالقول قولها لأن الأصل معها وإن اختلفا فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع أو الخلوة فالقول قوله لأن الأصل معه وإن اتفقا على أنه دفع إليها مالا فقال دفعته صداقا قالت بل هبه فإن كان الخلاف في نيته فالقول قوله بلا يمين لأنه أعلم بما نواه وإن اختلفا في لفظه فالقول قوله مع يمينه لأنه ملكه فالقول قوله في صفة نقله

فصل

وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فقالت حدث بعد الطلاق فلا ضمان علي وقال بل قبله فالقول قولها لأن الأصل براءة ذمتها

فصل

ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التي أنكحت نفسها بغير إذن وليها فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى ويجب للمكرهة على الزنى لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة والواطىء من أهل الضمان في حقها فأوجب المهر كالوطء بالشبهة ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذه المواضع لأنه داخل في المهر وعنه للمكرهة الأرش مع المهر لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها وعن أحمد لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة وعنه لا يجب لمحارمه من النسب لأن تحريمهن تحريم أصل فلا يوجب وطؤهن مهرا كاللواط وعنه من تحرم ابنتها لا مهر لها كذلك ومن تحل بنتها كالعمة والخالة يجب لها لأن تحريمها أخف ولنا أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة فأشبهت الأجنبية والبكر

فصل

ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنى لأنها باذلة لما يوجب البدل لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في قطع يدها فإن كانت أمة وجب المهر لسيدها لأنه المستحق له فلا يسقط ببذلها كيدها ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع بخلاف الفرج

فصل

ومن نكاحها باطل بالاجماع كذات الزوج والمعتدة حكمها حكم الأجنبية في وجوب الصداق إن كان الوطء بشبهة أو إكراه وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم لأنه باطل بالإجماع فكان وجوده كعدمه

2 باب الوليمة 2

وهي الإطعام في العرس وهي مستحبة لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشاة متفق عليه وليست واجبة لأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ويستحب أن يولم بشاة للخبر وإن أولم بغيرها أصاب السنة لما روى أنس قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة متفق عليه

فصل

وإجابة الداعي إليها واجبة لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وقال أبو هريرة ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواهما البخاري وإن كان الداعي ذميا لم تجب إجابته لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة ولا يجب ذلك للذمي وتجوز إجابته لما روى أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة [ج ٣ - ص ١١٦]

فأجابه رواه أحمد في الزهد وإنما تجب إجابة المسلم إذا نص عليه فإن دعا الجفلى كقوله أيها الناس أجيبوا وهلم إلى الطعام لم تجب الإجابة لأن كل واحد غير منصوص عليه فلا ينكسر قلب الداعي بتخلفه وإن دعا ثلاثة أيام وجبت الإجابة في اليوم الأول واستحب في الثاني ولم تستحب في الثالث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود فإن دعاه اثنان ولم يمكنه الجمع بينهما أجاب أسبقهما لان إجابته وجبت بدعوته فمنعت من وجوب إجابة الثاني فإن استويا أجاب أقربهما بابا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود فإن استويا أجاب أقربهما رحما فإن استويا أجاب أدينهما لأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني فإن استويا أقرع بينهما

فصل

وإذا دعي الصائم لم تسقط الإجابة فإذا حضر وكان الصوم واجبا لم يفطر وإن كان تطوعا استحب له الفطر ليسر أخاه ويجبر قلبه ولا يجب لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم وأبو داود ويستحب [ج ٣ - ص ١١٧]

إعلامهم بصيامه لأنه يروى عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره وإن كان مفطرا فالأفضل الأكل للخبر ولأن فيه جبر قلب الداعي ولا يجب لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك حديث صحيح

فصل

والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول لما روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود

فصل

وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر فأمكنه الإنكار حضر وأنكر لأنه يجمع بين واجبين وإن لم يمكنه لم يحضر لأنه يرى المنكر ويسمعه اختيارا وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه أزاله فإن لم تمكنه إزالته انصرف لما روى سفينة أن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معناه فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة الحقه فقل ما رجعك يا رسول الله فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا

مزوقا حديث حسن ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة فمنع منه كالقادر على إزالته وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه لم ينصرف لأنه لم يره ولم يسمعه ولا ينصرف لسماع الدف لأنه مشروع ولا لرؤية نقوش وصور غير الحيوان كالشجر والأبنية لأنه نقش مباح فهو كعلم الثوب وأما صور الحيوان فإن كانت توطأ أو يتكأ عليها كالبسط والوسائد فلا بأس بها وإن كانت على حيطان أو ستور انصرف لما روت عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير فلما رآه قال أتسترين الجدر بستر فيه تصاوير فهتكه قالت فجعلت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي فإن قطع رأس الصورة أو ما لا يبقى الحيوان بعده كصدر وظهر ذهبت الكراهة لأنه لا تبقى الحياة فيه فأشبه الشجر وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده كيد أو رجل فالكراهة بحالها لأنها صورة حيوان وإن سترت الحيطان بستور غير مصورة لحاجة من حر أو برد جاز ولم يكره لأنه يستعمله لحاجة فأشبه لبس الثياب وإن كان لغير حاجة ففيه وجهان أحدهما هو محرم لما روي عن علي بن الحسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر رواه الخلال والنهي يقتضي التحريم ودعا ابن عمر أبا أيوب فجاء فرأى البيت مستورا بنجاد أخضر فقال يا عبد الله [ج ٣ - ص ١١٩]

أتسترون الجدر لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج والثاني هو مكروه لأن ابن عمر أقر عليه ولم ينكر ولأن كراهته لما فيه من السرف فلا يبلغ به التحريم كالزيادة في الملبوس ويجوز الرجوع لذلك لفعل أبي أيوب

فصل

فأما سائر الدعوات غير الوليمة كدعوة الختان وتسمى الأعذار والعذيرة والخرس والخرسة عند الولادة والوكيرة دعوة البناء والنقيعة لقدوم الغائب والحذاق عند حذق الصبي والمأدبة اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب ففعلها مستحب لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة ولا تجب الإجابة إليها لما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعى إليه رواه الإمام أحمد وتستحب الإجابة لقوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس رواه أبو داود ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه

فصل

والنثار والتقاطه مباح لأنه نوع إباحة فأشبه تسبيل الماء والثمرة وفي كراهته روايتان إحداهما يكره وهي التي ذكرها الخرقي لما روي عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة وقال لا تحل النهبى رواه أحمد في المسند ولأن في التقاطه دناءة وقتالا وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه والثانية لا يكره اختارها أبو بكر لما روى عبد الله بن قرظ قال قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست بدنات فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من شاء اقتطع رواه أبو داود ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا لأن السلف كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما ومن وقع في حجره شيء من النثار فهو له لأنه مباح حصل في حجره فملكه كما لو وثبت سمكة فسقطت في حجره

2 باب عشرة النساء 2

يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف لقول الله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وقال سبحانه ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾ ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة للبذل ولا إتباعه بأذى ولا من وكف أذاه عن صاحبه ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم [ج ٣ - ص ١٢١]

فصل

وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلها فطلب تسليمها إليه وجب ذلك لأنه يطلب حقه الممكن فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة لأنه يسير جرت العادة بمثله وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها وإن كان لمرض غير مرجو الزوال أو لكونها نضوة الخلق وجب تسليمها لأن المقصود من مثلها الاستمتاع بغير الجماع وذلك ممكن في الحال وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا طلبها يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه وما لا فلا

فصل

ويجب تسليم الحرة ليلا ونهارا لأنه لا حق لغيره عليها وللزوج السفر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار لأنها مملوكة عقد على أحد منفعتيها فلم يجب التسليم في وغير وقتها كالمستأجرة للخدمة في أحد الزمانين

فصل

وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس مسلمة كانت أو ذمية لأن إباحة الوطء يقف عليه وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة لأنه

واجب عليها وفي الذمية روايتان إحداهما لا يملك إجبارها عليه لأنه لا يجب عليها ولا يقف إباحة الوطء عليه والثانية يملك إجبارها لأن كمال الاستمتاع يقف عليه لكون النفس تعاف من لا تغتسل من جنابة وفي التنظف والاستحداد وجهان بناء على هاتين الروايتين قال القاضي له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل وتقليم الأظفار إذا طالت رواية واحدة وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته على وجهين لما ذكرنا وله منع المسلمة من كل محرم لأن الله منعها منه وليس له منع الذمية من يسير الخمر لأنها لا تعتقد تحريمه وله إجبارها على غسل فيها منه لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به وله منعها من السكر لأنه يجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن من جنايتها عليه

فصل

وله منعها من الخروج من منزله إلا لما لا بد لها منه لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب وقد روي عن ابن عمر قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال حقه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديها أو شهود جنازته لأنه يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق

فصل

وله الاستمتاع بها في كل وقت من غير إضرار بها ولا منعها من فريضة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع متفق عليه ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر لقوله تعالى ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ وروى خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد رواهما الأثرم ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة وكيف شاء لقوله تعالى ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ قال جابر من بين يديها ومن خلفها غير ألا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه

فصل

وإذا أراد الجماع استحب أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عليه [ج ٣ - ص ١٢٤]

ويستحب التستر عند المجامعة لما روى عتبة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجه ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان أو يسمع وجسهما وإذا فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم اذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى نقضي حاجتها

فصل

ويكره العزل وهو أن ينزل الماء خارج الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع المرأة من كمال استمتاعها وليس بمحرم لما روى أبو سعيد قال ذكر يعني العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل فإنه ليس نفس مخلوقة إلا والله خالقها متفق عليه فإن كان ذلك في أمته فله ذلك بغير إذنها لأن الاستمتاع بها حق له دونها وكذلك أم الولد وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا بإذنها لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وإن كانت أمة فقال أصحابنا لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها لأن الولد له والأولى جوازه لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرها ولأن السيد لا حق له في الوطء فلا يجب استئذانه [ج ٣ - ص ١٢٥]

في كيفيته ولأن على الزوج ضررا في رق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحبا غير واجب لأن حقهما في الوطء لا في الإنزال بدليل خروجه بذلك من الفيئة والعنة

فصل

وإذا كان له زوجتان لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما لأن عليهما فيه ضررا ويؤدي إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأن فيه دناءة وسوء عشرة وإثارة للغيرة

2 باب القسم 2

يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع ووطؤها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر وقال القاضي لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه لأنه حق فجاز تركه كسكنى الدار المستأجرة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قال بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا متفق عليه وقال عمر لكعب ابن سور اقض بين هذا وامرأته قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن

فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة ولأن الوطء يجب على المولى ويفسخ النكاح لتركه وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة فإن لم يفعل فطلبت الفرقة فرق بينهما قال أصحابنا وحق الأمة ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة لأن زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا

فصل

فإن كانت له امرأتان أو أكثر وجب التسوية بينهن في القسم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داود ولأن الجور يحل بالعشرة بالمعروف وليس له البداءة في القسم بإحداهما دون الأخرى من غير رضاها لأنه جور يدعو إلى النفور فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها لزمه القضاء للبواقي لأن ترك القضاء ميل [ج ٣ - ص ١٢٧]

فصل

ويجب القسم على المريض والمحبوب والمظاهر والمولي وزوج المريضة والمحرمة والحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في مرضه ولأن القسم يراد للأنس والإيواء وذلك أحصل في هذه الأحوال فأما المجنون والمجنونة فإن خيف منهما سقط القسم لأن الأنس لا يحصل منهما وإن لم يخف منهما فالمجنونه على حقها من القسم ويطوف ولي المجنون به لأن الأنس يحصل منهما

فصل

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقط حقها من القسم والنفقة لأنها منعته القسم لها بغيبتها فأسقطت نفقتها بنشوزها وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم لأن ذلك حاصل بفعله فلم يسقط حقها كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه أشبه مالو سافرت معه الثاني يسقط اختاره الخرقي لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا لأنه لو سافر عنها [ج ٣ - ص ١٢٨]

لعذر سقط حقها منه فإذا سافرت هي كان أولى وفي النفقة وجهان لأنها لا تسقط بسفره

فصل

وعماد القسم الليل لقوله تعالى ﴿ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ﴾ ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار لأن نهاره كليل غيره وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه وقالت عائشة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق فإن زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن لأنه إذا بات عند واحدة تعينت الليلة الثانية للأخرى فلم يجز أن يبيتها عند غيرها بغير رضاها فإن اتفق الجميع على القسم أكثر من ذلك أو أقل جاز لان الحق لا يخرج عنهن وقال القاضي له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا لأنه يسير ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم لأنه فوت حقها الواجب لها فإن عادت بعد ذلك إليه لزمه أن يقضي لها لأنه قدر على [ج ٣ - ص ١٢٩]

إيفائه بعد العجز عنه فلزمه كالدين إذا أعسر به ثم أيسر وإن نشزت إحداهن في ليلتها وأغلقت بابها دونه أو ادعت طلاقه سقط حقها من القسم فإن طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقض لها لأنها أسقطت حق نفسها

فصل

والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة لأن المرأة تابعة للزوج في المكان ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن مثلها فهي على حقها من القسم وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته لأن عليها ضررا وإن كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما فلا يسقط بتباعدهما كالنفقة فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لأنه لم يقسم لها وإن أقام عندها لزمه القضاء للأخرى

فصل

يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع لأنه أكمل ولا يجب

ذلك لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية فيه قال الله تعالى ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ قال ابن عباس في الحب والجماع وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الترمذي وابن ماجه

فصل

وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقض لها لأنه لا فائدة في قضائه وإن أقام قضى لها سواء كانت إقامته لعذر أو لغير عذر لأن حقها فات بغيبته عنها ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه لأنه أقرب إلى المماثلة وإن قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لعدم المماثلة والثاني يجوز لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم وله الخروج في النهار كيف شاء لأن النهار للمعاش والانتشار وإن دخل على ضرتها في ليلتها ولم يلبث أن خرج لم يقض لعدم الفائدة في قضائه فإن جامعها فيه ففيه وجهان أحدهما لا يقضي أيضا لأن الزمن اليسير لا يقضى والوطء لا يستحق في القسم والثاني عليه القضاء وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأها ليعدل بينهما وإن أطال المقام عند الضرة قضاه من ليلة المدخول عليها بكل [ج ٣ - ص ١٣١]

حال فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج فيه وجهان أحدهما يجوز لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع والثاني لا يجوز لأنه يحصل به السكن أشبه الجماع وإن أطال قضاه للأخرى وإن جامع ففيه وجهان كما ذكرنا في الليل

فصل

والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه كالنفقة والسكنى فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة لما روي عن علي أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين أخرجه الدارقطني واحتج به أحمد فإن أعتقت الأمة في مدتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى لأنها صارت حرة فيجب التسوية بينهما وإن أعتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقض لها

فصل

إذا كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم أخرى فلم يقسم لها وقسم للاثنتين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة فإنه

يقسم لها ثلاثا وللناشر ليلة خمسة أدوار فيكمل للمظلومة خمسة عشر ويحصل للناشز خمس فتحصل التسوية فإن كان له ثلاث نسوة فظلم إحداهن وقسم بين الباقيتين ثلاثين ليلة ثم تزوج جديدة وأراد القضاء فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد ثم يقسم بينهما وبين المظلومة خمسة أدوار كما ذكرنا في التي قبلها سواء

فصل

ولا قسم عليه في ملك اليمين فإذا كانت له زوجات وإماء فله الدخول على الإماء كيف شاء والاستمتاع بهن لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لم تملك المطالبة في الإيلاء

فصل

وللمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها فيجعله لمن شاء من زوجاته ولبعض ضرائرها أو لهن جميعا إذا رضي الزوج لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه فإذا رضي جاز لما روت عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه ويجوز ذلك في بعض الزمان لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنت حيي في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يومي قالت نعم

فأخذت خمارا مصبوغا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول [ج ٣ - ص ١٣٣]

الله صلى الله عليه وسلم إليك يا عائشة إنه ليس يومك قالت ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها رواه ابن ماجه ولا يعتبر رضى الموهوبة لأنه حقه عليها عام وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة لم تجز الموالاة بينهما لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة فلم يجز تغييرها عن موضعها كما لو كانت الواهبة باقية ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل لأنه لم يقبض وما مضى فقد اتصل به القبض فلا حق لها فيه وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح لأنها ليست مالا ولا منفعة يستحق بها المال وإن كان العوض غير المال كإرضاء زوجها ونحو ذلك جاز لحديث عائشة

فصل

والحق في قسم الأمة لها دون سيدها فلها هبة ليلتها بغير إذن سيدها ولها المطالبة بها لأن الإيواء والسكنى حق لها فملكت إسقاطه والمطالبة به كالحرة

فصل

وإن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدور لحق الجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم

دار لما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل ثم قضى جميعها للبواقي لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وفي لفظ وإن شئت ثلثت ثم درت والأحرار والرقيق سواء في هذه الآية للإيناس وإزالة الاحتشام فاستوين فيه لاستوائهن في الحاجة إليه كالنفقة

فصل

يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش فإن فعل بدأ بالتي تدخل عليه أولا فوفاها حقها لأنها أسبق فإن أدخلتا عليه معا أقرع بينهما فقدم من تخرج لها القرعة ثم ثنى بصاحبتها ثم قسم بعد ذلك

فصل

وإذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر وإن أراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن إلا بقرعة لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها

معه متفق عليه ولا يلزمه القضاء للحاضرات لأن عائشة لم تذكر قضاء ولأن

[ج ٣ - ص ١٣٥]

المسافرة اختصت بمشقة السفر فاختصت بالقسم والسفر الطويل والقصير سواء في هذا لعموم الخبر والمعنى وإن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للبواقي لأنه خصها مدة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء كالحاضر فإن خرجت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه سقط حقها لامتناعها وإن آثرت أخرى به جاز إذا رضي الزوج لأن الحق لها أشبه ليلتها في الحضر وان أحب تركها والسفر وحده جاز لأن القرعة لا توجب وإنما تعين مستحق التقديم وان سافر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفر فله استصحابها معه لانه سفر واحد وإن أقام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة قضى ذلك فإذا خرج مسافرا لم يقض ما سافره لأنه سفر واحد قد أقرع له وإن كانت عنده امرأتان فتزوج امرأتين ثم أراد سفرا أقرع بين الكل فإن وقعت القرعة لإحدى الأوليين سافر بها فإذا قدم قضى حق العقد للجديدتين ثم دار وإن وقعت للجديدة سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم قضى حق العقد للأخرى ثم دار لأنه حق وجب عليه قبل سفره ويحتمل ألا يقضي لها لأن الإيواء في الحضر أكثر منه في السفر فيحصل تفضيلها على التي سافر بها ويحتمل أن يقيم عند الأخرى لقضاء حق العقد لأنه حق وجب بالعقد ولم يوجد له مسقط فيجب قضاؤه ثم يقيم مثله عند التي سافر بها لئلا يفضل الحاضرة عليها فإن العدل يحصل بهذا فيكون أولى من إسقاط حق العقد بغير مسقط

وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معه أتمه في الحضر والله أعلم

[ج ٣ - ص ١٣٦]

2 باب النشوز 2

وهو نوعان أحدهما نشوز المرأة وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح فمتى ظهر منها أمارات النشوز مثل أن يدعوها فلا تجيبه أو تجيبه متكرهة متبرمة وعظها وخوفها الله تعالى وما يلحقها من الإثم والضرر بنشوزها من سقوط نفقتها وقسمها وإباحة ضربها وأذاها لقوله تعالى ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ﴾ ولا يجوز ضربها لأنه يجوز أن يكون ذلك لعذر أو ضيق صدر من غير الزوج فإن أظهرت النشوز فله هجرها في المضاجع لقوله تعالى ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أو قال ثلاث ليال متفق عليه فإن ردعها ذلك وإلا فله ضربها لقوله تعالى ﴿ واضربوهن ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح رواه مسلم ولا يبرح بالضرب للخبر قال ثعلب غير مبرح أي غير شديد وعليه اجتناب المواضع المخوفة والمستحسنة لأن المقصود التأديب لا الإتلاف والتشويه وهل له ضربها بأول النشوز فعنه له ذلك [ج ٣ - ص ١٣٧]

للآية والخبر ولأنها صرحت بالمعصية فكان له ضربها كالمصرة وظاهر قول الخرقي أنه ليس له ضربها لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن المعصية في المستقبل فيبدأ بالأسهل فالأسهل كإخراج من هجم على منزله ولأنها عقوبات على جرائم فاختلفت باختلافها كعقوبات المحاربين

فصل

النوع الثاني نشوز الرجل عن امرأته وهو إعراضه عنها لرغبته عنها لمرضها أو كبرها أو غيرهما فلا بأس أن تضع عنه بعض حقها تسترضيه بذلك لقوله تعالى ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ﴾ قالت عائشة رضي الله عنها هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها تقول له أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي رواه البخاري وقالت عائشة إن سودة لما أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها ففي تلك وأشباهها أراه أنزل الله ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ﴾ رواه أبو داود ومتى صالحته على شيء من حقها ثم أرادت الرجوع فلها ذلك قال أحمد في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم فتقول قد رضيت فهو جائز وإن شاءت رجعت [ج ٣ - ص ١٣٨]

فصل

وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما الإنصاف فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره أو الاصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره لقوله تعالى ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين لأنهما إما وكيلان أو حكمان وأي ذلك كان فلا تشترط له القرابة والأولى جعلهما من أهلهما للآية ولأنهما أعرف بالحال وأشفق ويجب أن يكونا ذكرين عدلين لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق ولا يكمل بدون هذين الوصفين وإن كانا حكمين فهذا شرط فيه واختلف الرواية فيهما فروي أنهما حكمان لتسمية الله تعالى إياهما بذلك فعلى هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضى الخصم وروي أنهما وكيلان لا يملكان التفريق ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلم يجز إلا بإذنهما ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين لأنهما من شرائط الحكم وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين لأن توكيلهما جائز وقال القاضي لا يجوز أن [ج ٣ - ص ١٣٩]

يكونا عبدين لأنهما ناقصان فإن غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما إن قلنا هما وكيلان كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل وإن قلنا هما حكمان لم ينفذ لأنه لا يجوز له الحكم للغائب وكل واحد منهما محكوم له وعليه وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل [ج ٣ - ص ١٤٠]

ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض فإن خالعها بغير عوض لم يصح لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي ولم يقع به شيء وعنه يصح الخلع بغير عوض اختاره الخرقي فإذا سألته خلعها فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له لأنه فرقة فجازت بغير عوض كالطلاق فإن قال خلعتك من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا وكان كناية في الطلاق لا غير قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة ووجه الرواية الاولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب فلم يملكه الزوج كما لو لم تسأله المرأة

فصل

والخلع على ثلاثة أضرب مباح وهو أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه لقوله تعالى ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [ج ٣ - ص ١٤١]

وروى البخاري بإسناده قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إليها إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك كشراء المتاع

الثاني المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة لقوله تعالى ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ووجه ذلك قوله تعالى ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أبو داود ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الربا

الثالث أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه فهذا محرم لقوله تعالى ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في البيع ويقع الطلاق [ج ٣ - ص ١٤٢]

رجعيا وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا وإلا فالزوجية بحالها فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم لأنه ضربها بحق وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ والاستثناء من النفي إثبات وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا

فصل

ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج يصح طلاقه لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى والعوض في خلع العبد لسيده لأنه من كسبه لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه كسائر حقوقه وقال القاضي يصح قبضهما لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس ولا يصح من غير زوج لأنه لا يملك الطلاق إلا أب الصغير فإن فيه روايتين إحداهما لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه والثانية يملكه لأنه يملك تزويجه فملك الطلاق والخلع كالزوج وكذلك القول في زوجة عبده الصغير [ج ٣ - ص ١٤٣]

فصل

ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة لأن استدانتها صحيحة فإن كانت أمة فحكم خلعها حكم استدانتها بإذن سيدها وبغير إذنه ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا عتقت وعلى المفلسة إذا أيسرت كاستدانتها فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة فلا يصح بذل العوض منهن لأنه تصرف في المال وليس من أهله ويصح بذل العوض في الخلع من الأجنبي فإذا قال طلق زوجتك بألف علي ففعل لزمته الألف لأنه إسقاط حق لا يفتقر إلى رضى المسقط عنه فصح بالمالك والأجنبي كالعتق بمال فإن قال طلق زوجتك بمهرها وأنا ضامن ففعل بانت وعليه مهرها لا يرجع به على أحد وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها ولو كان أبا الصغيرة لأنه يسقط به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا وإلا لم يقع به شيء كالخلع مع العضل

فصل

ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي فلم يحتج إلى حاكم كالإقالة ويجوز في الحيض لأنه تحريم الطلاق فيه يثبت دفعا لضرر تطويل العدة والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة وهو أعظم وأدوم فكان دفعه أولى [ج ٣ - ص ١٤٤]

فصل

وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية لأنه أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق فالصريح ثلاثة ألفاظ خالعتك لأنه يثبت له عرف الاستعمال وفاديتك لورود القرآن به وفسخت نكاحك لأنه حقيقة فيه وما عدا هذا مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك فكناية فمتى أتى بالصريح وقع وإن لم ينو ولا يقع بالكناية إلا بنية أو دلالة حال بأن تطلب الخلع وتبذل العوض فيجيبها بذلك لأن دلالة الحال تعني عن النية ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق بائن لأنه لا يحتمل غير الطلاق وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق ففيه روايتان إحداهما هو طلاق أيضا لأنه كناية في الطلاق نوى به فرقتها فكان طلاقا كما لو نوى به الطلاق والثانية هو فسخ لقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ ثم ذكر الخلع ثم قال ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ فلو كان طلاقا كانت أربعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يكن طلاقا كغيره من الكنايات فإذا قلنا هو طلاق نقص به عدد طلاقها ومتى خالعها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن قلنا هو فسخ لم ينقص به عدد طلاقها وحلت له من غير نكاح زوج ثان ولو خالعها مرارا [ج ٣ - ص ١٤٥]

فصل

وتبين بالخلع على كلتا الروايتين فلا يملك رجعتها لأنه عقد معاوضة فلم يملك الرجوع فيما اعتاض عنه كالبيع ولا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن فلم يلحقها طلاقه كبعد العدة فإن طلقها بعوض وشرط الرجعة فقال ابن حامد يصح الخلع ويسقط الشرط لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسد فلم يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح قال القاضي ويسقط المسمى وله صداقها لأنه إنما رضي به مع الشرط فإذا فسد الشرط وجب أن يرجع بما نقص لأجله فيصير مجهولا فيفسد ويجب الصداق ويحتمل أن يجب المسمى لأنه مسمى صحيح في عقد صحيح فوجب قياسا على الصداق في النكاح وفيه وجه آخر أنه يسقط العوض وتثبت الرجعة لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان فيسقطان ويبقى مجرد الطلاق وإن شرط الخيار في الخلع بطل الشرط وصح الخلع لأن الخيار في البيع لا يمنع نقل الملك ففي الخلع لا يمنع وقوعه ومتى وقع فلا سبيل إلى رفعه

فصل

ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ومعلقا على شرط لما فيه من الطلاق فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض فيقول خلعتك بألف أو طلقتك بألف أو أنت طالق بألف [ج ٣ - ص ١٤٦]

فتقول قبلت كما يقول بعتك هذا الثوب بألف فتقول قبلت هذا قول القاضي وقياس قول أحمد أنه يقع الطلاق رجعيا ولا شيء له لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه ولم يعلقه بشرط وجعل عليها عوضا لم تبذله ولم ترض به فلم يلزمها فأما المعاوضة الصحيحة فمثل أن تقول المرأة اخلعني بألف أو طلقني بألف أو على ألف أو وعلي ألف فيقول طلقتك كما تقول بعني هذا الثوب بألف فيقول بعتك ولا يحتاج إلى ذكر إعادة الألف في الجواب لأن الإطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور ويجوز للرجل الرجوع في الإيجاب قبل القبول وللمرأة الرجوع في السؤال قبل الجواب كما يجوز في البيع وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال أو ضمانه فيقول إن أعطيتني ألفا أو إذا أعطيتني ألفا أو متى أعطيتني ألفا أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فمتى ضمنتها له أو أعطته ألفا طلقت سواء كان على الفور أوالتراخي لأنه تعليق للطلاق على شرط فوقع بوجود الشرط كما لو عري عن ذكر العوض ويكفي في العطية أن يحضر المال ويأذن في قبضه أخذ أو لم يأخذ لأن اسم العطية يقع عليه يقال أعطيته فلم يأخذ فإن أعطته بعض الألف لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط وإن قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء لأنه علق على المشيئة فلم [ج ٣ - ص ١٤٧]

يقع إلا بها وسواء شاءت على الفور أو التراخي نص عليه لأنه جعل المشيئة شرطا فأشبه تعليقه على دخول الدار

فصل

فإذا قال أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له لأنه لم يجعل الألف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها إنما عطفه على الطلاق الذي يملك إيقاعه فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه وإن قال أنت طالق على ألف أو على أن عليك ألفا فعن أحمد فيها مثل ذلك لأن على ليست حرف شرط ولا مقابله لهذا لا يصح أن تقول بعتك ثوبي على ألف وقال القاضي لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قوله تعالى في قصة شعيب ﴿ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ وقوله تعالى ﴿ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ﴾ فعلى هذا إذا قال أنت طالق على ألف أو بألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لم يقع لأنها لم تقبل ما بذله فأشبه ما لو قال بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال قبلت واحدا بثلث الألف وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث واستحق الألف لأنه علق الثلاث على بذلها للألف وقد وجد فإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين ووقعت الثالثة على [ج ٣ - ص ١٤٨]

قبولها ولو لم يبق من طلاقها إلا طلقة فقال أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا وإن قال الأولى بألف استحق الألف إذا قبلت

فصل

وإذا قالت طلقني بألف فقال خلعتك ينوي به الطلاق أو قلنا الخلع طلاق استحق الألف لأنه طلقها وإن لم ينو الطلاق وقلنا ليس بطلاق لم يستحق العوض لأنها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه فلم يجبها إليه ويكون كالخلع بغير عوض ويحتمل أن لا يقع بها شيء لأنه إنما بذل خلعها بعوض فلم يحصل فلم يقع وإن قالت اخلعني بألف فقال طلقتك بألف وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان أحدهما له الالف لان الطلاق بعوض نوع من الخلع ولأنها استدعت فرقة لا ينقص عدد طلاقها فأتى بفرقة تنقص عدد طلاقها وهذا زيادة والثاني لا يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وقعت رجعية ولا شيء له لأنه لم يجبها إلى ما سألت فإنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخر فلم يجبها إليه وإن لم يكن بقي من عدد طلاقها إلا واحدة استحق الألف علمت أو لم تعلم لأن القصد تحريمها قبل زوج آخر وقد حصل ذلك وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا طلقت ثلاثا

وله الألف لأنه حصل ما طلبته وزيادة وإن قالت طلقني عشرا بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف في قياس المسألة التي قبلها لأنه حصل المقصود وإن طلقها أقل من ذلك لم يستحق شيئا لأنه لم يجب سؤالها

فصل

فإن قالت طلقني بألف إلى شهر فقال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق استحق الألف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لأنه بعوض وإن طلقها قبل رأس الشهر طلقت ولا شيء له نص عليه لأنه إخبار بإيقاع الطلاق من غير عوض وإن قالت لك علي ألف على أن تطلقني متى شئت من الآن إلى شهر فطلقها قبل رأس الشهر وقع الطلاق واستحق الألف لأنه أجابها إلى ما سألت وقال القاضي تبطل التسمية وله صداقها لأن زمن الطلاق مجهول

فصل

وإن قالت إحدى زوجتيه طلقني وضرتي بألف ففعل صح الخلع فيهما لأن الخلع مع الأجنبي صحيح وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألت فلم يستحق ما بذلت كما لو قال في المناضلة من سبق بسهمين فله ألف فسبق أحدهما وقال القاضي تبين المطلقة وعلى [ج ٣ - ص ١٥٠]

الباذلة حصتها من الألف كما لو قال من رد عبدي فله الف فرد أحدهما وان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي بألف فكذلك سواء وقال القاضي إذا لم يف بشرطها فله الأقل من المسمى في صداقها أو الألف

فصل

وإن قال لزوجتيه أنتما طالقتان بألف فقبلتا طلقتا وتقسطت الألف بينهما على قدر صداقهما وعلى قول أبي بكر يكون بينهما نصفين كقوله فيما إذا تزوجهما بألف وإن قبلت إحداهما بانت ولزمتها حصتها من الألف وإن كانت إحداهما غير رشيدة فقبلتا بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الأخرى لأن بذلها للعوض غير صحيح وإن قال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا فهي كالتي قبلها إلا أن إحداهما إذا شاءت وحدها لم تطلق واحدة منهما لأن مشيئتهما معا شرط لطلاقهما فلا يوجد بدون شرطه فإن قالتا قد شئنا وإحداهما صغيرة أو مجنونة فكذلك لأن مشيئتهما غير صحيحة وإن كانت سفيهة طلقتا لأن مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة حصتها من العوض ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوض عليها لان بذلها غير صحيح [ج ٣ - ص ١٥١]

فصل

وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا وقال أبو بكر لا يأخذ أكثر مما أعطاها فإن فعل رد الزيادة والأول المذهب لقوله تعالى ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ وروت الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي وأجازه عثمان ولأنه عوض عن ملك منافع البضع أشبه الصداق ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجه وحكمه حكم الصداق في أنه إذا وجد به عيبا خير بين قيمته وأخذ أرشه وفي أنه إذا خالعها على عبد فبان حرا أو خلا فبان خمرا فله قيمة العبد ومثل الخل وإن خالعها بحر أو خمر يعلمانه وهما مسلمان فهو كالخلع بغير عوض لأنه رضي منها بما ليس بمال بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لم يرض بغير مال فرجع بحكم الغرور فإن كانا كافرين فأسلما أو تحاكما الينا بعد قبضه فلا شيء له لأن حكمه مضى قبل الإسلام فإن أسلما قبله فظاهر كلام الخرقي أنه يجب له عوض لأنه لم يرض بغير عوض فاشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا وقال القاضي في الجامع لا شيء له لأنه رضي بما ليس بمال فأشبه المسلم وقال في المجرد لها مهر المثل لأن العوض فاسد يرجع إلى قيمة المتلف [ج ٣ - ص ١٥٢]

وهو مهر المثل ويحتمل أن يجب لها قيمة الحر لو كان عبدا وقيمة الخمر عند الكفار لأنه رضي بمالية ذلك فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا

فصل

ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب وقال أبو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية وفيه مسائل خمس

أحدها أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم فإن كان في يدها دراهم فهي له وإن لم يكن فيها دارهم فله ثلاثة نص عليه أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم

الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز فهو كالوصية به وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها وكالوصية وقال القاضي وأصحابه له المسمى في صداقها لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها

الثالثة خالعها على دابة أو حيوان أو بعير أو ثوب ونحو ذلك أو قال إن أعطيتني دابة أو بعيرا أو بقرة فإنها تطلق ويملك ما أعطته [ج ٣ - ص ١٥٣]

من ذلك فإن اختلفا فيما يجب له فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد وفي قول القاضي وأصحابه يجب له صداقها ووجه القولين ما تقدم

الرابعة خالعها على عبد مطلق أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها قال أبو الخطاب نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته وقال القاضي له عبد وسط بناء على قوله في الصداق وقال أبو الخطاب يجب له صداقها ووجههما ما تقدم

الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها أو على ما تحمل أمتها أو على ما في بطن الأمة من الحمل أو ما في ضرع الشاة من اللبن أو على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له إن وجد منه شيء وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شي له لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء كما لو خالعها على ما ليس بمال فإذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض وقد قال أحمد إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها قيل له فإن حمل نخلها قال هذا أجود من ذاك قيل له يستقيم هذا قال نعم جائز قال القاضي قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه وقال وفي معنى هذا إذا خالعها على حكم أحدهما

أو حكم أجنبي أو على ما في يدها أو بيتها أو بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك وقال أبو الخطاب يرجع عليها [ج ٣ - ص ١٥٤]

بصداقها وقال ابن عقيل إن خالعها على حمل أمتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم

فصل

إذا قال إذا أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان أو معيبا قنا أو مدبرا لأن اسم العبد يقع عليه فقد وجد شرط الطلاق وإن دفعت إليه حرا لم تطلق لأنها لم تعطه عبدا ولم تملكه شيئا وإن دفعت إليه عبدا مغصوبا لم تطلق لأن معنى العطية هاهنا التمليك ولم تملكه شيئا وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فدفعته إليه فإذا هو حر أو مغصوب لم تطلق كذلك وعنه تطلق وله قيمته وإن خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء ذكره أبو الخطاب لأنه شرط لوقوع الطلاق فأشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه وقال القاضي له رده والرجوع بقيمته أو أخذ أرشه لأنها خالعته عليه أشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وقال فيما إذا قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق يلزمها عبد وسط كذلك وإن قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ونويا صنفا من الدراهم حمل العقد عليها وإن أطلقا حمل على نقد البلد كالبيع وإن لم يكن للبلد نقد غالب حمل على ما يقع عليه الاسم ولا يقع الطلاق بدفع ألف عددا ناقصة الوزن ولا تدفع نقره زنتها [ج ٣ - ص ١٥٥]

ألف لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا طلقت بوجود الفضة وإن نقصت عنها لم تطلق لأن الدراهم اسم للفضة

فصل

فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح وإن أطلق صح أيضا وينصرف إلى ما بقي من الحولين لأن الله تعالى قيده بحولين فينصرف الإطلاق إليه فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله كما ذكرنا في الإجارة فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما يثبت في ذمتها

فصل

ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالبيع فإن وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة عليه أو بصداقها عند الإطلاق

أو زيادة عليه صح ولزم المسمى لأنه امتثل أمره أو زاد خيرا وإن خالع بدونه ففيه وجهان أحدهما لا يصح اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص اختاره أبو بكر لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب كما لو لم يخالف وذكر القاضي وجهين آخرين أحدهما يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصا وبين رده وله الرجعة والثاني يسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن عين له جنس العوض فخالع بغيره أو خالع عند الإطلاق بغير نقد البلد أو بمحرم لم يصح لأنه خالف موكله في الجنس أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره فأما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر أو دونه أو بصداقهما عند الإطلاق أو دونه صح لأنه امتثل أو زاد خيرا وإن خالع بزيادة لم تلزمها لأنها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل لأنه التزمها للزوج وقال القاضي يلزمها مهر المثل

فصل

إذا ادعى الزوج خلعها فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بعوض في ذمته بانت بإقراره والقول قولها في نفي العوض مع يمينها لأنها منكرة وإن ادعته المرأة فأنكرها فالقول قوله ولا شيء عليه [ج ٣ - ص ١٥٧]

لأنه لا يدعيه وإن اتفقا على الخلع واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو صفته أو حلوله فالقول قول المرأة نص عليه لأن القول قولها في أصله فالقول قولها في صفته ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيها والقول قول المنكر وإن أقرت وقالت إنها في ضمان زيد لزمتها الألف ولم يلزم زيدا شيء إلا أن يقر به [ج ٣ - ص ١٥٨]

1 كتاب الطلاق 1

وهو على خمسة أضرب

واجب وهو طلاق المؤلي بعد التربص إذ أبي الفيئة وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه

ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وعنه أنه محرم لأنه يضر بنفسه وزوجته وقد قال عليه السلام لا ضر ولا ضرار

ومباح وهو عند الحاجة إليه لضرر بالمقام على النكاح فيباح له دفع الضرر عن نفسه

ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضرر عنها وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوه وعجزه عن إجبارها عليها أو كونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت فراشه وألحقت به ولدا من غيره [ج ٣ - ص ١٥٩]

وعنه أن الطلاق هاهنا واجب قال في مسألة إسماعيل بن سعيد هل يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن أخشى أن لا يجوز المقام معها وقال لا ينبغي له إمساك غير العفيفة

ومحظور وهو طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أصابها فيه ويسمى طلاق البدعة لمخالفته أمر الله تعالى في قوله ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ وروى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء متفق عليه ولأن طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضعه أم حائل فتعتد بالقرء ويحتمل أن يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولدها فأما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها لأنها لا عدة عليها تطول والصغيرة التي لا تحمل والآيسة لا يحرم طلاقهما لأنه لا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها لما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أخرجه مسلم ولأنه لا ريبة لها ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم لأنه على بصيرة من حملها [ج ٣ - ص ١٦٠]

فصل

ويقع الطلاق في زمن البدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجعة ولا يكون إلا بعد طلاق ويستحب ارتجاعها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق ولا يجب لأنه بمنزلة ابتداء النكاح أو استدامته وكلاهما غير واجب وعنه ان الرجعة واجبة لظاهر الأمر ومتى ارتجعها أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها قبل إصابتها لأن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق متفق عليه

فصل

والأولى أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لقول الله تعالى ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ إلى قوله ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ وهذا لا يمكن إذا جمع الثلاث وقال علي لو أن الناس أخذوا بما أمر الله تعالى من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها وهل يحرم جمع الثلاث فيه روايتان إحداهما يحرم لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة وروى [ج ٣ - ص ١٦١]

محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي ولأنه حرم بالقول امرأته لغير حاجة فحرم كالظهار والثانية لا يحرم لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات ولم ينقل إنكاره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النسوة ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لما روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال هو ما أردت فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي والدارقطني وأبو داود وقال الحديث صحيح فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى

فصل

ويملك الحر ثلاث تطليقات لقوله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وروى أبو رزين قال جاء رجل إلى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال قول الله تعالى ﴿ الطلاق مرتان ﴾ فأين الثالثة قال [ج ٣ - ص ١٦٢]

تسريح بإحسان ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة لما روي أن مكاتبا لأم سلمة طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين فأراد رجعتها فذهب إلى عثمان رضي الله عنه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فقالا حرمت عليك حرمت عليك والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك لأنه لم تكمل الحرية فيه

فصل

وإن طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه روايتان إحداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه استوفى عدد طلاقها فأشبه الحر إذا طلق ثلاثا والثانية له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك رواه النسائي وهو قول ابن عباس وجابر ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك رواه أبو داود والترمذي فلو قال إذا تزوجت فلانة أو امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر ولأنه حل لقيد النكاح قبله فلم يصح كما لو قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت

طالق ثم تزوجها وعن أحمد ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجها لأنه يصح تعليقه على الشرط فصح تعليقه على [ج ٣ - ص ١٦٣]

حدوث الملك كالوصية وأما الصبي العاقل ففيه روايتان إحداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ولأنه غير مكلف أشبه الطفل والثانية أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه اختاره الخرقي لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله أخرجه الترمذي ولأنه عاقل أشبه البالغ وأما الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو إكراه على شرب الخمر فلا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق فثبت في الثلاثة بالخبر وفي غيرهم بالقياس عليهم فأما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة ففيه روايتان إحداهما يقع طلاقه اختاره الخلال والقاضي لما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذا افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها ولأنه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي والثانية لا يقع طلاقه اختارها [ج ٣ - ص ١٦٤]

أبو بكر لأن ذلك قول عثمان صح ذلك عنه ولأنه زائل العقل أشبه المجنون وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ لأن تصحيح ما عليه إنما كان تغليظا عليه فيبقى في ماله على الأصل

فصل

فأما المكره على الطلاق بحق كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم عليه صح منه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعده به لا يمكن دفعه عنه الثاني أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن لم يفعل الثالث أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل كالقطع والقتل والحبس الطويل والإخراج من الديار وأخذ المال والإحراق بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار فأما من لا يغض ذلك منه والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره واختلف الرواية في نيله بشيء من العذاب هل يشترط في الإكراه أم لا فعنه هو شرط ولا يكون الوعيد بمجرده إكراها هذا الذي ذكره الخرقي ولأن عمر قال

ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو أوثقته ولأن الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به والثانية ليس بشرط وهو الصحيح لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه لكون الماضي لا يمكن دفعه وقد استويا في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع ولأن المهدد بالقتل إذا امتنع قتل فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه

فصل

وأما السفيه المبذر فيقع طلاقه لأنه زوج مكلف فيقع طلاقه كالرشيد والحجر إنما هو في ماله لا في غيره

فصل

وان قال العجمي لامرأته أنت طالق ولا يعلم معناه لم تطلق لأنه لم يختر الطلاق لعدم علمه بمعناه فإن نوى موجبه لم يقع لأنه لم يتحقق اختياره لما لا يعلمه فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها ويحتمل أن تطلق لأنه أتى بالطلاق ناويا مقتضاه فوقع كما لو علمه وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه

فصل

وإذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها أو عضوا منها كيدها وأصبعها طلقت لأنه لا يتبعض فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع

[ج ٣ - ص ١٦٦]

كالقصاص وإن اضافه إلى الشعر والسن والظفر لم يقع لأن هذه تزول ويخرج غيرها فلم يقع بإضافته إليها كالريق وان أضافه إلى الريق والدمع والعرق لم يقع لأنه ليس من ذاتها إنما هو مجاور لها وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع لأنه عرض ليس من ذاتها وإن أضافه إلى روحها فقال أبو بكر لا يقع لأنها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به ولا يحل العقد به وقال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها وروحها بها قوامها وان أضافه إلى الحمل لم يقع لأنه ليس من أعضائها وإنما هو مودع فيها

فصل

إذا قال لزوجته أنا منك طالق لم تطلق لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية فلم يقع بنية كالأجنبي ولأنه لو قال أنا طالق لم يقع به طلاق فكذلك إذا قال أنا منك طالق كالأجنبي وان قال أنا منك بائن أو بريء ففيه وجهان أحدهما لا يقع طلاقه لأنه لا يقع بإضافة صريحة إليه فكذلك كنايته والثاني يقع لأن البينونة والبراءة يوصف بها الرجل فيقال بان منها وبانت منه ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح إضافته إلى كل واحد منهما [ج ٣ - ص ١٦٧]

2 باب صريح الطلاق وكنايته 2

لا يقع الطلاق بمجرد النية لأنه إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق ولو قال أنت ونوى الطلاق وأشار بأصابعه لم يقع لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه ولا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه لانه موضوع له على الخصوص يثبت له عرف الشرع والاستعمال فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو يا مطلقة فهو صريح وذكر أبو بكر في قوله أنت مطلقة رواية أخرى أنه ليس بصريح لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا والمذهب الأول لأنه متصرف من لفظ الطلاق فكان صريحا كقوله طلقتك ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم كان صريحا لأن الجواب يرجع إلى السؤال فصار كالملفوظ به ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل لأنه محتمل وإن قال أنت الطلاق فهو صريح نص عليه لأنه لفظ بالطلاق وهو مستعمل في عرفهم قال الشاعر % فأنت الطلاق وأنت الطلاق % وأنت الطلاق ثلاثا تماما %

ويحتمل أن لا يكون صريحا لأنه وصفها بالمصدر وأخبر به عنها وهذا تجوز وفي لفظ الفراق والسراح وجهان أحدهما هو صريح اختاره

الخرقي لانه ورد في القرآن فهو كلفظ الطلاق والثاني ليس بصريح اختاره ابن حامد لأنه موضوع لغيره يكثر استعماله في غير الطلاق أشبه سائر كناياته وما عدا هذا فليس بصريح لانه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال وإن لطم زوجته وقال هذا طلاقك فهو صريح ذكره ابن حامد وذكر القاضي أنه منصوص أحمد لأنه أتى بلفظ الطلاق وكذلك على قياسه إن أطعمها وقال هذا طلاقك

فصل

وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه جادا كان أو هازلا لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي وقال حديث حسن وإذا أراد التلفظ بغير الطلاق فسبق لسانه إليه كأن أراد أنت طاهر فسبق لسانه إلى أنت طالق أو أراد فارقتك بقلبي أو ببدني أو سرحتك من يدي أو سرحت رأسك أو طلقتك من وثاقي لم تطلق لأنه عنى بلفظه ما يحتمله فوجب صرفه إليه فإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه محتمل فأما في الحكم فإن كان ذلك في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يقبل لانه يخالف الظاهر من وجهين مقتضى اللفظ أو ودلالة الحال وإن كان في غيرهما فظاهر كلام أحمد أنه يقبل لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير [ج ٣ - ص ١٦٩]

بعيد فقبل كما لو كرر لفظه الطلاق وأراد بالثانية التأكيد وعنه لا يقبل لأنه يخالف الظاهر فلم يقبل كما لو أقر بدرهم ثم فسره بدرهم صغير أو رديء وإن نطق بهذه الصلاة لم يقع الطلاق وجها واحدا لأنه وصل كلامه بما يغير مقتضاه فأشبه ما لو وصله بشرط أو قال له علي درهم صغير وإن قال طلقت زوجتي وقال أردت في نكاح غير هذا أو قال يا مطلقة وقال أردت من زوج قبلي دين في ذلك فأما في الحكم فإن لم يكن وجد لم يقبل لأنه لا يحتمله وإن كان وجد فهل يقبل على وجهين لما ذكرناه

فصل

وما عدا الصريح من الألفاظ قسمان أحدهما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله اقعدي واقربي وقومي وكلي واشربي وأطعميني واسقيني وما أحسنك وبارك الله عليك وأنت جميلة وأو قبيحة ونحو هذا فلا يقع به طلاق وإن نواه لأنه لا يحتمل الطلاق ولو أوقعناه لوقع بمجرد النية ولا سبيل إليه والثاني ما يشبه الطلاق ويدل على ما معناه فهو كناية فيه إن نوى به الطلاق وقع لأنه نوى بكلامه ما يحتمله وإن لم ينو شيئا ولا دلت عليه قرينة لم يقع لأنه ظاهر في غير الطلاق فلم يصرف إليه عند الإطلاق كما لا ينصرف الصريح إلى غيره [ج ٣ - ص ١٧٠]

وإن كان جوابا لسؤالها الطلاق وقع نص عليه لدلالة الحال عليه فإن الجواب مبني على السؤال فيصرف إليه كما لو قيل أطلقت فقال نعم وإن أتى بالكناية حال الخصومة والغضب ففيه روايتان إحداهما يقع الطلاق لأن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال ولذلك كان قول حسان % فما حملت من ناقة فوق رحلها % أبر وأوفى ذمة من محمد % مدحا جميلا وقول النجاشي % قبيلة لا يغدرون بذمة % ولا يظلمون الناس حبة خردل %

هجاء قبيحا مع استوائهما في الخبر عن الوفاء بالذمة لدلالة الحال عليه والثانية لا يقع لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فلم يقع به الطلاق كحال الرضى ويتخرج في جواب السؤال مثل ذلك ويحتمل التفريق بين الكنايات فيما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال لأنه أتى بما جرت العادة باستعماله بغير الطلاق كثيرا فلم يكن طلاقا كحال الرضى وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة إذا أتى في حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا لدلالة استعماله المخالف لعادته في خصوص هذه الحال على إرادة الفراق فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فالكناية أولى [ج ٣ - ص ١٧١]

فصل

والكنايات ثلاثة أقسام ظاهرة وخفية ومختلف فيها

فالظاهرة ستة ألفاظ خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأمرك بيدك وفيها روايتان إحداهما هي ثلاث وإن نوى واحدة لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا والثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة الذي قدمناه ولأنه أحد نوعي الطلاق فإذا نوى به واحدة لم يزد عليها كالصريح فإن لم ينو شيئا وقع ثلاثا وروى عنه حنبل أنه يقع به واحدة بائنة لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع

فأما الخفية فنحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وأغناك الله لقوله تعالى ﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾ وأشباه هذا فهذا يقع به ما نواه لأنه محتمل له وإن لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين

وأما المختلف فيها فالحقي بأهلك وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت واعتدي وغطي شعرك وأنت حرة وقد أعتقتك ولا سبيل لي عليك وأنت علي حرج ففيها روايتان إحداهما هي ظاهرة لأنها في [ج ٣ - ص ١٧٢]

معنى الظاهرة والأخرى هي خفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ابنة الجون قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك متفق عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا وقد نهى أمته عنه وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة اعتدي فجعلها طلقة متفق عليه وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك وحللت للأزواج وتقنعي ولا سلطان لي عليك فيخرج فيها وجهان

فصل

فإن قال أنت علي حرام ففيه ثلاث روايات إحداهن أنها ظهار نوى الطلاق أو لم ينوه ذكره الخرقي لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا كقوله أنت علي كظهر أمي والثانية هو كناية في الطلاق لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة ولأن الطلاق تحريم فصحت الكناية عنه بالحرام كقوله أنت الحرج فإن لم ينو الطلاق كان ظهارا فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهره فيها من الخلاف مثل ما تقدم والثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينا لأن ذلك يروى عن الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم ولأنه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الأمة وإن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق ففيه روايتان إحداهما أنه طلاق وهي المشهورة لأنه صريح

بلفظ الطلاق والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصر طلاقا لقوله أعني به الطلاق كقوله أنت علي كظهر أمي وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا ولم يقع به الطلاق لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في غيره ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لانه لا تصح الكنايه به وأن قال أنت علي كالميته والدم ونوى به الطلاق فهو طلاق لانه يشبه الطلاق فصح ان يكني به عنه وإن نوى الظهار كان ظهارا لأنه يشبهه وإن نوى اليمين كان يمينا لأنه يشبهها وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان أحدهما يكون ظهارا لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية

فصل

ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته لما روت عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ﴾ حتى بلغ ﴿ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ﴾ فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل [ج ٣ - ص ١٧٤]

ما فعلت متفق عليه وهو على ضربين أحدهما تفويضه بلفظ صريح فيقول طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها واحدة ليس لها أكثر منها لان الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم كما لو وكل فيه أجنبيا إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها ولها أن تطلق بلفظ الصريح والكناية مع النية لأن الجميع طلاق فيدخل في لفظه ولها أن تطلق متى شاءت لأنه توكيل في الطلاق مطلق فأشبه توكيل الأجنبي وقال القاضي يتقيد بالمجلس قياسا على التخيير الضرب الثاني تفويضه إليها بلفظ الكناية وهو نوعان أحدهما أن يقول أمرك بيدك فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت ومتى شاءت لأنه نوع توكيل بلفظ يقتضي العموم في جميع أمرها فأشبه ما لو قال طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت وقد روي عن علي في رجل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل وعن أحمد ما يدل على أنه إن نوى واحدة فهي واحدة لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيته كالتخيير النوع الثاني أن يقول لها اختاري فليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته كما ذكرنا في قوله طلقي نفسك وليس لها أن تختار إلا عقيب تخييره قبل أن يقطعا ذلك بالأخذ في كلام غيره أو قيام أحدهما عن مجلسه لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود

وجابر رضي الله عنهم ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول وإن جعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته أو قرينة فهو على ما جعل إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها قبل تطليقها لأنه نوع تفويض فملك الرجوع غليه كتوكيل الأجنبي وإن وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوعه عما جعل إليها

فصل

ولفظة الخيار وأمرك بيدك كناية في حق الزوج لأنه ليس بصريح في إرادة الطلاق فلم ينصرف إليه بغير نية وإن نوى به إيقاع الطلاق في الحال وقع لأنه يصلح كناية عن الطلاق فأشبه سائر كناياته وإن نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية وإن لم تختر شيئا لم يقع بها شيء وكذلك إن اختارت زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنه فلم يكن طلاقا قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا ولأنه تفويض للطلاق إليها فلم يقع به بمجرده طلاق كقوله طلقي نفسك وإن قالت قبلت فليس بشيء لأن ذلك ينصرف إلى قبول التفويض فهو كقبول التوكيل وإن قالت اخترت نفسي أو أهلي أو أبوي أو الأزواج أو ألا تدخل علي ونحو هذا مما يحتمل إرادة الطلاق [ج ٣ - ص ١٧٦]

فهوكناية يفتقر إلى النية لأنه ليس بصريح فاعتبرت النية فيه كالكنايات فإن نوت به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا ويقع به واحدة إلا أن ينوي الثلاث إذا جعل إليها ثلاثا وإن ملكها ثلاث تطليقات بلفظه أو بنيته فطلقت ثلاثا وقع ثلاثا وإن طلقت أقل منها وقع لأن من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج وإن قال اختاري فاختارت نفسها ونويا ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى أحدهما طلقة والآخر أكثر منها وقعت طلقة لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة فالزائد لم يوجد فيه إلا أحدهما فلم يقع

فصل

وإن قال لزوجته وهبتك لنفسك أو لأهلك فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع وإن لم ينو الإيقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج ومنهم لأنه ليس بصريح فإن نويا الطلاق دون العدد وقعت واحدة يملك الرجعة وإن نويا جميعا عددا وقع وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر وقع الأقل لاتفاقهما عليه وإن ردوها لم يقع شيء لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كقوله اختاري وإن باعها لغيره لم يقع به طلاق وإن نوى لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة والطلاق مجرد إسقاط [ج ٣ - ص ١٧٧]

فصل

ويصح تفويض الطلاق إلى غير الزوجة لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق فإذا قال لرجل طلق زوجتي أو أمرها بيدك فالحكم فيه كالحكم في جعل ذلك إلى الزوجة على ما مضى فإن وكل اثنين لم يملك أحدهما طلاقها منفردا وإن جعل إليهما طلاقا ثلاثا فطلقها أحدهما ثلاثا والآخر واحدة وقعت واحدة لاتفاقهما عليها ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها الوكيل ثلاثا وقعت الواحدة لأن المحل لا يتسع لأكثر من هذا

فصل

ولا يقع الطلاق بغير اللفظ إلا في موضعين أحدهما الأخرس إذا أشار بالطلاق وقع طلاقه لأنه يحتاج إلى الطلاق فقامت إشارته فيه مقام نطلق غيره كالنكاح ويقع من العدد ما أشار إليه لأن إشارته كلفظ غره وأما غير الاخرس فلا يقع الطلاق بإشارته لأنه لا ضرورة به إليها فلم يصح منه بها كالنكاح الثاني إذا كتب طلاق زوجته ونواه وقع لأنه حروف يفهم منها صريح الطلاق أشبه النطق وإن كتب صريح الطلاق من غير نية ففيه روايتان إحداهما يقع لذلك والثانية لا يقع لأن الكناية تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره فلم تطلق بمجردها كالكنايات وإن قصد [ج ٣ - ص ١٧٨]

بالكناية امتحان الخط أو غير الطلاق لم يقع لأنه لو قصد بالنطق غير الطلاق لم يقع فالكناية أولى وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم وعنه فيمن قصد تجويد الخط أنه يقع طلاقه لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق وإن ادعى إرادة ما ينفي وقوع الطلاق دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن كتبه بشيء لا يتبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع لأن الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع وقال أبو حفص يقع لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين

2 باب ما يختلف به عدد الطلاق 2

إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة لأن لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها والنية إنما تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته فإن قال أنت طالق واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها وكذلك إن قال أنت واحدة وإن قال أنت طالق ولم ينو عددا فهي واحدة وإن نوى ثلاثا أو اثنتين ففيه روايتان إحداهما لا يقع إلا واحدة لأن لفظه لا يتضمن عددا ولا [ج ٣ - ص ١٧٩]

بينونة فلم يقع به ثلاث كالتي قبلها والثانية يقع به ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله بدليل أنه يصح تفسيره به فأشبه الكناية وإن قال أنت طالق طلاقا أو الطلاق وقع ما نواه لأنه صرح بالمصدر وهو يقع على القليل والكثير وإن أطلق وقع بقوله أنت طالق طلاقا واحدة لأنه اليقين وفي قوله طالق الطلاق روايتان إحداهما تطلق ثلاثا لأن الألف واللام للاستغراق والثانية تقع واحدة لأن الألف واللام اشتهر استعمالها في الطلاق لغير الاستغراق كقوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإذا قال فارقتك لزمه الطلاق ومن أكره على الطلاق وكذلك في غيره من الأجناس كقوله اغسليه بالماء وعليك بالصعيد وتيمم بالتراب فيجب حمله على اليقين وهكذا إن قال أنت الطلاق أو الطلاق يلزمني أو لازم لي أو علي الطلاق أو أنت علي حرام أعني به الطلاق فالحكم فيه على ما ذكرنا وقد نص أحمد فيمن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق فإنه ثلاث ومن قال أعني به طلاقا فهي واحدة

فصل

وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو جميعه أو أكثره أو منتهاه طلقت ثلاثا لأن ذلك هو الطلاق الثلاث وإن قال أنت طالق كعدد الماء أو الريح أو التراب أو كألف طلقت ثلاثا لأنه يقتضي العدد [ج ٣ - ص ١٨٠]

فإن قال أنت طالق طلقة صعوبتها كألف قبل لأنه يحتمل ما قاله وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه طلقت واحدة لأن ذلك لا يقتضي عددا والطلقة الواحدة توصف بكونها ملء الدنيا ذكرها وإنها أشد الطلاق عليها لضررها بها فلم يقع الزائد بالشك فإن نوى ثلاثا وقعت لأن اللفظ يحتملها

فصل

وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها بمقتضى اللفظ وإن احتمل دخوله لم نوقعه بالشك وعنه تطلق ثلاثا لأن ما بعد إلى قد يدخل مع ما قبلها كقوله ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾

فصل

وإن قال أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى الثلاث وقع لأن في تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى ﴿ فادخلي في عبادي ﴾ وإن نوى واحدة لم يقع أكثر منها لأنه إنما أوقع واحدة وإن أطلق ولا يعرف الحساب وقعت واحدة فتطلق بقوله أنت طالق ولا يقع بقوله في ثنتين شيء لأنه لا يعرف مقتضاه ويحتمل أنه إن كان في عرفهم استعمال ذلك للثلاث

طلقت ثلاثا لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه فإن نوى موجبه في الحساب احتمل أن تكون نيته كعدمها قاله القاضي واحتمل أن تطلق طلقتين هذا قول ابن حامد ووجه القولين ما ذكرنا فيما إذا نوى العجمي بلفظ الطلاق موجبه عند العرب وإن كان يعرف الحساب وقع طلقتان لأن ذلك موجبه عندهم وإن لم ينو فقال أبو بكر يقع طلقتان لانه موضوعه عندهم ويحتمل أن تقع واحدة لما ذكرنا في غير الحاسب

فصل

فإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتين وقع طلقتان نص عليه لأن ما لفظ به بعد الإضراب يدخل فيه ما لفظ به قبله فلم يلزمه أكثر منه كما لو قال له علي درهم بل درهمان وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقة طلقت واحدة كما لو قال له علي درهم بل درهم وهكذا إن قال أنت طالق بل أنت طالق نص عليه ويحتمل أن يقطع طلقتان وإن نوى به طلقتين وقع طلقتان لأنه قصد إيقاع طلقتين بلفظين وإن قال أنت طالق بل هذه الأخرى طلقتا معا لأنه أوقعه بكل واحدة منهما فأشبه ما لو قال له علي هذا الدرهم بل هذا ولو قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا لأن التفسير يحصل [ج ٣ - ص ١٨٢]

بالإشارة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا فإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه لأنه يحتمله

فصل

وإذا طلقها جزءا من طلقة طلقت واحدة لأن ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر جميعه كما لو قال نصفك طالق وإن قال أنت طالق نصفي طلقة طلقت طلقة لأن ذلك طلقة وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين لأنه طلقة ونصف فكمل النصف بالسراية فتصير طلقتين وإن قال نصف طلقتين طلقت واحدة لأن نصف الطلقتين طلقة وإن قال أردت من كل واحدة جزءا طلقت طلقتين لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ وإن قال نصفي طلقتين وقعت طلقتان لأن نصفي الشيء كله وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا لأن نصف الطلقتين طلقة وقد كرره ثلاثا ويحتمل أن يقع طلقتان ويكون معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين وإن قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة لان هذه أجزاء طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا لأن عطف جزء الطلقة على جزء آخر يدل على المغايرة فيقع جزء من كل طلقة ثم يكمل بالسراية وإن قال أنت نصف طالق طلقت واحدة كما لو قال [ج ٣ - ص ١٨٣]

نصفك طالق وإن قال أنت نصف طلقة طلقت واحدة كما لو قال أنت الطلاق

فصل

فإن قال لأربع نسائه أوقعت بينكن أو عليكن طلقة طلقت كل واحدة طلقة لأن لكل واحدة ربع الطلقة ثم تكمل فإن قال طلقتين فكذلك عند أبي الخطاب لأنه إذا قسم لم تزد كل واحدة على طلقة وكذلك إن أوقع بينهن ثلاثا أو أربعا وإن أوقع بينهن خمسا طلقت كل واحدة طلقتين لأن لكل واحدة طلقة وربعا فيكمل الربع طلقة وروى الكوسج عن أحمد إذا قال أوقعت بينكن ثلاث طلقات ما أرى إلا قد بن منه فظاهره أنه قد أوقع بكل واحدة ثلاثا لأن نصيب كل واحدة من كل طلقة ربع ثم يكمل بالسراية وهذا قول أبي بكر والقاضي وعلى هذا يتفرع ما أشبهه

فصل

فإن قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص به عدد طلاقك أو لا شيء أو ليس بشيء طلقت لأنه أوقع الطلاق ثم وصفه بما لا يتصف به فلغت الصفة وبقي الطلاق بحاله وإن قال أنت طالق أو لا لم تطلق لأنه لم يوقعه وإنما استفهم عنه فلم يقع والله أعلم [ج ٣ - ص ١٨٤]

2 باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها 2

إذا قال أنت طالق أنت طالق لغير مدخول بها طلقت واحدة لأنها بانت بالاولى فلم يقع بها ما بعدها لأنه أوقعه على بائن وكذلك كل طلاق يترتب في الوقوع كقوله أنت طالق ثم طالق أو طالق فطالق أو طالق بل طالق وطالق أو طالق طلقة فطلقة أو طلقة قبل طلقة أوبعد طلقة أو بعدها طلقة لم يقع إلا واحدة كذلك وان قال أنت طالق طلقتين طلقت طلقتين لأنه أوقعهما معا في محل قابل لهما ولو قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين لأن لفظه يقتضي وقوعهما معا وكذلك لو قال أنت طالق وطالق طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب فأشبهت ما قبلها فإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك في قول أبي بكر لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى فوقعت معها وقال القاضي لا يقع إلا طلقة لأنه أوقعهما مترتبتين فتقع الأولى وتلغو الثانية كقوله طلقة قبل طلقة ومتى قال شيئا من ذلك لمدخول بها طلقت طلقتين لأنها لا تبين بالأولى ولو قال لها إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق وطالق وطالق إن قمت أو قال إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت [ج ٣ - ص ١٨٥]

ثلاثا مدخولا بها أو غير مدخول بها لأنه لا ترتيب فيه وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بها وثلاثا إن كان دخل بها

فصل

وإذا قال لمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقال أردت أنني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي دين وهل يقبل في الحكم فيه ثلاثة أوجه أحدها يقبل لأنه يحتمل أن يريد ذلك والثاني لا يقبل لأنه يخالف الظاهر والثالث إن كان وجد قبل لأن احتمال إرادة ذلك شائع ولا يقبل إن لم يكن وجد لأنه كذب وإن قال بعدها طلقة وقال أردت طلقة أوقعها فيما بعد دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فإن قال أردت بقولي أنت طالق أنت طالق التأكيد بالثانية قبل منه لأنه محتمل لما قاله وإن أطلق طلقت طلقتين لأن اللفظ الثاني كالأول فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول وإن قال أنت طالق طالق فهي واحدة لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف فينصرف إلى التأكيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل وإن قصد بالثاني الايقاع طلقت طلقتين ويقدر له ما يتم الكلام به وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث فإن قال أردت بالثانية التوكيد دين ولم يقبل في الحكم [ج ٣ - ص ١٨٦]

لأنه غاير بينهما بحرف وإن أراد بالثالثة التوكيد قبل في الحكم لأنها مثل الثانية في لفظها وكذلك إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وإن قال أنت طلاق وطالق فطالق أو طالق فطالق ثم طلاق وقال أردت التوكيد لم يقبل لأنه غاير بين الحروف وإن غاير بين الألفاظ فقا أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة وقال أردت بالثانية والثالثة التوكيد قبل لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام بخلاف التي قبلها

2 باب الإستثناء في الطلاق 2

يصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب ونزل به القرآن وقال أبو بكر لا يصح في عدد الطلقات لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منها والمذهب الأول لأنه استثناء في الطلاق فجاز كما في عدد المطلقات وليس الاستثناء رفعا لواقع اذ لو كان كذلك لم يصح في الاقرار ولا في عدد المطلقات وانما يمنع دخول المستثنى من الدخول في المستثنى منه ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر وفي استثناء النصف وجهان لما نذكره في الإقرار فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلا طلقتين طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقتين أو إلا طلقة وطلقة ففيه [ج ٣ - ص ١٨٧]

وجهان أحدهما لا يصح الاستثناء لأن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة فيكون مستثنيا للأكثر أو الكل والثاني يصح لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه فلا يبطل ببطلان غيره وإن قال أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة ففيه وجهان أحدهما يصح الاستثناء لما ذكرنا والثاني لا يصح لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه فيصير مستثنيا للكل ولأن تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغوا وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة أو طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة أو إلا نصف طلقة فكذلك لما ذكرنا ولو كان العطف بغير الواو لغا الاستثناء وجها واحد وإن قال أنت طالق خمسا إلا طلقتين لم يصح لأنه إن عاد إلى الخمس بقي بعد ثلاث وإن عاد إلى ثلاث لم يصح لأنه استثنى الأكثر فإن قال إلا طلقة ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه استثناء واحدة من خمس فبقي أربع والثاني يصح ذكره القاضي فيقع طلقتان لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من الطلقات دون ما زاد ولا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في مسألة واحدة وهي قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة في أحد الوجهين بناء على استثناء النصف وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة لم يصح لأن الاستثناء الأول باطل [ج ٣ - ص ١٨٨]

فلا يصح الاستثناء منه ويحتمل أن يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام لتعذر عوده إلى ما يليه فيقع طلقتان

فصل

وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة طلقت ثلاثا لأنه يسقط ما يقتضيه نصه بالنية فلم يصح وإن قال لنسائه أربعتكن طوالق واستثنى بقلبه إلا فلانة لم يصح كذلك وإن قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح ولم تطلق لأنه لا يسقط اللفظ وإنما يستعمل العموم في الخصوص وذلك شائع وإذا ادعى ذلك دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

2 باب الشروط في الطلاق 2

يصح تعليق الطلاق بشرط كدخول الدار ومجيء زيد ودخول سنة فإذا علقه بشرط تعلق به فمتى وجد الشرط وقع وإن لم يوجد لم يقع لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية أشبه العتق ولو قال عجلت ما علقته لم تطلق لأنه تعلق بالشرط فلم يتغير فإن قال أردت الطلاق في الحال وإنما سبق لساني إلى الشرط طلقت في الحال لأنه أقر [ج ٣ - ص ١٨٩]

على نفسه بما يوجب التغليط من غير تهمة وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

فصل

وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة إن ومن وإذا ومتى وأي وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو من قام منكن فهي طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق لأن اللفظ لا يقتضي التكرار وإن قال كلما قمت فأنت طالق فقامت طلقت وإن تكرر القيام تكرر الطلاق لأن اللفظ يقتضي التكرار وقال أبو بكر في متى ما يقتضي تكرارها لأنها تستعمل للتكرار قال الشاعر % متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد %

والصحيح أنها لا تقتضيه لأنها اسم زمان فأشبهت إذا وكل هذه الأدوات على التراخي إذا خلت من حرف لم فإن صحبتها لم كانت إن على التراخي وفي إذا وجهان أحدهما هي على الفور لأنها اسم زمان فأشبهت متى والثانية على التراخي لأنها أخلصت للشرط فهي بمعنى إن وإن احتملت الأمرين لم يقع الطلاق بالشك وسائر الأدوات على الفور [ج ٣ - ص ١٩٠]

لأنها تقتضيه فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا بعينه ولا دلت عليه قرينة لم يقع الطلاق إلا عند قربه منه وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما وإن قال متى لم أطلقك أواي وقت لم أطلقك فأنت طالق أو من لم أطلقها منكن فهي طالق فمضى زمن يمكن طلاقها ولم يطلقها طلقت وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال أو في آخر حياة أ حدهما على وجهين وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا لأن معناه كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق وقد سكت ثلاث سكتات في ثلاثة أوقات

فصل

وإن قال إن دخلت الدار أنت طالق لم تطلق حتى تدخل كما لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ويحتمل أن يقع في الحال لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه لم يكن إلا بالفاء أو بإذا وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق طلقت في الحال لأن الواو ليست جوابا للشرط فإن قال أردت بها الجزاء أو أردت أن أجعلهما شرطين لشيء ثم أمسكت دين لأنه محتمل لما قاله وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين فإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت لأن معناه ولو دخلت كقوله عليه [ج ٣ - ص ١٩١]

الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار طلقت لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع كقوله تعالى ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ وإن قال أردت الشرط قبل لأنه محتمل وإن قال أنت طالق أن دخلت بفتح الهمزة طلقت عند أبي بكر لأن أن للتعليل لا للشرط كقوله تعالى ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ وقال القاضي قياس قول أحمد أنه إن كان نحويا وقع طلاقه لذلك وإن كان عاميا فهي للشرط لأن العامي لا يريد بها الا الشرط فأجري عليه حكمه وحكي عن الخلال أن النحوي اذا لم يكن له نية فهو كالعامي

فصل

فإن قال أنت طالق إذا شربت إذا أكلت أو متى أكلت لم تطلق حتى تشرب بعد الأكل لأن إدخال الشرط على الشرط يقتضي تقديم المؤخر وإن قال أنت طالق إن شربت إن أكلت فكذلك لما ذكرناه وإن قال أنت طالق إن شربت فأكلت أو إن شربت ثم أكلت لم تطلق حتى تأكل بعد الشرب لأنهما حرفا ترتيب وإن قال أنت طالق إن شربت وأكلت طلقت بوجودهما على أي صفة لأن الواو للجمع ولا تقتضي ترتيبا ولا تطلق بوجود أحدهما لأنها للجمع وان قال أنت طالق إن أكلت أو شربت

طلقت بوجود أحدهما لأن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد من المذكورين لقوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾

فصل في تعليق الطلاق بالحيض

إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول جزء من الحيض فإن رأت دما وتبين أنه ليس بحيض تبين أن الطلاق لم يقع وإن قالت قد حضت فكذبها قبل قولها بغير يمين وعنه لا يقبل قولها ويختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج فإن ظهر الدم فهي حائض وإلا فلا والمذهب الأول لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه ولأنه لا يعرف إلا من جهتها وإن قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت قد حضت فكذبها لم تطلق ضرتها لأن قولها يقبل في حقها دون غيرها وإن قال الزوج قد حضت فكذبته طلقت بإقراره وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فصدقها طلقتا وإن كذبها طلقت وحدها [ج ٣ - ص ١٩٣]

ولم تطلق الضرة وإن صدقها وإن قال إذا حضتما فأنتما طلقتان فصدقهما طلقتا وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على حيضهما ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها وإن صدق إحداهما وحدها لم تطلق لأن قول المكذبة غير مقبول في حقها وطلقت المكذبة لأنها مقبولة القول في نفسها وقد صدق الزوج صاحبتها فوجد الشرطان في طلاقها فطلقت وإن قال لأربع نسوة له إن حضتن فأنتن طوالق فقد علق طلاق كل واحدة منهن بحيض الأربع فإن قلن قد حضنا فصدقهن طلقن لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه وإن كذبهن أو كذب ثلاثا أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن لأن قول كل واحدة لا يقبل إلا في حق نفسها فلم يوجد الشرط وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة لما ذكرنا في الاثنتين إذا صدق إحداهما وإن قال كلما حضت إحداكن فضرائرها طوالق فقد جعل حيض كل واحدة شرطا لطلاق البواقي فإن قلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث ضرائر فتطلق بحيض كل واحدة طلقة وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة منهن طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة لأن حيضها ثبت بتصديقه ولم تطلق المصدقة لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها وان صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة [ج ٣ - ص ١٩٤]

وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين لما ذكرنا

فصل

إذا قال لحائض إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض لأن إذا اسم لزمن مستقبل فتقتضي فعلا مستقبلا وان قال لها اذا طهرت فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم نص عليه لأنه ثبت لها أحكام الطهر من وجوب الغسل والصلاة وصحة الصوم وذكر أبو بكر قولا آخر أنها لا تطلق حتى تغتسل لأن بعض أحكام الحيض باقية وإن قال لطاهر إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر لما ذكرنا وإن قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر نص عليه لأنها لا تحيض حيضة كاملة إلا بذلك وإن قال إن حضت نصف حيضة فأنت طالق احتمل أن تطلق إذا مضى نصف عادتها لأن الأحكام تعلقت بالعادة واحتمل أنه متى مضت حيضتها تبينا وقوع الطلاق في نصفها وحكي عن القاضي أنه يلغو قوله نصف حيضة ويتعلق الطلاق بأول الدم وقيل عنه تطلق بمضي سبعة أيام ونصف لأنه نصف أكثر الحيض يعني والله أعلم أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر [ج ٣ - ص ١٩٥]

الحيض لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة فلا يقع الطلاق بالشك فإن طهرت بدون ذلك تبينا وقوع الطلاق ونصف الحيضة قلت أو كثرت لأننا تبينا مضي نصف الحيضة بمضيها كلها وإن قال لزوجتيه إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان لغا قوله حيضة واحدة لاستحالة ذلك وصار كقوله إذا حضتما فأنتما طالقتان فإن قال أردت إذا حاضت كل واحدة منهما قبل لأنه محتمل لما قاله

فصل

إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة وهي المدخول بها من ذوات الأقراء أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال لوجود الصفة وإن كانت حائضا أو في طهر أصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة فإذا طهرت الحائض أو حاضت المصابة ثم طهرت طلقت لوجود الصفة حينئذ وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم تطلق لعدم الصفة فإذا حاضت أو جامعها طلقت وإن قال لها أنت طالق للسنة إن كنت الآن ممن يطلق للسنة وكانت في زمن السنة طلقت لوجود الصفة وإلا لم تطلق بحال لأنه شرط لوقوعه كونها الآن ممن يطلق للسنة ولم يوجد ذلك وان قال أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت في الحال واحدة فإذا صارت إلى [ج ٣ - ص ١٩٦]

ضد حالها طلقت الأخرى وإن قال طلقة للسنة وللبدعة لغا قوله للسنة وللبدعة لاستحالة اجتماعهما وطلقت في الحال وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة فعلى قول الخرقي تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه لأنه وقت السنة وعلى قول أبي بكر تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيه وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن وجدا لأن السنة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال والثالثة في الحال الأخرى لأن قسط الحال الأولى طلقة ونصف فكمل فصار طلقتين وإن قال أردت في هذه الحال واحدة والباقي في الأخرى قبل قوله لأن البعض يقع على الطلقة حقيقة فلم تخالف دعواه الظاهر فقبلت

فصل

وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض أو آيسة أو حامل تبين حملها أو غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فإذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت لوجود الصفة وإن قال أنت طالق للسنة أو للبدعة أو للسنة والبدعة طلقت في الحال لأنه وصفها بصفة لا تتصف بها فلغت الصفة ووقع الطلاق فإن قال أردت إيقاعه بها إذا صارت من أهل سنة الطلاق وبدعته دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

فصل

إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله وأعدله وما أشبه هذا من الصفات الجميلة طلقت للسنة وإن قال أقبح الطلاق وأسمجه وما أشبهه من صفات الذم طلقت للبدعة فإن قال أردت بالأول طلاق البدعة وبالثاني طلاق السنة لأنه الأليق بها فإن كان أغلظ عليه قبل قوله لأنه مقر على نفسه وإن كان أخف عليه دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فهو طلاق البدعة لأنه يأثم به وإن قال أنت طالق طلاقة حسنة قبيحة طلقت في الحال على أي صفة كانت لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع الطلاق وإن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي ممن لطلاقها سنة وبدعة طلقت في كل حيضة طلقة إلا على قولنا الأقراء الأطهار فإنه يقع في كل طهر طلقة وإن كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة طلقت في الحال طلقة ثم إن كانت ممن يتجدد لها أقرؤ طلقت في كل قرء منها طلقة ويحتمل أن لا تطلق في الحال شيئا لأن القرء والطهر بين الحيضتين وليس ذلك لها [ج ٣ - ص ١٩٨]

فصل في تعليقه بالحمل

إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها نص عليه لأنه يحتمل أن تكون حاملا فيغلب التحريم وحكى أبو الخطاب رواية أخرى لا يحرم وطؤها لأن الأصل عدم الحمل ثم إن ولدت لأقل من ستة أشهر تبينا وقوع الطلاق لأنها كانت حاملا وإن ولدت لأكثر من أربع سنين لم تطلق لاننا علمنا أنها لم تكن حاملا وإن ولدت فيما بين ستة أشهر وأربع سنين ولم يكن لها من يطؤها طلقت لأنها كانت حاملا وإن كان لها زوج يطؤها فولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطء طلقت لأننا علمنا أنه ليس من الوطء وإن ولدته الاكثر من ستة أشهر من وطئه لم تطلق لأن الأصل عدم الحمل والطلاق وإن قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها لأن الأصل عدم الحمل وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع هاهنا وكل موضع لا يقع ثم يقع هاهنا لأنها ضدها إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين فهل يقع الطلاق هنا فيه وجهان أحدهما تطلق لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء والثاني لا تطلق لأن الأصل بقاء النكاح ويحصل الاستبراء بحيضه نص عليه لأن براءة الرحم تحصل بحيضة وذكر القاضي رواية أخرى أنها تستبرىء بثلاثة قروء [ج ٣ - ص ١٩٩]

لأنه استبراء حرة فأشبهت عدتها والأولى أصح لأن المقصود معرفة براءتها من الحيض وهو يحصل بحيضة وأما عدة الحرة بثلاثة قروء ففيها نوع من التعبد ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل ان يكون زوجها غائب عنها سنين وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة فلا يجوز تعديتها إلى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه وإن استبرأها قبل عقد اليمين أجزأ لأن معرفة براءة الرحم تحصل به وهو المقصود ولو قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا ولو قال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها ذكرا أو أنثى ولم يوجد

فصل في تعليقه بالولادة

إذا قال إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا حيا أوميتا ذكرا أو أنثى أو خنثى طلقت لأنه ولد وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأن صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة وإن ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد طلقت بالأول طلقة وبالثاني أخرى وبانت بالثالث ولم تطلق به ذكره أبو بكر لأن العدة [ج ٣ - ص ٢٠٠]

انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق وقال ابن حامد تطلق به الثالثة لأن زمن الوقوع زمن البينونة ولا تنافي بينهما والأول أصح وعليه التفريع فلو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة طلقت ثلاثا فإن ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالأول ما علق عليه وبانت بالثاني ولم تطلق به فإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة بيقين ولم تلزمه الثانية بالشك وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو الأول ولو قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق لأنه لا أول فيهما ومتى ادعت الولادة فصدقها أو ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره فإن ادعته المرأة فأنكرها لم تطلق إلا ببينة لأن هذا يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض

فصل في تعليقه بالطلاق

إذ قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها طلقت طلقتين واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لأجعله شرطا دين وهل يقبل في الحكم على روايتين لأن الظاهر جعله شرطا وإن وكل من طلقها فهو [ج ٣ - ص ٢٠١]

كمباشرته لأن فعل الوكيل كفعل الموكل وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين واحدة بقيامها وأخرى بالصفة لأن الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها وإن قال مبتدئا إن قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق للأخرى لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع ووقوع الطلاق هاهنا بالقيام إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا ولو قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذ وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين لأن الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد وجدت الصفة ولو قال إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم قال إذا قمت فأنت طالق فقامت طلقت اثنتين لأن قوله أوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك وقال القاضي لا تطلق إلا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة لأن ذلك يقتضي مباشرتها به لا وقوعه بالصفة وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت طلقتين إحداهما بقوله أنت طالق والأخرى بالصفة ولا تقع الثالثة لأن الصفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع عليها الثالثة وإن [ج ٣ - ص ٢٠٢]

قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فقال ابن عقيل تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو ما علق عليها لأنه طلاق في زمن ماض فأشبه قوله أنت طالق أمس وقال القاضي تطلق ثلاثا لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا فإن قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمرة طالق وكلما طلقت عمرة فحفصة طالق ثم طلق إحداهما طلقتا جميعا إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة فإن كانت المباشرة به حفصة لم تزد واحدة منهما على طلقة لأنه ما أحدث في عمرة طلاقا إنما طلقت بالصفة السابقة وإن كانت المباشرة عمرة طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقها وإن قال لحفصة كلما طلقت عمرة فأنت طالق وقال لعمرة كلما طلقت حفصة فأنت طالقة ثم طلق عمرة طلقت كل واحدة واحدة وإن طلق حفصة طلقة طلقت طلقتين وطلقت عمرة واحدة وإن قال لأربع نسائه أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع بإحداهن طلاقه طلق الجميع ثلاثا

فصل

وإن كان له أربع نساء وعبيد فقال كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار

وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات فإنه يعتق من عبيده خمسة عشر يعتق بطلاق الواحدة واحد وبطلاق الثانية ثلاثة لأنها واحدة وهي لصاحبتها اثنتان ويعتق بطلاق الثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع صاحبتيها ثلاث ويعتق بطلاق الرابعة سبعة لأنها واحدة وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع صواحبها أربع وإن شئت قلت فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق لذلك أربعة وهن أربعة آحاد فيعتق بذلك أربعة أخر وهن اثنتان واثنتان فيعتق بذلك أربعة أخر وفيهن ثلاث فذلك خمسة عشر وقيل يعتق عشرة بالواحدة واحد وابالثانية اثنان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة والأول أصح لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء وإن كان في محل واحد ولذلك لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت أسود فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت طالق فكلمت رجلا اسود طويلا طلقت ثلاثا ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا واحدة لكونها رمانة واثنتان بأكلها النصفين ولو قال إذا ولدت ولدا فأنت طالق وإذا ولدت غلاما فأنت طالق وإذا ولدت أسود فأنت طالق فولدت غلاما أسود طلقت ثلاثا

فصل في تعليقه بالحلف

إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق [ج ٣ - ص ٢٠٤]

ثم قال إن خرجت فأنت طالق أو إن لم تخرجي فأنت طالق أو إن لم يكن هذا القول حقا فأنت طالق طلقت في الحال لأنه حلف بطلاقها وإن قال إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فأنت طالق ففيه وجهان أحدهما لا تطلق حتى تطلع الشمس ويجيء الحاج لأن الحلف ما قصد به المنع من الشيء أو الحنث عليه أو التصديق وليس في طلوع الشمس وقدوم الحاج شيء من هذا هذا قول القاضي في المجرد وابن عقيل والثاني أنه حلف لأنه تعليق على شرط فكان حلفا كما لو قال إن خرجت فأنت طالق هذا قول القاضي في الجامع وأبي الخطاب وإن قال إذا شئت فأنت طالق أو إذا حضت أو إذا طهرت فأنت طالق لم يكن حلفا وجها واحدا لأن تعليقه على المشيئة تمليك وتعليقه على الحيض طلاق بدعة وتعليقه على الطهر طلاق سنة فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده ثانية طلقت واحدة لأنه حلف بطلاقها فإن أعاده ثالثا طلقت ثانية فإن أعاه رابعا طلقت ثلاثا لأن كل مرة يوجد بها صفة طلاق وتنعقد بها صفة أخرى ومثله لو قال إن كلمتك فأنت طالق وكرره أربعا طلقت ثلاثا كذلك ولو قال لمدخول بهما إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وكرره أربعا طلقتا ثلاثا فإن كانتا غير مدخول بهما بانتا إذا أعاده مرة ثانية ولم يقع بهما بعده طلاق فإن كانت إحداهما مدخولا بها و الأخرى

غير مدخول بها فأعاده مرة طلقت المدخول بها طلقة رجعية والأخرى طلقة ثانية فإن أعاده ثانيا لم تطلق واحدة منهما لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يحلف به لأن غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها وإن قال لمدخول بهما أو لإحداهما إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال للأخرى مثل ذلك طلقت الأولى وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى وإن قال كلما حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال مثل ذلك لضرتها طلقت فان أعاده للأولى طلقت الضرة فإن أعاده للثانية طلقت الأولى وكلما أعاده لامرأة طلقت ضرتها حتى تكمل ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق أخرى ولم تطلق الأخرى بإعادته لها لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا

فصل

وإن استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم وأجابه بجوابه فقال أنت طالق لأقومن أو ما قمت أو لقد قمت أو إني لقائم وبر لم يقع الطلاق لأنه حلف بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله وإن حنث وقع طلاقه وإن قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق وإن كان كاذبا طلقت

فصل في تعليقه بالكلام

إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك أو فتحققيه طلقت لأنه كلمها بعد عقد اليمين إلا أن يريد بعد انقضاء كلامي هذا ونحوه وإن زجرها فقال تنحي أو اسكتي حنث لأنه كلام وإن سمعها تذكره فقال الكاذب لعنه الله حنث لأنه كلمها وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر انحلت يمينه بيمينها لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك بداية فإن كلمها انحلت يمينها لأنها لم تبدأه ما لم يكن لهما نية وإن قال إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدا ففيه وجهان أ حدهما يطلقان لأن تكليمهما وجد منهما والثاني لا يطلقان حتى تكلم كل واحدة الرجلين معا لأنه علق طلاقهما على فعليهما معا ولو قال إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان طلقتا إذا ركبت كل واحدة دابة لأن العرف في ركوب دابتيهما أن يركب كل واحد دابته ولو قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال يكون محمد مع خالد لأن الجملة حال للجملة الأولى إلا أن يريد بكلامه الاستئناف فتطلق بكلام زيد بكل حال وقال القاضي يحنث بكلام زيد لأن الجملة الثانية استئناف لا تعلق لها بالأولى وإن قال

من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق وأخبره بذلك زوجتاه وهما صادقتان طلقت الأولى وحدها لأن البشارة خبر يحصل به سرور أو غم وإنما تحصل بالأول وإن كانتا كاذبتين لم تطلق واحدة منهما لأنه لا سرور في الكذب وإن كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة طلقت الثانية وحدها لذلك وإن قال من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق فقال القاضي هي كالتي قبلها سواء لأن المراد من الخبر الإعلام ولا يحصل إلا بالخبر الأول الصدق ويحتمل أن تطلق الثانية والكاذبة لأن الخبر يقع على الجميع

فصل في تعليقه بالمشيئة

إذا قال أنت طالق إن شئت أو متى شئت أو غير ذلك من الحروف فقالت قد شئت طلقت سواء شاءت على الفور أو التراخي لأنه تعليق للطلاق على شرط فأشبه سائر التعليق وإن قالت قد شئت إن شئت أو إن شاء أبي لم تطلق وإن شاء لأنها لم تشأ إنما علقت مشيئتها بمشيئته كما لو قالت قد شئت إذا طلعت الشمس ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فشاء وهو مجنون أو طفل لم تطلق لأنه لا مشيئة لهما وكذلك إن شاء وهو سكران وخرجه أصحابنا على روايتين في طلاقه وإن شاء وهو مميز طلقت لأن له مشيئة ولذلك صح اختياره لأحد أبويه وخوطب [ج ٣ - ص ٢٠٨]

بالاستئذان في العورات الثلاث وإن كان أخرس فأومأ بمشيئته طلقت لأن إشارته كنطق غيره وإن كان ناطقا فخرس فكذلك لأنه من أهل الإشارة ويحتمل أن لا يحنث لأن إشارته لا يعتد بها في تلك الحال في الشرع وإن مات أوجن لم تطلق لأنه لم يشأ وحكي عن أبي بكر أنها تطلق وإن قال أنت طالق إن شاءت البهيمة فهو تعليق للطلاق على المستحيل وإن قال أنت طالق لمشيئة أبيك أو رضاه طلقت في الحال لأن معناه ليرضى أو لكونه شاء فإن قال أردت تعليقه بذلك قبل منه لأن ذلك يستعمل للشرط في قوله أنت طالق للسنة فإن قال أنت طالق إلا أن تشائي فشاءت في الحال لم تطلق وإن لم تشأ طلقت لأنه أوقعه عليها إلا أن ترفعه مشيئتها فإذا لم يوجد ما يرفعه وقع وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا وإن لم تشأ أو شاءت دون الثلاث وقعت واحدة لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك وفيه وجه آخر أنها إذا شاءت ثلاثا لم تطلق لأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث ولم يوقع لمشيئتها شيئا فأشبه قوله إلا أن تشائي وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك فشاء أحدهما منفردا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط

فصل

وإن قال أنت طالق إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبين ذلك في قلبك فقالت أنا أحب ذلك ففيه وجهان أحدهما لا تطلق لأنها لا تحب ذلك وقولها كذب لا يلتفت إليه والثاني تطلق لأنه لما لم يوقف على ما في القلب علق على النطق كالمشيئة

فصل

فإن قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء طلقت زوجته وعتق عبده لما روى عن ابن عباس أنه قال إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل فإن قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله ففيه روايتان إحداهما يقع الطلاق لما ذكرنا والأخرى لا يقع لان الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت لما ذكرنا ولأنه علق رفع الطلاق على مشيئة لا يوقف عليها وإن قال أنت طالق ما لم يشأ الله أو إن لم يشأ الله طلقت لأنه علقه بمستحيل فإن وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال ويحتمل أن لا يحنث وإن قال أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم يحنث دخلت الدار أو لم [ج ٣ - ص ٢١٠]

تدخل لأنها إن دخلت فقد شاء الله وإن لم تدخل فلم يشأ الله تعالى

فصل في تعليقه بوقت مستقبل

لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم ولو سميت المراة بعينها رواه الدارقطني وفي لفظ لا طلاق فيمالا يملك رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى أبو داود الطيالسي نحوه وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وإن تزوجت فلانة فهي طلاق ثم تزوجها لم يقع كذلك قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله أن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع وقال غيره عن أحمد ما يدل على أن الطلاق يقع لأنه يصح تعليقه على الإخطار فصح تعليقه على الملك كالوصية والمذهب الأول لما ذكرنا ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كالمجنون

فصل

إذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت طلقت بأوله لأنه إذا علق بشيء تعلق بأوله كما لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار طلقت بدخولها أول جزء منها فول قال أنت طالق في رمضان طلقت بغروب شمس شعبان

وإن قال أنت طالق اليوم طلقت في الحال وإن قال أنت طالق غدا طلقت بطلوع فجره فإن قال أردت في آخر الشهر واليوم والغد دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن قال أنت طالق في أول رمضان أوفي غرته طلقت في أوله ولم يقبل قوله نويت آخره لأنه لا يحتمله وإن قال أردت بالغرة اليوم الثاني قبل لأنه محتمل لأن الثلث الأول من الشهر تسمى غررا وإن قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان طلقت بأول جزء منه لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن قال أردت إذا رأيته بعينيك قبل لأنه فسر اللفظ بموضوعه ويتعلق الحكم برؤيتها إياه بعد الغروب وبعده لأن هلال الشهر ما كان في اوله ويحتمل أن يتعلق برؤيتها إياه قبل الغروب وبعده لأنه هلال للشهر يتعلق به وجوب الصوم والفطر وإن لم تره حتى أقمر لم تطلق لأنه ليس بهلال واختلف فيما يقمر به فقيل بعد ثالثة وقيل باستدارته وقبل إذا بهر ضوؤه وإن قال أنت طالق إلى شهر رمضان طلقت في أول جزء منه كقوله في شهر رمضان لأنه جعل الشهر غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله فإن قال أردت الإيقاع في الحال طلقت لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وإن قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت في آخر أول يوم منه لأنه [ج ٣ - ص ٢١٢]

أوله وإن قال في أول آخره طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه لأنه آخره وقال أبو بكر تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم الخامس عشر منه لأنه آخر نصف الشهر الأول وأول نصفه الآخر

فصل

إذا قال إذا مضت سنة فانت طالق اعتبر مضي سنة بالأهلة لأنها السنة المعهودة في الشرع فإن قاله في أثناء شهر كمل ذلك الشهر بالعدد ثلاثين يوما وأحد عشر شهرا بالأهلة وإن قال أردت سنة بالعدد وهي ثلاثمائة وستون يوما أو شمسية وهي ثلاثمائة وخمس وستون يوما قبل لأنه سنة حقيقة وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة لأن التعريف بالألف واللام يقتضي ذلك فإن قال أردت سنة كاملة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة طلقت في الحال ثم إذا مضت سنة كاملة طلقت أخرى وكذلك الثالثة وقال أبو الخطاب تطلق الثانية بدخول المحرم وكذلك الثالثة فإن قال أردت أن تكون ابتداء السنين من أول الجديدة دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين [ج ٣ - ص ٢١٣]

فصل

وإن قال أنت طالق إذا قدم فلان غدا أو غدا إذا قدم فلان لم تطلق حتى يقدم لأن الطلاق لا يقع قبل شرطه فإن مات قبل قدومه لم تطلق لأنها لم تبق محلا للطلاق وإن قدم بعد الغد لم تطلق لفوات محل الطلاق وإن قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم تطلق لأن الشرط لم يوجد إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق قال الله تعالى ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره ﴾ وإن قدم نهارا طلقت وهل تطلق في أول اليوم أو حين قدومه فيه وجهان أ حدهما تطلق من أوله كما لو قال أنت طالق يوم الجمعة والثاني لا تطلق إلا بعد قدومه لأنه جعل قدومه فيه شرطا فلا تطلق قبله فإن مات قبل قدومه طلقت على الوجه الأول ولم تطلق على الثاني

فصل

وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقها طلقت في آخر اليوم إذا بقي منه مالا يتسع لقوله أنت طالق لأن معناه إذا فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق وبهذا يفوت طلاقها وقال أبو بكر لا تطلق لأن شرط طلاقها خروج اليوم وبخروجه يقوم محل طلاقها وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فقال القاضي في موضع يقع الطلاق في الحال [ج ٣ - ص ٢١٤]

لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة وقال في المجرد لا تطلق لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط وإذا جاء الغد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض

فصل

وإن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة لان من طلقت اليوم فهي طالق غدا وإن قال أردت طلقة اليوم وطلقة غدا طلقت اثنتين لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظوإن قال أردت نصف طلقة اليوم ونصف غدا فكذلك لأن كل نصف يكمل بالسراية فيصيران طلقتين وإن قال أردت نصف طلقة اليوم وباقيها غدا فكذلك في إحدى الوجهين لأن باقيها نصف يكمل بالسراية والثاني لا تطلق إلا واحدة لأنه لما كمل النصف الأول لم يبق من الطلقة شيء فلا باقي لها فإن قال أنت طالق اليوم والغد طلقت واحدة لما ذكرنا وإن قال أنت طالق في اليوم وفي الغد فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر تطلق طلقتين لأن إعادة حرف الصلة يقتضي فعلا فكأنه قال أنت طالق في اليوم وأنت طالق في غد [ج ٣ - ص ٢١٥]

فصل

إذا قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق لأنها بعد موته بائن فليست محلا للطلاق وإن قال أنت طالق مع موتي لم تطلق لأن زمن البينونة زمن الطلاق فلم يمكن إيقاعه وإن تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي فأنت طالق فمات أبوه لم تطلق لأنه يملكها بموت أبيه فينفسخ نكاحه فيجتمع الفسخ والطلاق فيمتنع وقوعه كالتي قبلها وفيه وجه آخر أنها تطلق لأن زمن الطلاق عقيب الموت وهو زمن الملك والفسخ بعد الملك فيتقدم الطلاق الفسخ فيقع وإن قال إن اشتريتك فأنت طالق واشتراها فعلى وجهين كالتي قبلها وإن قال الأب لجاريته إذا مت فأنت حرة وقال الزوج إذا مات أبي فأنت طالق فمات الأب وقعت الحرية والطلاق معا لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه

فصل في اضافته إلى زمن ماض

إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أ ن أتزوجك لم يقع الطلاق نص عليه لأنه إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيه فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر ومات قبل مضي شهر وقال القاضي في بعض كتبه تطلق لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت الصفة ووقع [ج ٣ - ص ٢١٦]

الطلاق كما لو قال لآيسة أنت طالق للبدعة وحكي عن أبي بكر أن الطلاق يقع في قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك خاصة لأنه يمكن أن يتزوجها بائنا وهذا الوقت قبله فيقع فيه بخلاف التي قبلها وإن قال أردت طلاقها في الحال وقع لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ وإن قال أردت أني طلقتها أمس طلقت بإقراره وإن قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر أو طلقها زوج قبلي فقد ذكرنا حكمه فيما مضى وإن قال أنت طالق قبل قدوم أخي بشهر أو قبل موتي بشهر فقدم أخوه أو مات مع مجيء الشهر أو قبله لم تطلق لأنه زمن ماض وإن قدم أو مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه تبينا أنه وقع في ذلك الجزء قبل الشهر فإن خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم مات أو قدم بعد التعليق بشهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع لأنها بانت بالطلاق فكان الخلع لبائن وإن مات أو قدم بعد الخلع بشهر وساعة صح الخلع لأنه صادف زوجة ولم يقع الطلاق لأنها بانت بالخلع قبله وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال لأنه قبل موته وكذلك إن قال أنت طالق قبل قدوم زيد سواء قدم أو لم يقدم ذكره القاضي وان قال أنت طالق قبيل موتي أو قبيل قدوم زيد لم يقع الطلاق إلا في الجزء الذي يلي الموت لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير

فصل

وإن علقه على مستحيل كقوله أنت طالق إن طرت ففيه وجهان أحدهما لا تطلق لأنه علقه على صفة لم توجد والثاني تطلق لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة فلغا الشرط ووقع الطلاق كقوله أنت طالق طلقة لا تلزمك ولو قال أنت طالق إن لم تطيري أو تقتلي الميت طلقت في الحال لأنه معلوم عدمه وان قال أنت طالق لتطيرن فكذلك وحكي عن القاضي أنه لا يحنث

فصل

إذا كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت اذا أتاها وإن ذهبت حواشيه أو امحى ما فيه إلا ذكر الطلاق طلقت لأنه أتاها كتابه مشتملا على المقصود وإن امحى كل ما فيه أو امحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق لأن المقصود لم يأت وان ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق ففيه وجهان أحدهما تطلق لأن المقصود أتاها والثاني لا تطلق لأن الكتاب لم يأت وان قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب اذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين واحدة بمجيء الكتاب والأخرى بمجيء الطلاق [ج ٣ - ص ٢١٨]

فصل مسائل تنبني على نية الحالف

إذا قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة والا فأنت طالق فإنها تعد له عددا يعلم أن عددها داخل فيه ولا يحنث إذا نوى ذلك فإن لم ينو حنث في قياس المذهب لأن الأيمان تنبني على المقاصد وظاهر قصد الحالف العلم بكميته ولا يحصل بهذا فإن قال إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة وحدها فالحكم فيها كالتي قبلها ولو وقعت في ماء جار فقال إن أقمت فيه أو خرجت منه فأنت طالق فقال القاضي في الجامع هي كذلك لأن الظاهر قصده خروجها من النهر وقال في المجرد لا يحنث بحال لأن االماء الذي كانت فيه جرى وصارت في غيره ولو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان عبدي في السوق فأمرأتي طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة لأن العبد عتق باللفظ الأول فلما عتق لم يبق له في السوق عبد ولو كان في فيها تمرة فقال إن أكلتيها أو أمسكتيها أو ألقيتيها فأنت طالق فأكلت بعضها ورمت بعضها انبنى على فعل بعض المحلوف عليه ولو كانت على سلم فحلف عليها ألا تنزل عنه ولا تصعد عنه ولا تقف عليه فإنها تنتقل إلى سلم آخر ثم تنزل أو تصعد لأن نزولها أو صعودها إنما حصل من غيره ولو سرقت زوجته منه شيئا فحلف لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا وكانت [ج ٣ - ص ٢١٩]

قد سرقت منه وخشيت أن تخبره فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك وتكون ما هاهنا بمعنى الذي

فصل

ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم تزوجها قبل الصفة عادت الصفة لأن العقد والصفة وجدا منه في الملك فأشبه ما لو لم يخللهما بينونة وإن وجدت الصفة حال البينونة لم يحل اليمين لأنه لم يحنث في يمينه فلم تنحل كما لو لم توجد الصفة ولأن الملك مقدر في يمينه لتقييد الطلاق به ويتخرج أن تنحل الصفة بناء على قوله في العتق وهو اختيار أبي الحسن التميمي لأن الصفة وجدت فانحلت اليمين بها كما لو وجدت حال الملك ولأن اليمين إذا تعلقت بعين لم تتقيد بالملك كما لو حلف لا يدخل هذه الدار وهي ملكه والله أعلم

2 باب الشك في الطلاق 2

إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك وإن طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا بني على اليقين كذلك نص عليه أحمد فإذا ارتجعها فعليه نفقتها واختلف أصحابنا في حلها فقال الخرقي هي محرمة لأنه متيقن للتحريم الحاصل بالطلاق شاك في حصول الحل

بالرجعة فلا يزول التحريم المتيقن بالشك وقال غيره تحل لأن الرجعة مزيلة الحكم المتيقن من الطلاق ومنهم من منع حصول التحريم بالطلاق لكون الرجعة مباحة فلم يكن التحريم يقينا والورع أن يلتزم حكم الطلاق الأكثر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لتحل لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

فصل

وإذا قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن نص عليه لأنه يروى عن علي وابن عباس ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق وإن نوى واحدة بعينها طلقت وحدها لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه وقوله في ذلك مقبول لأنه لا يعلم إلا من جهته فقبل منه كقول المرأة في حيضها وإن قال هذه المطلقة بل هذه المطلقة طلقتا لأن إقراره بطلاق الثانية مقبول ورجوعه عن طلاق الأولى غير مقبول وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخريين وإن قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الثالثة وإحدى الأوليين وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه احتمل ان يكون الشك في الجميع لأنه أتى بحرف الشك بعد الأوليين فيعود إليهما واحتمل أن يكون الشك في الثانية [ج ٣ - ص ٢٢١]

والثالثة لأن حرف الشك بينهما وإن قال طلقت هذه أو هذه وهذه ففي أحد الوجهين يكون شاكا في طلاق الجميع لا يدري أطلق الأولى وحدها أم الأخريين جميعا وفي الأخرى يكون متيقنا لطلاق الثانية شاكا في الأوليين وكل موضع علم أنه طلق بعضهن فاشتبهت عليه بغيرها فحكمها حكم المنسية على ما سنذكره وإن لم ينو واحدة بعينها تعينت بالقرعة وعليه نفقة الجميع حتى يتيقن المطلقة لأنهن محبوسات عليه

فصل

وإن طلق واحدة بعينها ثلاثا وأنسيها أو خفيت عليه بأن طلقها في ظلمة أو من وراء حجاب أو يراها في طاقة فيطلقها وتشتبه عليه فإنه يحرم عليه الجميع لأنه اشتبهت زوجته بغيرها فحرمتا كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها وإن علمها عينها وقبل قوله لأنه لا يعلم إلا من جهته فإن امتنع مع العلم حبس حتى يعينها لأنه حق عليه امتنع عن إيفائه وإن ادعت غير المعينة عليه أنها المطلقة فالقول قوله من غير يمين فإن مات أقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة فلا ميراث لها قال إسماعيل ابن سعيد سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت أرأيت إن مات [ج ٣ - ص ٢٢٢]

بعدها قال أقول بالقرعة وذلك لأنه تصير القرعة على المال وقد روي عن علي في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة وقسم بينهن الميراث وكذلك إن ماتت إحداهن أو متن جميعا أقرعنا بينهن فمن خرجت عليها القرعة حرمناه ميراثها وقال الخرقي وكثير من أصحابنا يقرع بينهن في حياته فمن خرجت عليها قرعة الطلاق بانت وحل له البواقي احتجاجا بحديث علي رضي الله عنه فإن ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها بانت المذكورة لأنها المطلقة ويكون وطؤه لها وطئا بشبهة وترد إليه الأخرى إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون القرعة بحكم حاكم فلا ترد نص عليه لأنها إذا تزوجت فقد تعلق بها حق غيره فلم يقبل قوله في فسخ نكاح غيره وقرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه وقال أبو بكر وابن حامد لا ترد إليه التي عينتها القرعة بحال لأنه لا يقبل قوله عليها ولا يرثها إن ماتت وإن مات هو ورثته

فصل

وإن رأى طائرا فقال إن كان غرابا ففصة طالق وإن كان حماما فعمرة طالق فطار ولم يعرف ما هو لم يلزمه طلاق لأنه يحتمل أنه غيرها

ولو قال إن كان غرابا فحفصة طالق وإن لم يكن غرابا فعمرة طالق ولم يعرف ما هو طلقت إحداهما والحكم فيها على ما ذكرنا في المشتبهة وإن كان الحالف رجلين فقد حنث أحدهما فيحرم الوطء عليهما لأننا علمنا التحريم في إحداهما فأشبه ما لو كان الحالف واحدا على زوجتين ويبقى في حق كل واحد منهما أحكام النكاح من النفقة والكسوة والمسكن لأن نكاحه كان متيقنا وزواله مشكوك فيه ولو قال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر لم يعتق واحد منهما لأن الأصل الرق فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه عتق لأن تمسكه بعبده اعتراف منه بعتق الآخر وقد ملكه فيعتق قاله القاضي وقال أبو الخطاب يقرع بينهما حينئذ لأن العبدين صارا له وقد علم عتق أحدهما لا بعينه فيعتق بالقرعة إلا أن يكون أحدهما قد أقر أن الحانث صاحبه فيؤخذ بإقراره ولو كان الحالف واحدا فقال إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعرف أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو الحر لأن القرعة تستعمل لتعيين الحرية [ج ٣ - ص ٢٢٤]

فصل

إذا قال لحماته ابنتك طالق أو كان اسم زوجته زينب فقال زينت طالق طلقت زوجته فإن قال أردت ابنتها الأخرى أو أمرأة اجنبية اسمها زينب دين لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم نص عليه لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقه فلم يقبل تفسيره بها وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق فكذلك لما ذكرناه وقال القاضي هل يقبل في الحكم على روايتين

فصل

فإن كانت له زوجتان هند وزينب فقال يا هند فأجابته زينب فقال أنت طالق ينوي المجيبة أو لم يكن له نية طلقت المجيبة وحدها لأنها المخاطبة بالطلاق ولم يرد غيرها به وإن قال ظننت المجيبة هندا فطلقتها طلقت هند رواية واحدة لأنه أرادها بطلاقه وفي زينب روايتان إحداهما تطلق اختارها ابن حامد لأنه خاطبها بالطلاق فطلقت كما لو لم يكن له نية والثانية لا تطلق لأنه لم يردها بكلامه فلم تطلق كما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه بقوله أنت طالق وقال أبو بكر لا يختلف كلام أحمد أنها لا تطلق وإن قال علمت أن المجيبة زينب [ج ٣ - ص ٢٢٥]

وأردت طلاق هند طلقتا معا هند بإرادته وزينب بخطابه لها بالطلاق اختيارا ولو لقي اجنبية يظنها زوجته فقال أنت طالق طلقت زوجته لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق فطلقت كالتي قبلها وإن لقي زوجته فظنها أجنبية فقال تنحي يا مطلقة أو أمته فقال تنحي يا حرة يظنها أجنبية فقال أبو بكر لا يلزمه عتق ولا طلاق لأنه لم يقصد طلاقا ولا عتقا ويخرج على قول أبن حامد أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل

[ج ٣ - ص ٢٢٦]

إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله ارتجاعها مادامت في العدة لقوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ يريد الرجعة عند جماعة أهل التفسير وقال الله تعالى ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وروى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها متفق عليه وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها رواه أبو داود وإن انقضت عدتها لم يملك رجعتها لقوله تعالى ﴿ أحق بردهن في ذلك ﴾ وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة له لأنه لا عدة عليها فلا تربص في حقها يرتجعها فيه وكل هذا مجمع عليه بحمد الله

فصل

وإذا كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فله رجعتها قبل وضع الثاني

لأن العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله وإن طهرت ذات القرء من القرء الثالث ولم تغتسل ففيه روايتان إحداهما له رجعتها اختاره كثير من أصحابنا لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم والثانية لا رجعة له لقوله تعالى ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وهي الحيض وقد زال الحيض وهذا اختيار أبي الخطاب

فصل

ويملك رجعتها بغير رضاها لقوله تعالى ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ ولا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق لأنها إمساك وهل تفتقر إلى إشهاد فيه روايتان إحداهما تفتقر إلى الإشهاد لقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود أشبه النكاح والثانية لا يجب لأنه إمساك لا يفتقر إلى رضى المرأة أشبه التكفير في الظهار

فصل

والرجعية زوجة بدليل ان الله تعالى سمى الرجعة إمساكا وسمى المطلقين بعولة فقال سبحانه وتعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وخلعه ويرثها وترثه لأنها زوجه فثبت فيها ما ذكرنا كما قبل الطلاق [ج ٣ - ص ٢٢٨]

فصل

الرجعية مباحة لزوجها فلها التزين والتشرف له وله السفر بها والخلوة معها ووطؤها في ظاهر المذهب لقوله تعالى ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ وهذه زوجة وعنه أنها محرمة وهو ظاهر كلام الخرقي لأنها معتدة من طلاقه فحرمت عليه كالمختلعة فإن وطئها فلا حد عليه لأنها زوجته ولا مهر عليه كذلك ويحتمل أن يجب المهر على القول بالتحريم إذا أكرهها على الوطء لأنه وطء حرمه الطلاق فأشبه وطء المختلعة

فصل

وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب قصد أو لم يقصد لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار والوطء من المالك يمنع زواله كوطء البائع في مدة الخيار ولا يحصل باستمتاع سواء من قبلة أو لمس أو نظر إلى محرم منها في ظاهر كلام أحمد وقال ابن حامد يخرج فيه وجهان مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة فأما الخلوة بها فليست رجعة بحال لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها وقال بعض أصحابنا يحصل بها لأنه محرم من غير الزوجة فأشبه الاستمتاع وعن أحمد لا تحصل الرجعة إلا بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله تعالى ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾

ولا يحصل الإشهاد إلا على القول ولأنه استباحة عضو مقصود فأشبه النكاح

فصل

وألفاظ الرجعة راجعتك وارتجعتك لورود النص والسنة بهما في حديث ابن عمر واشتهارهما في العرف بهذا اللفظ ورددتك وأمسكتك لورود الكتاب بهما لقوله تعالى ﴿ أحق بردهن ﴾ وقوله تعالى ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ ويحتمل أن يكون الصريح لفظ المراجعة وحده لاشتهاره في العرف دون غيره وإن قال نكحتك أو تزوجتك ففيه وجهان أ حدهما تصح الرجعة به اختاره ابن حامد لأن الأجنبية تحل به فالزوجة أولى والثاني لا يصح لأنه وضع لابتداء النكاح وهذا لاستدامته فإن قال راجعتك للمحبة أو الإهانة فهي رجعة صحيحة لأنه أتى بصريح الرجعة وما قرنه به يحتمل أن يكون بيانا للعلة ويحتمل غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك فإن نوى به أنني راجعتك لمحبتي إياك أو لأهينك لم يقدح في الرجعة لأنه ضم إليها بيان علتها وان لم يرد الرجعة وإنما أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك أو إلى المحبة فليس برجعة لأنه قصد بلفظه غير الرجعة [ج ٣ - ص ٢٣٠]

فصل

ولا يصح تعليقها على شرط لأنه استباحة بضع فأشبهت النكاح ولو قال راجعتك إن شئت أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح وإن راجعها في الردة فقال أبو الخطاب لا يصح لأنه استباحة بضع فأشبه النكاح وقال القاضي إن قلنا بتعجل الفرقة فلا يصح وإن قلنا لا تتعجل فهي موقوفة إن أسلم صحت وإن لم يسلم لم تصح كما يقف الطلاق والنكاح وهذا اختيار ابن حامد

فصل

وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها لقوله تعالى ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على قبولها منهم وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله لأنه اختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء الأطهار أو في أقل من تسعة وعشرين إذا قلنا هي الحيض لأننا نعلم كذبها وإن ادعت انقضاءها بالقروء [ج ٣ - ص ٢٣١]

في شهر لم يقبل قولها إلا ببينة نص عليه لأنه يروى عن علي ولأن ذلك يندر جدا وظاهر قول الخرقي قبول قولها بمجرده لما ذكرنا

فصل

وإن ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته فالقول قوله لأنه يملك رجعتها فقبل قوله فيه كالطلاق فإن ادعى رجعتها بعد العدة فأنكرته فالقول قولها لأنه في زمن لا يملكها والأصل عدمها فإن كان في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فقالت قد انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك وأنكرته لم يقبل قوله لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول فصار دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضائها ولو سبق فقال قد كنت راجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء العدة وظاهر كلام الخرقي أن القول قولها في الحالين لأن من قبل قوله سابقا قبل مسبوقا كسائر الدعاوى وإن ادعى أنه أصابها ليثبت له رجعتها فأنكرته فالقول قولها لأن الأصل عدمها

فصل

فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادعى رجعتها وصدقته هي وزوجها ردت إليه لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول وإن

صدقه أحدهما دون الآخر قبل قوله وحده في حقه فإن صدقه الزوج انفسخ نكاحه لاعترافه بفساده ولم تسلم المرأة إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول وإن كان هذا قبل دخوله بها فلها عليه نصف المهر وإن كان بعده فلها الجميع بمنزلة طلاقها وإن صدقته المرأة وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها أنها ليست زوجة له فإن أنكراه فالقول قولهما فإن أقام بينة بدعواه قبلت وردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة الأول وعن أبي عبد الله رواية أخرى إن دخل بها الثاني فهي زوجته ويبطل نكاح الأول لأنه يروى عن عمر بن الخطاب ولأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول والأول المذهب

فصل

وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه انقطعت عدة الأول فإذا وضعت حملها أتمت عدة الأول وله رجعتها في هذا التمام لأنها في عدته وإن راجعها قبل الوضع ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنها في عدة غيره لا في عدته والثاني يصح لأن الزوجية باقية وإنما انقطعت عدته لعارض فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه [ج ٣ - ص ٢٣٣]

فصل

وإن وطىء الزوج الرجعية وقلنا لا تحصل الرجعة به فعليها استئناف العدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا وله ارتجاعها في بقية العدة الأولى وليس له ارتجاعها بعدها لأن عدة الطلاق انقضت

فصل

إذا طلق الحر زوجته ثلاثا أو طلق العبد زوجته طلقتين حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها لقوله تعالى ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ويشترط لحلها للأول شرطان أحدهما نكاح زوج غيره للآية فلو كانت أمة فوطئها سيدها أو وطئت بشبهة أو استبرءها من سيدها لم تحل له ولا بد أن يكون نكاحا صحيحا فلو نكحها نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل له وذكر أبو الخطاب وجها آخر أنه يحلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له فسماه محللا مع فساد نكاحه والمذهب الأول لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح وإنما سماه محللا لقصده التحليل فيما لا يحل له كقوله تعالى ﴿ فيحلوا ما حرم الله ﴾ فلو أحل حقيقة لم يكن هو والزوج ملعونين الثاني أن يطأها الزوج في الفرج وأدناه تغييب الحشفة

مع الانتشار لما روت عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير فقالت والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه فإن وطئها في الدبرأو دون الفرج أوغيب الحشفة من غير انتشار لم تحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بذواق العسيلة ولا يحصل بذلك فإن كان الذكر مقطوعا فبقي منه قدر الحشفة فأولجها أحلها وإلا فلا وإن كان خصيا أو مسلولا أو موجوءا حلت بوطئه لدخوله في عموم الآية وعنه لا يحلها لأنه لا تذاق عسيلته قال أبو بكر العمل على أنه يحلها لأنه لا يفقد إلا الانزال وهوغير معتبر في الإحلال ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي أحلها للمسلم لدخوله في الآية والخبر وكذلك المملوك والصبي والمجنون وقال ابن حامد لا يحلها المجنون لأنه لا يذوق العسيلة والأول المذهب لدخوله في عموم الآية والخبر ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة فإن المجنون كالصحيح في الشهوة واللذة وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في ذلك فإنه يوجد في البهائم مع عدم العقل وإن وطئها نائمة أو مغمى عليها أو وطئها يعتقدها أجنبية أو [ج ٣ - ص ٢٣٥]

استدخلت ذكره وهو نائم حلت لأن الوطء وجد في نكاح صحيح ويحتمل ألا تحل بالوطء في الإغماء لأنها لا تذوق عسيلته

فصل

واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالا فلو وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو صوم مفروض أو إحرام لم تحل لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلها كوطء المرتدة وظاهر النص أنه يحلها لدخوله في العموم ولأنه وطء تام في نكاح صحيح تام فأحلها كما لو كان التحريم لحق آدمي مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه فإنه لا خلاف في حلها به فأما الوطء في ردتها أو ردة أحدهما فلا يحلها لأنه إن عاد إلى الإسلام فقد وقع الوطء في نكاح غير تام لانعقاد سبب البينونة وإن لم تسلم في العدة فلم يصادف الوطء نكاحا

فصل

وإذا غابت المطلقة ثلاثا ثم أتت زوجها فذكرت أنها نكحت من أصابها كان ذلك ممكنا وكان يعرف منها الصدق والصلاح حلت له لأنها مؤتمنة على ما تدعيه وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقها لم تحل له لأن الأصل التحريم ولم يوجد غلبة ظن تنقل عنه فلم يحل كما لو أخبره فاسق غيرها فإن كذبها ثم غلب [ج ٣ - ص ٢٣٦]

على ظنه صدقها فصدقها حلت لأنه قد لا يعلم ثم يتجدد علمه بذلك وإن تزوجت زوجا ثم طلقها فادعت أنه اصابها فأحلها واستقر عليه مهرها فأنكر فالقول قولها في حلها لانها لاتدعي عليه حقا والقول قوله في استقرار مهرها لأنه حق عليه والأصل عدمه وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرها لم تحل للأول لأنه لم يثبت طلاقها فتبقى على نكاح الثاني

فصل

وإذا عادت المطلقة ثلاثا إلى زوجها بعد زواج وإصابة ملك عليها ثلاث تطليقات لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فوجب أن بستأنفها وإن كان طلاقها أقل من ثلاث رجعت إليه على ما بقي من طلاقها لأنها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي من العدد كما لو رجعت قبل نكاح آخر وعنه أنها إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق ثلاث لأنها رجعت بعد زوج وإصابة فأشبهت المطلقة ثلاثا

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر لقول الله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطء ولا يصح من غير زوج كالسيد يؤلي من أمته أو من أجنبية ثم يتزوجها لقوله تعالى ﴿ من نسائهم ﴾ ولا يصح من صبي ولا مجنون لأنه لا حكم ليمينهما فأما العاجر علن الوطء فإن كان لسبب يرجى زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه لأنه يمنع نفسه الوطء بيمينه فأشبه القادر وإن كان لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه لأنه حلف على ترك مستحيل فلم يصح كالحلف على ترك الطيران ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الجماع وهذا لا تمنعه منه يمينه ويحتمل أن يصح إيلاؤه كالعاجز بالمرض ويصح إيلاء الذمي لعموم الآية ولأن من صح طلاقه ويمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم [ج ٣ - ص ٢٣٨]

فصل

ويشترط لصحتة أربعة شروط أحدها الحلف لقوله تعالى ﴿ للذين يؤلون ﴾ والإيلاء الحلف فإن حلف بالله تعالى أوبصفة من صفاته كان مؤليا بغير خلاف وإن حلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو صدقة المال ونحوه ففيه روايتان إحداهما لا يكون مؤليا لأن ابن عباس قال في تفسير الآية يحلفون بالله هكذا ذكره الإمام أحمد ولأنه لم يحلف بالله فلم يكن مؤليا كالحلف بالكعبة والثانية يكون مؤليا لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق فيصح الإيلاء بها كاليمين بالله تعالى وقال أبو بكر ما أوجب الكفارة كالحرام كان به مؤليا وما لا كفارة فيه كالطلاق والعتاق لم يكن به مؤليا ولا يختلف المذهب أنه لايكون مؤليا بما يلزمه به حق كقوله إن وطئتك فأنت زانية لأنه لا يصح تعليق القذف بشرط فلا يلزمها بالوطء حق فلا يكون مؤليا ولو قال إن وطئتك فعلي صوم أمس أو صوم هذا الشهر لم يصح لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضيا ولا يصح نذر الماضي وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري صار مؤليا لأنه يلزمه بالوطء حق وهو تعيين عتق سالم وإن قال إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري إن تظاهرت

لم يكن مؤليا في الحال لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه وإن تظاهر صار موليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحق يلزمه

فصل

الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء في الفرج لأنه الذي يحصل الضرر به وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج فليس بمؤل لأنه لا ضرر فيه وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام

أحدها صريح في الظاهر والباطن وهي قوله والله لا آتيك أو لا أدخل أو لا أغيب أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا افتضك للبكر خاصة فهذه صريحة ولا يدين فيها لأنها لا تحتمل غير الإيلاء

والقسم الثاني صريحة في الحكم ويدين فيها وهي عشرة ألفاظ لا وطئتك لا جامعتك لا اصبتك لا باشرتك لا مسستك لا قربتك لا أتيتك لا باضعتك لا باعلتك لا اغتسلت منك فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في الوطء عرفا وقد ورد الكتاب والسنة ببعضها فلا يقبل تفسيرها بما يحيله كوطء القدم والإصابة باليد ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما قاله

القسم الثالث كناية وهو ما عدا هذه الألفاظ مما يحتمل الجماع وغيره كقوله لأسوأنك ولا دخلت عليك ولا جمع رأسي ورأسك شيء فهذا

لا يكون مؤليا بها إلا بالنية لأنها ليست ظاهرة في الجماع فلم يحمل عليه إلا بالنية ككنايات الطلاق فيه فإن قال والله لاجامعتك إلا جماع سوء ونوى به الجماع في الدبر أو دون الفرج فهو مؤل وإن نوى جماعا ضعيفا لا يزيد على تغييب الحشفة فليس بمؤل لأن الضعيف كالقوي في الحكم

فصل

الشرط الثالث ان يكون الحالف زوجا مكلفا قادرا على الوطء في الجملة وقد ذكرنا ذلك

الشرط الرابع أن يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها لم يكن مؤليا حرا كان أو عبدا من أمة أو حرة لقوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ فدل على أنه لايكون مؤليا دونها ولأن المطالبة بالطلاق والفيئة إنما تكون بعدها فلا تصح المطالبة من غير إيلاء فإذا قال والله لا وطئتك كان مؤليا لأنه يقتضي التأبيد وكذلك إن قال حتى أموت أو تموتي لأنه للتأبيد وكذلك إن علقه على مستحيل فقال حتى تطيري ويشيب الغراب ويبيض القار لأن معناه التأبيد قال الله تعالى ﴿ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ أي لا يلج الجمل في سم الخياط أي لا يدخلونها [ج ٣ - ص ٢٤١]

أبدا وإن علقه على فعل يتيقن أويغلب على ظنه أنه لا يوجد في أربعة أشهر كقيام الساعة وخروج الدجال ونزول عيسى من السماء أو موت زيد فهو مؤل لأنه لا يوجد في أربعة أشهر ظاهرا فأشبه ما لو صرح به وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤل لأنها لا تحبل من غير وطئه فهو كالحلف على ترك الوطء أبدا وقال القاضي إن كانت ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا ولا أعلم لهذا وجها لأنه لا تحمل حينها من غير وطء وإن قال أردت ب حتى السببية أي لا أطؤك لتحبلي قبل منه لأنه يحتمل ما قاله ولا يكون مؤليا لأنه يمكن وطؤها لغير ذلك وإن علقه على ما يعلم وجوده قبل أربعة أشهر كجفاف بقل أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه وقدوم الحاج في زمانه أو ما يحتمل الأمرين على السواء كقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤليا لانه لم يغلب على الظن وجود الشرط فلا يثبت حكمه وإن قال والله ليطولن تركي لجماعك ونوى مدة الإيلاء فهو مؤل وإلا فلا وإن قال والله لأسوءنك ولتطولن غيبتي عنك ونوى ترك الجماع في مدة الإيلاء فهو مؤل لأنه عنى بلفظه ما يحتمله وإلا فلا وإن قال والله لاوطئتك طاهرا أوطئا مباحا فهو مؤل لأنه حلف على ترك الوطء الذي يطالب به في الفيئة فكان مؤليا كما لو قال والله لا وطئتك إلا في الدبر [ج ٣ - ص ٢٤٢]

فصل

وإن قال والله لا وطئتك في هذا البيت أو البلد لم يكن مؤليا لأنه يمكنه الوطء بغير حنث وإن قال والله لاوطئتك إلا برضاك أو إلا أن تشائي فليس بمؤل كذلك وكذلك والله لا وطئتك مريضة أومحزونة أو مكرهة أو ليلا أو نهارا لم يكن مؤليا كذلك وإن قال والله لاوطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا وإلا فلا

فصل

ويصح تعليق الإيلاء على شرط لأنه يمين فإذا قال إن وطئتك فوالله لاوطئتك لم يصر مؤليا في الحال لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث فإذا وطئها صار مؤليا لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحنث وإن قال والله لا وطئتك في هذه السنة إلا مرة لم يصر مؤليا في الحال كذلك فإذا وطئها وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صار مؤليا لأنه صار ممنوعا من طئها بيمينه وإن قال والله لا وطئتك سنة إلا يوما فكذلك لأن اليوم منكر فلم يختص يوما بعينه فصارت كالتي قبلها ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة كما في التأجيل [ج ٣ - ص ٢٤٣]

فصل

فإن قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك نصف عام دخلت المدة الثانية في الأولى لأنها بعضها ولم يعقب إحداهما بالأخرى فتداخلا كما لو قال له علي مائة ثم قال له علي خمسون فإن قال والله لأوطئتك عاما فإذا مضى فوالله لاوطئتك نصف عام فيها إيلا آن في زمانين لا يدخل حكم أحدهما في الآخر فإذا انقضى حكم الأول ثبت حكم الآخر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فولاالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يكن مؤليا لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر ويحتمل أن يكون مؤليا لأنه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر

فصل

وإن قال لأربع نسوة والله لا أطأكن انبنى على أصل وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه أم لا فيه روايتان إحداهما بحنث فيكون مؤليا في الحال منهن لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بحنث فإذا وطىء واحدة انحلت يمينه لأنها يمين واحدة فتنحل بالحنث فيها كما لو حلف على واحدة وعلى الأخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا في الحال لأنه يمكن وطء كل واحدة بغير حنث فإذا وطىء ثلاثا [ج ٣ - ص ٢٤٤]

صار مؤليا من الرابعة وابتداء المدة حينئذ فإن مات بعضهن أو طلقها انحل الإيلاء لأنه أمكنه وطء الباقيات بغير حنث وإن قال والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا في الحال لأنه لا يمكنه الوطء الا بحنث فإن طلق واحدة منهن أو ماتت كان مؤليا من الباقيات لأنه تعلق بكل واحدة منهن منفردة وإن وطىء واحدة سقط الإيلاء من الباقيات لأنها يمين واحدة فإذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة ثانية وإن نوى واحدة بعينها كان مؤليا منها وحدها ويقبل قوله في ذلك لأن اللفظ يحتمله وهو أعلم بنيته وإن قال نويت واحدة غير معينة قبل لأنه يحتمل ذلك وقياس المذهب أن يخرج المؤلي منها بالقرعة كالطلاق وذكر القاضي أن الحكم فيمن أطلق يمينه ولم ينو شيئا كذلك والأول أولى لأنه نكرة في سياق النفي فيكون عاما ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن ولم يقبل قوله نويت واحدة لأن لفظه لا يحتمل ذلك وتنحل اليمين بوطء واحدة لما ذكرنا فإن طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن وإن اختلفت مطالبتهن وقف لكل واحدة عند طلبها لأنه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها وعنه يوقف لهن جميعا عند طلب أولاهن لأنها يمين واحدة فكان الوقف لها واحدا وإن قال لزوجتيه كلما وطئت إحداكن فالأخرى طالق وقلنا بكونه إيلاء فهو مؤل منهما [ج ٣ - ص ٢٤٥]

فصل

فإن قال والله لا وطئتك ثم قال للأخرى شركتك معها لا يصير مؤليا من الثانية لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أوصفة وهكذا كناية وقال القاضي يكون مؤليا منهما وإن قال إن أصبتك فأنت طالق وقال للأخرى شركتك معها ونوى وقلنا بكونه إيلاء من الأولى صار مؤليا من الثانية لأن الطلاق يصح بالكناية ولو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى شركتك معها كان مظاهرا منهما لأن الظهار تحريم فصح بالكناية كالطلاق وهل يفتقر إلى نية فيه وجهان أحدهما لا يفتقر إليها ذكره أبو الخطاب لأنه ليس بصريح في الظهار فافتقر إلى النية كسائر كناياته

فصل

ولا يطالب المؤلي بشيء قبل أربعة أشهر للآية وابتداء المدة من حين اليمين لأنها ثبتت بالنص والإجماع فلم تفتقر إلى حاكم كمدة العدة فإن كان بالمرأة عذر يمنع الوطء كصغر أو مرض أو نشوز أو جنون أو إحرام أو صوم فرض أو اعتكاف فرض لم يحتسب عليه بمدته لأن المنع منها وإن طرأ منه شيء انقطعت المدة لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطء ولا امتناع منه مع العذر ويستأنف المدة عند زوال العذر لأن من

شأنها أن تكون متوالية ويحتسب بمدة الحيض لأنه عذر معتاد لا ينفك منه فلو قطع المدة سقط حكم الإيلاء وكذلك لا يقطع التتابع في الصيام وفي النفاس جهان أحدهما هو كالحيض لأنه مثله في أحكامه والثاني هو كالمرض لأنه عذر نادر أشبه المرض وإن كان بالزوج عذر حسبت عليه مدته ولم يقطع المدة طريانه لأن الامتناع من جهته والزوجية باقية فحسبت عليه المدة وإن آلى من الرجعية احتسب عليه بالمدة ذكره ابن حامد وإن طرأ الطلاق الرجعي لم يقطع المدة لأن الرجعية مباحة ويحتمل أن تنقطع إذا قلنا بتحريمها وإن طلقها طلاقا بائنا انقطعت المدة لأنها حرمت عليه فإذا تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر استؤنفت المدة سواء كان الطلاق في المدة أو بعدها

فصل

وإن وطئها حنث وسقط الإيلاء لزوال اليمين والضرر عنها سواء وطئها يقظانة أو نائمة أو عاقلة أو مجنونة وهكذا إن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام أو ظهار لما ذكرنا وقال أبو بكر قياس المذهب ألا يخرج من حكم الإيلاء بالوطء الحرام لانه لا يؤمر به في الفيئة فهو كالوطء في الدبر والأول أولى لأن اليمين تنحل به فيزول الإيلاء بزوالها وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث لأن القلم عنه مرفوع [ج ٣ - ص ٢٤٧]

ويسقط الإيلاء لانه وفاها حقها ويحتمل ألا يسقط لأن حكم اليمين باق لو أفاق لمنعته اليمين الوطء وقال أبو بكر يحنث ويحل الإيلاء لأنه فعل ما حلف عليه وإن وطئها ناسيا فهل يحنث على روايتين أصحهما لا يحنث فعلى هذا هل يسقط الإيلاء على وجهين كما ذكرنا في المجنون وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث لأنه ما وطىء وهل يسقط الإيلاء على وجهين لما ذكرنا وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به وإن وطئها في الدبر أو دون الفرج لم يعتد به لأن الضرر واليمين لا يزولان به

فصل

وإذا وطىء لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه وإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع لأنه معلق على شرط قد وجد وإن كان عل نذر خير بين الوفاء به والتكفير لأنه نذر لجاج وهذا حكمه وإن كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحل له الوطء لأن آخره يقع في أجنبية ويوقع طلاق البدعة من وجهين جمع الثلاث ووقوعه بعد الإصابة وذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين فإن وطىء فعليه النزع حين يولج لان الحنث حصل به فصارت أجنبية فإذا فعل هذا فلا حد عليه ولا [ج ٣ - ص ٢٤٨]

مهر لأنه تارك للوطء وإن لبث أو أتم الايلاج فلا حد أيضا لتمكن الشبهة منه لكونه وطئا بعضه في زوجة وفي المهر وجهان أحدهما يجب لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطىء بعد النزع والثاني لا يجب لأنه إيلاج في محل مملوك فكان آخره تابعا له في سقوط المهر ويلحق النسب به وإن نزع ثم أولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان زنا لا شبهة فيه فعليهما الحد ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة أو جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر وإن جهلا التحريم معا فلا حد ويجب لها المهر ويلحقه النسب وإن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فقال أحمد لا يطأ حتى يكفر يريد أنه إذا وطئها مرة لم يكن له أن يطأها ثانيا حتى يكفر لأنها تصير محرمة عليه بالظهار فأما قبل ذلك فلا يصح منه التكفير لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها

فصل

وإن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيئة أو الطلاق لقوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ فإن سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وإن عفت عنها سقط حقها في أحد الوجهين كما لو عفت

امرأة العنين والآخر لا يسقط ولها الرجوع والمطالبة لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطء وذلك يتجدد مع الأحوال فأشبه النفقة والقسم وإن طلب الامهال ولا عذر له لم يمهل لأن الحق حال عليه وهو قادر وإن كان ناعسا فقال أمهلوني حتى يذهب النعاس أو جائعا فقال أمهلوني حتى أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أفطر من صيامي أمهل بقدر ذلك ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال فإن وطئها فقد وفاها حقها وإن أبى ولا عذر له أمر بالطلاق إن طلبت ذلك فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه ولا يطالب بأكثر من طلقة لأنها تفضي إلى البينونة فإن امتنع طلق الحاكم عليه لأنه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه كقضاء دينه وعن أحمد لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق لأن ما خير فيه بين شيئين لم يقم الحاكم مقامه فيه كاختيار إحدى الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربع فإن قلنا إن الحاكم يملك الطلاق فله أن يطلق واحدة وثلاثا لأنه قائم مقام الزوج فملك ما يملكه فإن طلق الزوج أو الحاكم ثلاثا حرمت عليه إلا بزوج وإصابة فإن طلق أحدهما أقل من ثلاث فله رجعتها وعن أحمد أنها تكون طلقة بائنة لأنها شرعت لدفع الضرر الحاصل منه فوجب أن لا يملك رجعتها كالمختلعة وعنه أن تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد لأنه تفريق حاكم فأشبه [ج ٣ - ص ٢٥٠]

فرقه اللعان والأول أصح لأنه لم يستوف عدد طلاقها فلم تحرم على التأبيد كما لو طلق الزوج وإن قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسخ للنكاح لا تحل له إلا بنكاح جديد نص عليه ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها أو تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها لأنه ممتنع من وطئها بيمين في حال الزوجية فأشبه ما لو راجعها وإن بقي أقل من أربعة أشهر لم يثبت حكم الإيلاء لقصوره عن مدته

فصل

وإن انقضت المدة وهي حائض أو نفساء لم تطالب بالفيئة لأنها لا تستحق الوطء في هذه الحال وإن كان مغلوبا على عقله لم يطالب أيضا لأنه لا يصلح لخطاب ولا يصح منه جواب وإن كان مريضا أو محبوسا لا يمكنه الخروج طولب بفيئة المعذور وهو أن يقول متى قدرت جامعتها أو نحو ذلك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بما أتى به من الاعتذار فمتى قدر على الوطء طولب به لأنه تأخر للعذر فإذا زال العذر طولب به كالدين وهذا اختيار الخرقي وقال أبو بكر إذا فاء فيئة المعذور لم يطالب لأنه فاء مرة فلم يلزمه فيئة أخرى كالذي فاء بالوطء لا يلزمه بالفيئة باللسان كفارة لأنه لم يحنث وإن كان غائبا لا يمكنه

القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور وإن أمكنه القدوم فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق وإن كان محرما فاء فيئة المعذور في قول الخرقي لأنه عاجز عن الوطىء أشبه المريض ويتخرج في الاعتكاف المنذور مثله وإن كان مظاهرا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم ولا يحل الأمر بمعصية الله ويقال له إما أن تكفر وتفيء وإما أن تطلق فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام لأنها قريبة وإن علم أنه قادر على التكفير وأن قصده لمدافعة لم يمهل لأن الحق حال عليه وإنما يمهل للحاجة ولا حاجة وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم لأنه كثير وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها ويتخرج أن يفيء المظاهر فيئة المعذور ويمهل ليصوم كالمحرم فإن أراد الوطء في حال الإحرام أو الظهار فمنعته لم يسقط حقها لأنها منعته مما يحرم فأشبه ما لو منعته في الحيض وذكر القاضي أنه يسقط حقها لأنها منعته من إيفائه وإن انقضت مدة العاجز لجب أو شلل ففيئته لو قدرت لجامعتك لأنه لا قدرة له على غير ذلك [ج ٣ - ص ٢٥٢]

فصل

ومن طولب بالفيئة فقال قد وطئتها فأنكرته فإن كانت ثيبا فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح وعدم ما يوجب إزالته وهل يحلف على روايتين إحداهما يحلف وهو اختيار الخرقي لأن ما تدعيه المراة محتمل فوجب نفيه باليمين والأخرى لا يمين عليه اختاره أبو بكر لأنه لا يقضي فيه بالنكول وإن كانت بكرا أريت النساء الثقات فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها لأنه يعلم كذبه وإلا فالقول قوله وإن ادعى عجزه عن الوطء ولم يكن علم انه عنين ففيه وجهان أحدهما لا يقبل قوله لأن الأصل سلامته فيؤمر بالطلاق والثاني يقبل قوله لأنه لا يعرف إلا من جهته وإن اختلفا في انقضاء المدة فالقول قول الزوج لأنه اختلاف في وقت حلفه فكان القول قوله فيه وهل يحلف على روايتين والله أعلم

فصل

وإن ترك الزوج الوطء بغير يمين فليس بمؤل لأن الإيلاء من شرطه الحلف فلا يثبت بدونه لكن إن تركه مضرا بها لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه شيء لأنه ليس بمؤل فلا يثبت له حكم كما لو تركه لعذر

ولأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه والثانية تضرب له مدة الإيلاء وتوقف بعدها كالمؤلي سواء لأنه تارك لوطئها مضرا بها فأشبه المؤلي ولأن مالا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه كالزيادة على الواجب وثبوت حكم الإيلاء له لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس والله أعلم

[ج ٣ - ص ٢٥٤]

وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وما أشبهه وهو محرم لقوله تعالى ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ ويصح من كل زوج يصح طلاقه لأنه قول يختص النكاح فأشبه الطلاق إلا الصبي فلا يصح منه لأنه يمين موجبة للكفارة أشبه اليمين بالله وقال القاضي ظهاره كطلاقه لما ذكرناة أولا ويصح ظها ر الذ مي لأنه مكلف يصح طلا قه فصح ظهاره كالمسلم ولا يصح ظهار السيد من أمته لقوله تعالى ﴿ من نسائهم ﴾ نخص به الزوجات فإن ظاهر منها أو حرمها فعليه كفارة يمين كما لو حرم طعامه وعنه عليه كفارة ظهار قال أبو الخطاب ويتوجه ألا يلزمه شيء كما لو ظاهرت المرأة من زوجها فإن ظاهر من أجنبية ثم تزوجها أو قال كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمي ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر لما روى أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال إن تزوجت فلانه فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها قال عليه كفارة الظهار ولانها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى

فصل

فإن قال أنت علي كظهر أمي أو ظهر من يحرم عليه على التأبيد كجدته وسائر ذوات محارمه من النسب والرضاع أو المصاهرة فهو مظاهر لأنه شبهها بظهر من هي محل للاستمتاع تحرم عليه على التأبيد فكان مظاهرا كما لو قال أنت علي كظهر أمي وان شبهها بمن يحرم في حال كأخت زوجته وعمتها أو الأجنبية ففيه روايتان إحداهما هي ظهار اختاره الخرقي وأبو بكر لأنه تشبيه بمحرم عليه أشبه تشبيهها بالأم والأخرى ليس بظهار لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد أشبه تحريمها بالمحرمة والصائمة وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا لأنه ليس محلا للاستمتاع وإن قال أنت علي كظهر أبي ففيه روايتان أحدهما هو ظهار لأنه شبهها بمحل محرم على التأبيد أشبه التشبيه بظهر الأم والأخرى ليس بظهار لأنه ليس محل للاستمتاع أشبه التشبيه بالبهيمة

فصل

فان قال أنت عندي أو معي أو مني كظهر أمي فهو ظهار لأنه تقيد بما يفيده قوله أنت علي كظهر أمي وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال أنت علي كفرج أمي أو يدها أو رأسها فهو ظهار لأن غير الظهر [ج ٣ - ص ٢٥٦]

كالظهر في التحريم فكذلك في الظهار به وإن شبه عضوا منها بظهر أمه أو عضوا من أعضائها فقال ظهرك علي كظهر أمي أو رأسك علي كرأس أمي فهو مظاهر لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه كالشعر والسن والظفر لا يتعلق الظهار به لما ذكرنا

فصل

فإن قال أنت على كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر فإن نوى به التشبيه في الكرامة أو نحوها فليس بظهار لأنه يحتمل مقاله وعنه ليس يظهارحتى ينويه لأنه يحتمل غير الظهار كاحتماله فلم يصرف إليه إلا بنية ككنايات الطلاق وإن قال أنت كأمي أو مثلها فليس بظهار إلا أن ينويه لأنه في غير التحريم أظهر وقال أبو الخطاب هي كالتي قبلها وهكذا يخرج في قوله رأسك كرأس أمي أو يدك كيدها وما أشبهه وقياس المذهب أنه إن وجدت قرينة صارفه إلى الظهار مثل أن يخرجه مخرج اليمين كقوله إن خرجت من الدار فأنت عندي كأمي وشبهه فهو ظهار لأن القرينة صارفة إليه وإلا لم يكن ظهارا لتردد الاحتمالات فيه وإن قال أنت حرام كأمي فهو صريح في الظهار لأنه لا يحتمل سوى التحريم [ج ٣ - ص ٢٥٧]

فصل

وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا لانه أوقع الطلاق صريحا فوقع وبقي قوله كظهر أمي غير متعلق بشيء فلم يقع فإن نوى به الطلاق والظهار معا فهو ظهار وطلاق وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لأنه صريح في موجبه فلم ينصرف إلى غيره بالنية كما لو نوى بقوله أنت علي كظهر أمي الطلاق

فصل

ويصح الظهار مؤقتا كقوله أنت علي كظهر أمي شهرا لماروى سلمة بن صخر قال ظاهرت من أمرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال حرر رقبة رواه أبو داود ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها كاليمين بالله تعالى فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار ويجوز تعليقه شرط كدخول الدار لذلك فإذا وجد الشرط ثبت حكم الظهار وإن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصر مظاهرا لما ذكرنا [ج ٣ - ص ٢٥٨]

فصل

وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ فعلقه على الزوج ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة يملك الزوج رفعه فاختص الرجل كالطلاق وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات إحداهن عليها كفارة الظهار لما روى إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة رواه الأثرم ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظ فلزمتها كفارة الظهار كالرجل والثانية لا شيء عليها لأنه تشبيه غير ظهار فلم يوجب الكفارة كقولها أنت علي كظهر البهيمة والثالثة عليها كفارة يمين أو مأ إليها بقوله قد ذهب عطء مذهبا جعلها بمنزلة من حرم على نفسه شيئا من الطعام وهذا أقيس في مذهبه لأنه تحريم لحلال غير الزوجة فأوجب كفارة يمين كتحريم الأمة وعليها التمكين قبل الكفارة لأنه حق عليها ولا يسقط بيمينها ولأنه قول غير الظهار موجب للكفارة فأشبه اليمين بالله تعالى

فصل

وإذا صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ [ج ٣ - ص ٢٥٩]

والعود هو الوطء في ظاهر كلام أحمد والخرقي قال أحمد العود الغشيان لأن العود في القول فعل ضد ما قال كما أن العود في الهبة هو استرجاع ما وهب فالمظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله وقال القاضي وأصحابه العود العزم على الوطء لأن الله تعالى أمر بالتكفير عقيب العود قبل التماس بقوله تعالى ﴿ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير لقوله تعالى ﴿ من قبل أن يتماسا ﴾ فإن وطأ قبله أثم واستقرت الكفارة عليه ولم يجب عليه أكثر منها لحديث سلمة حين وطىء فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من كفارة وتحريمها باق حتى يكفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمه ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر وأما قبل الوطء فلا كفارة عليه وإنما أمر بها لكونها شرطا لحل الوطء كاستبراء الأمة المشتراة فإن فات الوطء بموت أحدهما أو فرقتهما فلا كفارة عليه لذلك وإن عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر وقال أبو الخطاب إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة وهذا مقتضى قول من وافقه وقد صرح أحمد بانكاره وكذلك قال القاضي لا كفارة عليه [ج ٣ - ص ٢٦٠]

فصل

وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع كالقبلة واللمس روايتان إحدا هما يحرم لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والثانية لا تحرم لأنه تحريم يتعلق بالوطء فيه كفارة فلم يتجاوز الوطء كتحريم الحيض ولأن المسيس هنا كناية عن الوطء فيقتصر عليه

فصل

وإذا ظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات فعليه لكل واحدة كفارة لأنها أربع أيمان في محال مختلفة فأشبه ما لو وجدت في أربعة أنكحة قال ابن حامد والقاضي هذا المذهب رواية واحدة وقال أبو بكر فيه رواية أخرى يجزئه كفارة واحدة لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ولأن الكفارة حق الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدود وإن ظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة رواية واحدة لما روى ابن عباس أن عمر سئل عن رجل ظاهر من نسوة فقال يجزئه كفارة واحدة ولأنها يمين واحدة فلم توجب أكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى وإن ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة في ظاهر المذهب لأن اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة فلم يجب بها كفارة الظهار كاليمين بالله وعن أحمد

ما يدل على أنه ان نوى بالثانية الاستئناف وجب بها كفارة ثانية لأنه قول يوجب تحريما في الزوجة فإذا نوى به الاستئناف تعلق به حكم كالطلاق والمذهب الأول فأما إن كفر عن الأولى فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة لأنها أثبتت في المحل تحريما أشبهت الأولى وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ثم تزوج نساء في عقد واحد فكفارة واحدة وإن تزوجهن في عقود فكذلك في إحدى الروايتين لأنها يمين واحدة والأخرى لكل عقد كفارة فلو تزوج امرأتين في عقد وأخرى والأخرى لكل عقد كفارة فلو تزوج امرأتين في عقد وأخرى في عقد لزمته كفارتان لأن لكل عقد حكم نفسه فتعلق بالثاني كفارة كالأول

فصل

وإن ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها فقال الحرقي لا يطؤها حتى يكفر يعني كفارة الظهار لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ وقال أبو بكر عليه كفارة يمين لا غير لأنها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة ظهار كما لو تظاهر منها وهي أمة فإن أعتقها عن كفارته جاز فإذا تزوجها بعد ذلك لم يعد حكم الظهار والله تعالى أعلم [ج ٣ - ص ٢٦٢]

2 باب كفارة الظهار 2

الواجب فيهاتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ وروى أبو داود بإسناده عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه فما برحت حتى نزل القرآن ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قلت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله إن شيخ كبير مابه من صيام قال فليطعم ستين مسكينا فمن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له من مؤنة عياله ونحوه لزمه العتق لأنه واجد فإن كانت له رقبة لا يستغني عن خدمتها لكبره أو لمرضه أو لكونه ممن لا يخدم نفسه أو يحتاج إليها لخدمة زوجته التي يلزمه إخدامها أو يتقوت بغلتها أو يتعلق بها حاجة لا بد منها لم يلزمه عقتها لأن ما تستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن معه ماء يحتاج إليه للعطش في التيمم فإن كانت فاضلة عن حاجته الأصلية لزمه عتقها لانه مستغن عنها وإن كان ماله [ج ٣ - ص ٢٦٣]

غائبا ففيه وجهان أحدهما له التكفير بالصيام لأن عليه ضررا في تحريم الوطء إلى حضور المال فكان له الصوم كالمعسر والثاني لا يجزئه إلا العتق لأنه مالك لما يشتري به رقبة ولأنه فاضل عن كفايته ولو كان ذلك في كفارة القتل والجماع لم يكن له التكفير بالصيام لأنه قادر على التكفير بالعتق من غير ضرر فلزمه كمن ماله حاضر ويحتمل أن يجوز له الصوم لأنه عاجز في الحال أشبه المظاهر

فصل

والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين لأنها تجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد والثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى الأداء فأي وقت قدر على العتق لزمه لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج فإن لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال إلى العتق لأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل فأشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى فله ذلك لأنه الأصل فيجزئه كسائر الأصول إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له إلا الصوم لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب فكذلك

فصل

ولا يجزىء في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ نص على المؤمنة في كفارة القتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها وعنه يجزئه في سائر الكفارات ذمية لإطلاق الرقبة فيها

فصل

ولا يجزىء إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف ولا يحصل هذا مع العيب المذكور فلا يجزىء الأعمى لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصير ولا الزمن ولا مقطوع اليد أو الرجل لأنه يعجز عن أعمال كثيرة ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد لأن نفعها يبطل بهذا ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة كذلك وقطع أنملتين من أصبع كقطعها لأن نفعها يذهب بذلك ولا يمنع قطع أنملة واحدة لأنها تصير كالأصبع القصيرة إلا الإبهام فإنها أنملتان فذهاب إحداهما كقطعها لذهاب نفعها وإن قطعت الخنصر من يد والبنصر من أخرى لم يمنع لأن نفع اليد لا يبطل به ولا يجزىء الأعرج عرجا فاحشا لأنه يضر بالعمل فهو كقطع الرجل فإن كان عرجا يسيرا أجزأ لأنه لا يضر ضررا بينا

ولا يجزىء الأخرس الذي لا تفهم إشارته فإن فهمت إشارته فالمنصوص أن الأخرس لا يجزىء وقال القاضي وأبو الخطاب يجزىء إلا أن يجتمع معه الصمم فإنهما إذا اجتمعا ضررا بينا ولا يجزىء المجنون جنونا مطبقا لأنه لا يصلح لعمل ولا من أكثر زمنه الجنون لأنه يعجز عن العمل في أكثر زمنه فإن كان أكثره الإفاقة ولا يمنعه من العمل أجزأ لعدم الضرر البين

فصل

ويجزىء الأعور لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين وأجدع الأنف والأذنين والأصم لأنه كغيره في العمل ويجزىء الخصي والمجبوب كذلك ويجزىء المرهون والجاني والمدبر وولد الزنى كذلك ويجزىء الأحمق وهو الذي يخطىء ويعتقد خطأه صوابا ويجزيء المريض المرجو برؤه والنحيف القادر على العمل فأما من لا يرجى برؤه أو لا يقدر على العمل فلا يجزىء لأنه لا عمل فيه ويجزىء عتق الغائب المعلوم حياته لأنه ينتفع بنفسه حيث كان وإن شك في حياته لم تبرأ ذمته لأن الوجوب ثابت بيقين فلا يزول بالشك فإن تبين أنه كان حيا تبينا أن الذمة برئت بعتقه

فصل

ولا يجزىء عتق الجنين لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب فإن أعتق

صبيا فقال الخرقي لا يجزئه حتى يصلي ويصوم لأن الإيمان قول وعمل ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزىء في الكفارة كالمجنون وقال القاضي لا يجزىء من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد وقال في موضع آخر يجزىء عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين وقال أبو بكر وغيره يجزىء الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه فأجزأ كالمريض المرجو ولا يجزىء عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزمن

فصل

ولا يجزىء عتق أم الولد في ظاهر المذهب لأن عتقها مستحق بسبب آخر فلم يجزىء كعتق قريبه ولأن الرق فيها غير كامل بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها وعنه تجزىء لأنها رقبة فتتناولها الآية بعمومها وفي المكاتب ثلاث روايات إحداهن يجزىء مطلقا والأخرى لا يجزىء مطلقا ووجههما ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء ما ذكرنا والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزىء لأنه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة وإن لم يؤد شيئا أجزأ لأنه لم يقتض عن شيء منها أشبه المدبر

فصل

وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم

[ج ٣ - ص ٢٦٧]

يجزئه لأن عتقه مستحق في الكفارة فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه عن الكفارة وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزه كذلك ولو قال إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي ثم وطئها وأعتق العبد عن ظهاره أجزأه لأنه لم يتعين عتقه عن الإيلاء بل هو مخير بين عتقه وبين كفارة يمين

فصل

ولو ملك نصف عبد وهو موسر فأعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن كفارته لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه وحكاه صاحبه عن أحمد لأن عتق النصيب الذي لشريكه استحق بالسراية فلم يجزه كما لو اشترى قريبه ينوي به التكفير وقال غيرهما يجزىء لأن حكم السراية حكم المباشرة بدليل أنه لو جرحه فسرى إلى نفسه كان كمباشرة قتله وإن كان معسرا عتق نصيبه فإن ملك نصفه الآخر فأعتقه عن الكفارة أجزأه لأنه أعتق جميعه في وقتين فأجزأ كما لو أطعم المساكين في وقتين وإن أعتق نصف عبدين فقال الخرقي يجزىء لأن أبعاض الجملة كالجملة في الزكاة والفطرة كذلك في الكفارة وقال أبو بكر لا يجزىء لأن المقصود تكميل الأحكام ولا يحصل بإعتاق نصفين فعلى قوله إذا أعتق الموسر نصف عبد عتق جميعه ولا يجزئه إعتاق نصف آخر فإن أعتق عبده عن كفارة غيره بغير إذنه لم

يجزئه لأنها عبادة فلم تجز عن غيره بغير أمره مع كونه من أهل الأمر كالحج إلا أن يكون ميتا فيجزىء عنه لأنه لا سبيل إلى إذنه فصح من غير إذنه كالحج عنه وإن أعتقه عن كفارة حي بأمره صح وأجزأ عن الكفاة ر إذا نواها لأنه أعتق عنه بأمره فأجزأه كما لو ضمن له عوضا وعنه لا يجزىء إلا أن يضمن له عوضا لأن العتق بغير عوض كالهبة ومن شرطها القبض ولم يحصل

فصل في الصيام

ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام لزمه صيام شهرين متتابعين فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام شهرين بالأهلة تامين كانا أو ناقصين وإن دخل في أثناء شهر صام شهرا بالهلال وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين يوما لما ذكرنا فيما تقدم فإن أفطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الشهرين لأنه أمكنه التتابع فلزمه وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخوف أو جنون أو إغماء لم ينقطع التتابع لأنه لا صنع لها في الفطر وإن أفطر لسفر فظاهر كلام أحمد أنه لاينقطع التتابع لأنه عذر مبيح للفطر أشبه المرض ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف أنه يقطع التتابع لأنه أفطر باختياره فقطع التتابع كالفطر لغير عذر وإن أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما فهما كالمريض وإن أفطرتا خوفا على ولديهما

احتمل أن لا ينقطع التتابع لأنه عذر مبيح للفطر أشبهواحتمل ان ينقطع المرض لأن الخوف على غيرهما ولذلك اوجب الكفارة مع قضاء رمضان ومن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أفطر وفي قطع التتابع وجهان بناء على ما تقدم وإن نسي التتابع أو تركه جاهلا بوجوبه انقطع لأنه تتابع واجب فانقطع بتركه جهلا ونسيانا كالموالاة في الطهارة وإن أفطر يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق لم ينقطع به التتابع لأنه فطر واجب أشبه الفطر للحيض ويكمل الشهر الذي أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوما لأنه بدأ من أثنائه وإن صام ذا الحجة قضى أربعة أيام وحسب بقدر ما أفطر لأنه بدأ من أوله وإن قطع صوم الكفارة بصوم رمضان لم ينقطع التتابع لأنه زمن منعه الشرع صومه في الكفارة أشبه زمن الحيض وإن صام في أثناء الشهرين عن نذر أو قضاء أو تطوعا انقطع التتابع لأنه قطع صوم الكفارة اختيارا لسبب من جهته فأشبه ما لو أفطر لغير عذر وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس قدم صوم الكفارة عليه وقضاه بعدها وكفر لأنه لو صامه لم يمكنه التكفير بحال

فصل

وإن وطىء التي ظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف لقوله

تعالى ﴿ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ﴾ فأمر بهما خاليين عن التماس ولم يوجد وعنه لا ينقطع التتابع لأنه وطء لا يفطر به فلم يقطع التتابع كوطء غيرها وإن وطء غيرها ليلا لم يقطع التتابع لأنه غير ممنوع منه وإن وطئها نهارا ناسيا أفطر وانقطع التتابع وعنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع به

فصل في الاطعام

ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال أو شبق شديد أو نحوه لزمه إطعام ستين مسكينا لأن سلمة بن صخر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة شبقه أمره بالإطعام وأمر أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام فإن قدر على ستين مسكينا لم يجزئه أقل منهم وعنه يجزئه ترديد الإطعام على واحد ستين يوما لأنه في معنى إطعام ستين مسكينا لكونه قد دفع في كل يوم حاجة مسكين وعنه لا يجزئه إلا إطعام ستين مسكينا سواء وجدهم أو لم يجدهم لظاهر قوله ﴿ فإطعام ستين مسكينا ﴾ والمذهب أن ذلك يجزىء مع تعذر المساكين للحاجة ولا يجزىء مع وجودهم لأنه أمكن امتثال الأمر بصورته ومعناه [ج ٣ - ص ٢٧١]

فصل

والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير لما روى الامام أحمد بإسناده قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق وشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر وهذا نص ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى وأما المد من البر فيجزىء لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ويجب أن يملك كل فقير هذا القدر فإن دفعه إليهم مشاعا فقال هذا بينكم بالسوية فقبلوه أجزأه لأنه دفع إليهم حقهم فبرىء منه كالدين وقال ابن حامد يجزئه وإن لم يقل بالسوية لأن قوله عن كفارتي يقتضي التسوية وإن غداهم أو عشاهم ستين مدا ففيه روايتان إحداهما يجزىء لقوله تعالى ﴿ فإطعام ستين مسكينا ﴾ وهذا قد أطعمهم ولأن أنسا فعل ذلك وظاهر المذهب أنه لا يجزئه لأنه لم يعلم وصول حق كل فقير إليه ولانه حق وجب للفقراء شرعا فوجب تمليكهم إياه كالزكاة ولا يجب التتابع في الاطعام لان الأمر به مطلق لا تقييد فيه [ج ٣ - ص ٢٧٢]

فصل

ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة سواء كانت قوت بلده أو لم تكن وإن أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه ذكره أبو الخطاب لقوله تعالى ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ فإن أخرج غير قوت بلده خيرا منه جاز لأنه زاد على الواجب وإن كان انقص منه لم يجزىء وقال القاضي لا يجزىء إخراج غير ما يجزىء في الفطرة ولأنه إطعام للمساكين فأشبه الفطرة والأول أجود لموافقته ظاهر النص ويجوز إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من الحنطة وفي الخبز روايتان إحداهما قد يجزئه لقوله تعالى فإطعام ستين مسكينا المجادله 4 0 ومخرج الخبز قد أطعمهم والأخرى لا يجزئه لأنه قد خرج عن حال الكمال والادخار فأشبه الهريسة فإذا قلنا يجزئه اعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا فإن أخذ مد حنطة فطحنه وخبزه أجزأه وقال الخرقي لكل مسكين رطلا خبز لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا من مد فأكثر وفي السويق وجهان بناء على الروايتين في الخبز ولا تجزىء الهريسة والكبولا لأنه خرج عن الاقتيات المعتاد ولا القيمة لأنه أحد ما يكفر به فلم تجزىء القيمة فيه كالعتق [ج ٣ - ص ٢٧٣]

فصل

ولا يجوز صرفها إلا على الفقراء والمساكين لأنهما صنف واحد في غير الزكاة ولا يجوز دفعها إلى غنى وإن كان من أصناف الزكاة لأن الله تعالى خص بها المساكين ولا إلى مكاتب كذلك وقال الشريف أبو جعفر يجوز دفعها إليه لأنه يأخذ من الزكاة لحاجته فأشبه المسكين والأول أولى لأن الله تعالى خص بها المساكين والمكاتب صنف آخر فأشبه الؤلفة ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه كالعبد والكافر ومن تلزمه مؤنته لما ذكرنا في الزكاة وخرج أبو الخطاب وجها آخر في جواز الدفع إلى الكافر بناء على عتقه ولا يصح لأنه كافر فلم يجز الدفع إليه كالمستأمن

فصل

ولا تجزىء كفارة إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية كالزكاة فإن كانت عليه كفارات من جنس لم يلزمه تعيين سببها فإن كانت من أجناس فكذلك لأنها كفارات فلم يجب تعيين سببها كما لو كانت من جنس وقال القاضي يحتمل أن يلزمه تعيين سببها لأنها عبادات من أجناس فوجب تعيين النية لها كأنواع الصيام فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها فأعتق رقبة أجزأه على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني ينبغي أن تلزمه [ج ٣ - ص ٢٧٤]

كفارات بعدد الأسباب كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ولا يلزم نية التتابع في الصيام لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط فيه فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة

فصل

وإن كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والإطعام لأنه يصح منه في غير الكفارة فصح منه فيها ولا يكفر بالصوم لأنه لايصح منه في غيرها فكذلك فيها وإن أسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون

فصل

ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه كتقديم الزكاة قبل الملك ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة أو عن اليمين قبلها أو عن القتل قبل الجرح لم يجز كذلك وإن كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود وعن اليمين بعدها وقبل الحنث وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز لأن الله تعالى قال ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ولانها كفاره فجاز تقديمها على شرطها ككفارة الظهار ولانه حق مالي فجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاه [ج ٣ - ص ٢٧٥]

ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنى في قبل أو دبر فقال زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين لزمه الحد إلا أن يأتي بينة أو يلاعنها لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ﴾ دلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقطه بأربعة شهداء والثانية على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد وروى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ رواه البخاري ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد وتتعذر عليه البينة ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب الفاسد ولا ينتفي إلا باللعان لتعذر الشهادة على نفيه وله الملاعنة وإن قدر على البينة كذلك ولأنهما حجتان فملك إقامة أيهما شاء كالرجلين والرجل والمرأتين في المال [ج ٣ - ص ٢٧٦]

فصل

ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها كالدين فان عفت عن الحد أو لم تطالب لم تجز مطالبته بحد ولا بينة ولا لعان ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الأمة المطالبة بالتعزير من أجلهن لأنه حق ثبت للتشفي فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه كالقصاص فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها وليس بينهما ولد يريد نفيه لم يملك ذك لأنه لا حاجة إليه وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه فيشرع كما لو طالبته ولأن نفيه حق له فلا يسقط برضاها به ويحتمل إلا يشرع اللعان كما لو صدقته

فصل

ويصح اللعان بين كل زوجين مكلفين لعموم قوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ ولأن اللعان لدرء عقوبة القذف ونفي النسب الباطل والكافر والعبد كالمسلم الحر فيه وعنه لا يصح اللعان إلا بين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف لأن اللعان شهادة بدليل قوله تعالى ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ﴾ فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة وقال القاضي من لايحد بقذفها كالذمية والأمة والمحدودة في الزنى إن كان بينهما ولد يريد نفيه فله اللعان لنفيه لأنه محتاج إليه وإلا فلا لعان [ج ٣ - ص ٢٧٧]

بينهما لأن اللعان لإسقاط حد أو نفي نسب ولم يوجد واحد منهما وإن كان أحد الزوجين صبيا أو مجنونا فلا لعان بينهما لأن غير المكلف لا حكم لقوله ونفي حكم الولد إنما يحصل بتمام اللعان ولا يتم اللعان مع عدم القول منها وقال القاضي له لعان المجنونة إن كان ثم نسب يريد نفيه لأنه محتاج إليه فإن كان أحدهما أخرس وليست له إشارة مفهومة ولا كتابة فهو كالمجنون لأنه لا يعلم طلبها ولا يتصور لعانهما وإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة صح اللعان منهما لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه فكذلك في لعانه وعن أحمد إذا كانت المرأة خرساء فلا لعان بينهما لأنه لا يعلم طلبها فيحتمل أن يحمل على عمومه في كل خرساء لأن إشارتها لا تخلو من تردد واحتمال والحد يدرأ بالشبهة ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها لأنه علل بأنه لا تفهم مطالبتها وإن اعتقل لسان الناطق وأيس من نطقه فهو كالأخرس وإن رجى نطقه لم يصح لعانه لأنه غير مأيوس من نطقه فأشبه الساكت

فصل

ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول لعموم قوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴾ وبعد الطلاق الرجعي لأن الرجعية

زوجته فتدخل في العموم ولا يصح من غير الزوجين للآية فإن قذف من كانت زوجته فبانت منه بزنى لم يضفه إلى حال الزوجية فلا لعان بينهما لأنه قذف أجنبية وإن أضافه إلى حال الزوجية وبينهما ولد يريد نفيه لا عن لنفيه لأنه محتاج إليه فصح منه كحال الزوجية وإن لم يكن بينهما ولد حد ولم يلاعن لأنه لا حاجة به إليه فأشبه قذف الأجنبية ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية فنص أحمد على أنه يلاعن فنحمله على من بينهما ولد لأنه يتعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية ولو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها فالحكم فيها كالمطلقة إن كان بينهما ولد لاعن لنفيه وإلا فلا لأن النسب يلحق في النكاح الفاسد فيحتاج إلى اللعان لنفيه وإن قذف أجنبية ثم تزوجها حد ولم يلاعن لأنه قذف أجنبية قذفا لا حاجة به إليه وإن قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح فإن كان يتعلق به نفي نسب عنه فله اللعان وإلا فلا ونقل عن أحمد في هذا روايتان إحداهما لا يلاعن لأنه قذفها في حال كونها أجنبية أشبه ما لو قذفها قبل نكاحه لها الثانية يشرع اللعان لأنه قذف زوجته [ج ٣ - ص ٢٧٩]

2 باب صفة اللعان 2

وصفته أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبة أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي من الزنى ويشير إليها إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة سماها ونسبها حتى تنتفي المشاركة ثم يقول وان لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ثم تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى وتشير إليه فإن كان غائبا سمته ونسبته ثم تقول وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى لقوله تعالى ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فجاءت فتلا عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال والله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما فقيل لهلال [ج ٣ - ص ٢٨٠]

اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم قيل لها اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا بيت لها من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها

فصل

وشروط صحة اللعان ستة أحدها أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبة لأنه يمين في دعوى فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى وإن كانت المرأة برزة أرسل إليها فأحضرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة هلال وإن لم تكن برزة بعث من يلاعن بينهما كما يبعث من يستخلفها في سائر الدعاوى [ج ٣ - ص ٢٨١]

الثاني أن يأتي به بعد إلقائه عليه فإن بادر به قبل ذلك لم يعتد به كما لو حلف قبل أن يستحلفه الحاكم

الثالث كمال لفظاته الخمسة فإن نقص منها شيئا لم يعتد به لأن الله علق الحكم عليها فلا يثبت بدونها ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة

الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لأنه خلاف ما ورد به الشرع ولأن لعان الرجل بينة للإثبات ولعان المرأة بينة للإنكار فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات فإن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة أو المرأة الغضب على شيء منها لم يعتد بها لأن الله تعالى جعلها الخامسة فلا يجوز تغييره

الخامس الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع فإن أبدل الشهادة ببعض ألفاظ اليمين كقوله أقسم أو أحلف أو أولي أو بدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط أو غيره لم يعتد به لأنه ترك المنصوص ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة فلم يجز إبداله كالشهادة في الحقوق وفيه وجه آخر أنه يجزىء لأن معناهما واحد وقال الخرقي يقول الرجل أشهد بالله لقد زنت وليس هذا لفظ النص فيدل ذلك على أنه لم يشترط اللفظ وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز [ج ٣ - ص ٢٨٢]

لأن الغضب أغلظ ولذلك خصت به المرأة لأن المعرة والإثم بزناها أعظم من الحاصل بالقذف وإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لمخالفته المنصوص والثاني يجوز لأنه أبلغ في المعنى

السادس الإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسمية بما يتميز به إن كان غائبا ليحصل التميز عن غيره قال الوزير يحى بن محمد بن هبيرة رحمه الله الفقهاء يشترطون أن يزاد فيما رميتها به من الزنى وفي نفيها عن نفسه فيما رماني به من الزنى ولا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا ولم يأت في الخبر في صفة اللعان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراطه زيادة

فصل

ويشترط في اللعان العربية لمن يحسنها ولا يصح بغيرها لأن الشرع ورد به بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة وإن لم يحسن العربية جاز بلسانه لأنه يحتاج إليه فجاز بلسانه كالنكاح فإن عرف الحاكم لسانه أجزأ وإن لم يعرف لسانه أحضر عدلين يترجمان عنه ولا يقبل أقل منهما لأنه بمنزلة الشهادة عليه [ج ٣ - ص ٢٨٣]

فصل

فإن كان بينهما ولد يريد نفيه لم ينتف إلا بذكره في اللعان فإن لم يذكره أعاد اللعان هذا ظاهر قول الخرقي واختاره القاضي وقال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش لأن حديث سهل به سعد وصف فيه اللعان ولم يذكر فيه الولد وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن يدعى لأمه ولا يرمى ولدها رواه أبو داود والأول أصح لأن ابن عمر قال لاعن رجل امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة والزيادة من الثقة مقبولة ولأن من سقط حقه في اللعان اشترط ذكره فيه كالزوجة وتذكره المرأة في لعانها لأنهما يتحالفان عليه فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في الثمن ويحتمل أن لا يشترط ذكرها لأنه لا تنفيه والأول المذهب ولا بد من ذكره في كل لفظة فإذا قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي وهذا الولد ولده في كل لفظة وذكر القاضي أنه يشترط أن يقول هذا الولد من زنى وليس مني لئلا يعني بقوله ليس مني خلقا وخلقا ولا يكفيه قوله هو من زنى لأنه قد يعتقد الوطء في النكاح الفاسد زنى والصحيح الأول لأنه نفى الولد فينتفي عنه كما لو قال ذلك

فصل

ويسن في اللعان أربعة أمور أحدها أن يتلاعنا قياما لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت ولأن فعله في القيام أبلغ في الردع

الثاني أن يكون بمحضر من جماعة لأن ابن عباس وابن عمر وسهل ابن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يحضر الصبيان تبعا للرجال ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك

والثالث ان يعظهما الحاكم بعد الرابعة ويتخوفهما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

والرابع أن يضع رجل يده على في الملاعن بعد الرابعة يمنعه المبادرة إلى الخامسة إلى أن يعظه الحاكم ثم يرسلها وتفعل امرأة بالملاعنة بعد رابعتها كذلك لما روى ابن عباس في خبر المتلاعنين قال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسل فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعا بها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال ويلك كل شيء أهون عليك من غضب الله أخرجه الجوزجاني [ج ٣ - ص ٢٨٥]

فصل

ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان لأنه لم يرد به أثر ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار لقوله في الحديث فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث والغدو إنما يكون أول النهار وقال أبو الخطاب يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر لقوله تعالى ﴿ تحبسونهما من بعد الصلاة ﴾ يعني بعد العصر ويكون في الأماكن الشريفة عند المنابر في الجامع وفي مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الأقصى عند الصخرة لأنه أبلغ في الردع والزجر والله أعلم

2 باب ما يوجب اللعان من الأحكام 2

وهي أربعة أحكام أحدها سقوط الحد والتعزير الذي أوجبه القذف لأن هلال بن أمية قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها لأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة للحد كذلك لعانه ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك وإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه ثم قال أنا ألاعن سمع ذلك منه لأنه ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها [ج ٣ - ص ٢٨٦]

كالرجل وإن قذف امرأته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه وإن لم يذكره فيه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرره له ولأن اللعان بينة في احدى الطرفين فكان بينة في الأخرى كالشهادة وقال أبو الخطاب يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى

فصل

الحكم الثاني نفي الولد وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرنا من الحديث فيه ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد

فصل

فإن نفى الحمل في لعانه فقال الخرقي لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن لأن الحمل غير متيقن ويحتمل أن يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليقه على شرط وظاهر كلام أبي بكر صحة نفيه لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة والمسكن ونفي طلاق ا لبدعة ووجوب الاعتداد به وغير ذلك فكان كالمتيقن

فصل

فإن ولدت توأمين فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقا جميعا لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل والآخر من غيره والنسب يحتاط لإثباته لا لنفيه وإن نفى أحدهما وترك الآخر ألحقناهما به جميعا كذلك

فصل

وإن أقر بالولد أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو دعا لمن هنأه به لزمه نسبه ولم يملك نفيه لأن هذا جواب الراضي به وكذلك إن علم فسكت لحقه لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة وهل يتقدر بالمجلس أو يكون عقيب الإمكان على وجهين بناء على خيار الشفعة وإن أخره لعذر كأداء صلاة حضرت أو أكل لدفع الجوع وأشباه هذا من أشغاله أو للجهل بأن له نفيه أو بوجوب نفيه على الفور لم يبطل خياره لأن العادة جارية بتقديم هذه الأمور والجاهل معذور وإن ادعى الجهل بذلك قبل منه لأن هذا مما يخفى إلا أن يكون فقيها فلا يقبل منه لأنه في مظنة العلم وإذا أخره لعذر مدة يسيرة لم يحتج أن يشهد على نفسه وإن طالت أشهد على نفسه بنفيه كالطلب بالشفعة وإن قال لم اصدق المخبر وكان الخبر مستفيضا أو المخبر مشهور العدالة لم يقبل قوله وإن لم يكن كذلك قبل وإن أخر نفي الحمل لم يسقط نفيه [ج ٣ - ص ٢٨٨]

لأنه غير مستحق وإن استحقه لم يلحقه كذلك إلا على قول أبي بكر وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة وأمكن صدقه فالقول قوله وإلا فلا وإن أخر نفيه رجاء موته ليكفى أمر اللعان سقط حقه من النفي

فصل

الحكم الثالث الفرقة وفيها روايتان إحداهما لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عباس في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وفي حديث عويمر انه قذف زوجته فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عويمر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان فعلى هذا إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما من غير استئذانهما وعليه أن يفرق بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما والثانية تحصل الفرقة بمجرد لعانهما لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعيب والإعسار وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان وعلى كلتا الروايتين ففرقه اللعان فسخ لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع [ج ٣ - ص ٢٨٩]

فصل

الحكم الرابع التحريم المؤبد يثبت لما روى سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا رواه الجوزجاني ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع وقد روى عنه حنبل أنه إذ أكذب نفسه عاد فراشه وهذه الرواية شذ بها عن سائر أصحابه قال أبو بكر والعمل على الأول وإن لاعنها في نكاح فاسد أو بعد البينونة لنفي نسب ثبت التحريم المؤبد لأنه لعان صحيح فأثبت التحريم كاللعان في النكاح الصحيح ويحتمل أن لا يثبت التحريم لأنه لم يرفع فراشا فلم يثبت تحريما كغير اللعان ولو لاعنها في نكاح صحيح وهي أمة ثم اشتراها لم تحل له لأنه وجد ما يحرمها على التأبيد فلم يرتفع بالشراء كالرضاع

فصل

ولا تثبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان إلا سقوط الحد وما قام مقامه فإنه يسقط بمجرد لعانه فإن مات أحدهما قبل كماله منهما فقد مات على الزوجية لأن الفرقة لم تحصل بكمال اللعان ويرثه صاحبه كذلك ويثبت النسب لأنه لم يوجد ما يسقطه فإن كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحد فلا لعان لأن الحد

لا يورث وإن ماتت بعد طلبها قام وارثها مقامها في المطالبة وله اللعان لإسقاط الحد

فصل

وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان لزمه الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة ويلحقه النسب لأنهما حق عليه فيلزمانه بإقراره بهما ولا يعود الفراش ولا يرتفع التحريم المؤبد لأنهما حق له فلا يعودان بتكذيبه

فصل

فإن لاعن الزوج ونكلت المرأة عن اللعان فلا حد عليها لأن زناها لم يثبت فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج ولم يسمع لعانها كما لو قامت به البينة ولا يثبت بنكولها لأن الحد لا يقضى فيه بالنكول لأنه يدرأ بالشبهات والشبهة متمكنة منه ولكن تحبس حتى تلتعن أو تقر قال أحمد أجبرها على اللعان لقوله تعالى ﴿ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ﴾ فإذا لم تشهد لم يدرأ عنها وعنه يخلى سبيلها وهو اختيار أبي بكر لأنه لم يثبت عليها ما يوجب الحد فيخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة وإن صدقته فيما قذفها به لم يلزمها الحد حتى تقر أربع مرات لأن الحد لا يثبت بدون إقرار أربع على ما سنذكره [ج ٣ - ص ٢٩١]

وحكمها حكم ما لو نكلت ولا لعان بينهما لأن اللعان إنما يكون مع إنكارها ولا يستحلف إنسان على نفي ما يقربه

2 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 2

إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمكان اجتماعهما على الوطء لحقه نسبه في الظاهر من المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولأن مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب إلحاقه به وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به وانتفى من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه

فصل

وأقل سن يولد لمثله في حق الرجل عشر سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وقال القاضي تسع سنين واقل مدة الحمل لأن الجارية يولدها كذلك فكذلك الغلام وقال أبو بكر لا يلحق به الولد حتى يبلغ قال ابن عقيل هو أصح لأن من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد وهذا ليس بسديد لأنهم إن أرادوا بالبلوغ بلوغ خمس عشرة فهو باطل لأنه يولد له بغير ذلك [ج ٣ - ص ٢٩٢]

وقد روي أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله إلا اثنتا عشرة سنة وإن أرادوا الإنزال فيما يعلم فلا بد من ضبطها بأمر ظاهر وإذا ولدت امرأة غلام سنه دون ذلك لم يلحق به ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق به نسب لأنه لا ينزل مع قطعهما وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحق به النسب لأنه إذا بقي الذكر أولج فأنزل وإن بقيت الأنثيان ساحق فأنزل والصحيح أن مقطوع الأنثيين لا يلحق به نسب لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه ولد ولا تنقضي به شهوة فأشبه مقطوع الذكر والأنثيين وإن لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطء بأن يطلقها عقيب تزويجه بها أو كان بينهما مسافة لا يمكن اجتماعها على الوطء معها لم يلحق به الولد وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح

فصل

وأقل مدة الحمل ستة أشهر لما روي أن عثمان أتى بامرأة ولدت لدون ستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس أنزل الله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ وأنزل ﴿ وفصاله في عامين ﴾ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر وذكر ابن القتبي أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان لما روي عن [ج ٣ - ص ٢٩٣]

عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة على سنتين في الحمل والأول المذهب لما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعة أربع سنين وغالب الحمل تسعة أشهر لأنه كذلك يقع غالبا وإذا أتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها بموت أو طلاق بائن بأربع سنين لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان لأنها علقت به بعد زوال الفراش وإن كان الطلاق رجعيا فوضعته لأبع سنين منذ انقضت عدتها فكذلك لذلك وإن كان لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق ففيه روايتان إحداهما لا يلحق به لأنها علقت به بعد طلاقه أشبهت البائن والثانية يلحقه لأنها في حكم الزوجات فأشبهت ما قبل الطلاق وإن وضعته لأقل من أربع سنين قبل الحكم بانقضاء عدتها لحق به لأنه أمكن إلحاقه به والنسب مما يحتاط لإثباته وإن بانت زوجته منه فوضعت ولدا ثم وضعت آخر بينهما اقل من ستة أشهر لحق به لأنهما حمل واحد وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا لم يلحق به لأنه حمل ثان إذ لا يمكن أن يكونا حملا واحدا بينهما مدة الحمل فيعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وإن اعتدت بالأقراء ثم أتت بولد لدون ستة أشهر لحق

به لعلمنا أنها حملته الزوجية في والدم دم فساد رأته في حملها وإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لم يلحق به لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول أصحابنا

فصل

وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالأول وانتفى عنهما بغير لعان وإن تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني فهو ولد الأول لأنه أمكن أن يكون منه ولم يمكن إلحاقه بالثاني وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا فهذا يحتمل أن يكون منهما فيرى القافه معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما فإن ألحقته بالأول انتفى عن الثاني بغير لعان لأن ناكحه فاسد وإن ألحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللعان على روايتين إحداهما له ذلك والأخرى لا ينتفى عنه بحال وإن لم توجد قافه أو أشكل أمره ففيه روايتان إحداهما يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما والأخرى يضيع نسبه

فصل

إذا أتت زوجته بولد يمكن أن يكون منه فقالت هذا ولدي منك

فقال ليس هذا ولدي منك بل استعرتيه أو التقطتيه ففيه وجهان أحدهما القول قولها لأنه خارج تنقضي به العدة فالقول قولها فيه كالحيض والثاني القول قوله ولا يقبل قولها إلا ببينة لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل عدمها فكانت البينة على مدعيها ويكفي في ذلك امرأة عدلة وإذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به لأنه ولد على فراشه وإن كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة لأن المرجع إليها فيها وإن قال هو من زوج قبلي ولم يكن لها قبله زوج أو كان ولم يمكن إلحاقه به لحقه ولم يلتفت إلى قوله وإن قال هو من وطء شبهة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فقال الخرقي هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لأنه لم يقذفها ولا لعان بينهما لأن من شرطه القذف ولم يقذفها وقال أبو الخطاب هل له أن يلاعن بنفي الولد على روايتين إحداهما لا يلاعن كذلك والثانية له أن يلاعن لأنه يحتاج إلى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها

فصل

ومن ولدت زوجته بعد وطئه لها بستة أشهر من غير مشاركة غيره له في وطئها لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة إيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه [ج ٣ - ص ٢٩٦]

احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود وإن علم أنه من غيره مثل أن يراها تزني ف يطهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت لزمه قذفها أو نفي ولدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته فلما حرم عليها أن تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل عل أن الرجل مثله ولأنه إذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقهم ونظر إلى حرمه بحكم أنه محرم لهن وإن لم يرها تزني لكن علم أن الولد من غيره لكونه لم يصبها لزمه نفي ولدها كذلك وليس له قذفها لاحتمال أن تكون مكرهة أو موطوءة بشبهة وإن كان يطؤها ويعزل لم يكن له نفي ولدها لما روى أبو سعيد الخدري قال قالوا لرسول الله إنا نصيب الإماء فنعزل عنهن فقال إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق منه وإن كان يجامعها دون الفرج أو في الدبر فقال أصحابنا ليس له نفيه لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما لا تحس به

فصل

وإن ولدت امرأته غلاما أسود وهما أبيضان أو أبيض وهما أسودان لم يجز له نفيه ذكره ابن حامد لما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم [ج ٣ - ص ٢٩٧]

هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قا هل فيها من أورق قال إن فيها أورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق قال ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه ولأن دلالة ولادته على فراشه قوية ودلالة الشبهة ضعيفة فلا يجوز معارضة القوي بالضعيف ولذلك لما اختلف عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بينا لعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه فاعتبر الفراش دونا الشبه وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن له نفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إمرأة هلال ابصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك رواه أحمد ومسلم فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان لي ولها شأن أخرجه أبو داود فجعل الشبهة دليلا على نفيه عن الزوج

فصل

وإن رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقه فله قذفها لأن هلالا وعويمرا قذفا زوجتيهما قبل أن يكون ثم نسب ينفى وله أن يسكت [ج ٣ - ص ٢٩٨]

لأنه لا نسب فيه ينفيه وفراقها ممكن بالطلاق فيستغني عن اللعان وإن أقرت عنده بالزنى فوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض في الناس أن رجلا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله قذفها لأن الظاهر زناها وإن لم ير شيئا ولا استفاض سوى أنه رأى رجلا يخرج من عندها من غير استفاضة لم يكن له قذفها لأنه يجوز أن يكون دخل هاربا أو سارقا أو ليراودها عن نفسها فمنعته فلم يجز قذفها بالشك وإن استفاض ذلك ولم يره يدخل إليها ففيه وجهان احدهما يجوز قذفها لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة والثاني لا يجوز لأنه يحتمل أن عدوا أشاع ذلك عنها

فصل

ومن ملك أمة لم تصر فراشا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها التمول أو التجمل أو التجارة أو الخدمة فلم يتعين لإرادة الوطء فإن أتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه لأنه لم يولد على فراشه فإذا وطئها صارت فراشا له فإذا أتت بولد لمدة الحمل من حين يوم الوطء لحقه لأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه فإن [ج ٣ - ص ٢٩٩]

ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف عنه بذلك لما ذكرنا في الزوجة وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بال قوم يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا وإن اعترف بوطئها دون الفرج فقال أصحابنا يلحقه نسب ولدها لأن الماء قد يسبق إلى الفرج من حيث لا يعلم وإن انتفى من ولدها بعد اعترافه بوطئها لم يلاعن لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها فإن ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه ويقوم ذلك مقام اللعان في نقي الولد

إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بالاجماع لقوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ ولأن العدة تجب لاستبراء الرحم وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل فإن فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالإجماع لقوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه وإن طلقها بعد الخلوة وجبت العدة لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زرارة ابن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو من أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها ولهذا استقرت به الأجرة في الإجارة فجعل كالاستيفاء في العدة

فصل

والمعتدات ثلاثة أقسام معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه سواء

كانت حرة أو أمة مفارقة في حياة أو بوفاة لقوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ وروت سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها فلما انقلبت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لعلك ترجين النكاح إنك والله لست بناكح حتى يمر عليك أربعة اشهر وعشر قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي فأمرني بالتزوج إن بدا لي متفق عليه ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضعه فكانت عدتها به ولا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله فإن كان حملها أكثر من واحد فحتى تضع آخر حملها ويفصل لأن الشغل لا يزول إلا بذلك وإن وضعت ما يتبين فيه خلق الانسان انقضت به عدتها لأنه ولد وإن لم يتبين وشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية فكذلك لأنه تبين لهن وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي فالمنصوص أن العدة لا تنقضي به لأنه لم يصر ولدا فأشبه العلقة وعنه أن الأمة تصير به أم ولد فيجب أن تنقضي به العدة لأنه حمل فيدخل في عموم الآية وأقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل أن تضعه بعد ثمانين يوما من حين إمكان الوطء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما [ج ٣ - ص ٣٠٢]

ثم يكون مضغة أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ولا تنقضي العدة بما دون المضغة ولا يكون مضغة في أقل من ثمانين

فصل

القسم الثاني معتدة بالقروء وهي كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تحيض وهي نوعان حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ وأمة فعدتها قرآن لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان رواه أبو داود وعن عمر وعلي وابن عمر أنهم قالوا عدة الأمة حيضتان وفي القروء روايتان إحداهما الحيض لهذا الخبر وقول الصحابة ولقوله عليه السلام تدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود وقال لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة ولأن الله جعل العدة ثلاثة قروء فالظاهر أنها تكون كاملة ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت الحيض ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة كاملة لأنه يعد الطهر الذي طلقها فيه قرءا والثانية القروء الأطهار لقوله تعالى ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في عدتهن وإنما يطلق في الطهر فإذا قلنا هي الحيض لم [ج ٣ - ص ٣٠٣]

يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لقوله تعالى ﴿ ثلاثة قروء ﴾ فيتناول الكاملة وإن قلنا هي الأطهار احتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة لقوله تعالى ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ أي في عدتهن وإنما يكون من عدتهن إذا احتسب به ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض كيلا يضر بها فتطول عدتها ولو لم يحتسب بقية الطهر قرءا لم تقتصر عدتها بالطلاق فيه فإن لم يبق من الطهر بعد الطلاق جزء بأن وافق آخر لفظه آخر الطهر أو قال أنت طالق في آخر طهرك كان أول قرئها الطهر الذي بعد الحيض لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ومتى قلنا القرء الحيض فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة لأن ذلك آخر القروء وعنه لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة اختاره الخرقي لأنه يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق وعثمان وعبادة وأبو موسى وأبو الدرداء وإن قلنا القرء الطهر فآخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت عدتها ويحتمل أن لا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة لأن ما دونه لا يحتمل تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة لأن ما دونه لا يحتمل أن يكون حيضا وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها ولا يصح ارتجاعها فيها لأن حسبانها من عدتها يفضي إلى زيادتها على ثلاثة قروء وإنما اعتبرت ليتحقق انتفاء الطهر

فصل

وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما إن قلنا القرء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما لأن ثلاثة حيضات ثلاثة أيام وبينها طهران ستة وعشرون يوما وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر يوما فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوما وإن قلنا الأقراء الأطهار والطهر ثلاثة عشر يوما فأقلها ثمانية وعشرون يوما ولحظة وإن قلنا أقله خمسة عشر يوما فأقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة فأما الأمة فعلى الأول أقل عدتها خمسة عشر يوما وعلى الثاني سبعة عشر وعلى الثالث أربعة عشر يوما ولحظة وعلى الرابع ستة عشر يوما ولحظة

فصل

القسم الثالث المعتده بالشهور وهي ثلاثة أنواع إحداهن الآيسة من المحيض والصغيرة التي لم تحض إذا بانت في حاية زوجها بعد دخوله بها فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾

فإن طلقها في أول الهلال فعدتها ثلاثة أشهر بالأهلة وإن طلقها في أثناء الشهر اعتدت شهرين بالهلال وشهرا بالعدد لما ذكرنا فيما مضى وإن

كانت أمة ففيها ثلاث روايات إحداهن عدتها شهران لأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرآن فتكون عدتها بالشهور شهرين والثانية عدتها شهر ونصف لأن عدتها نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف وإنما كملنا الأقراء لتعذر تنصيفها وتنصيف الأشهر ممكن والثالثة أن عدتها ثلاثة أشهر لعموم الآية ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل بأقل من ثلاثة

فصل

واختلف عن أحمد في حد الإياس فعنه أقله خمسون سنة لأن عائشة رضي الله عنها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة وعنه إن كانت من نساء العجم فخمسون وإن كانت من نساء العرب فستون لأنهن أقوى طبيعة وذكر الزبير في كتاب النسب أن هند بنت أبي عبيد بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة قال ويقال لن تلد بعد الخمسين إلا عربية ولا بعد الستين إلا قرشية ويحتمل كلام الخرقي أن يكون حده ستون سنة في حق الكل لقوله وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض [ج ٣ - ص ٣٠٦]

فصل

وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى حاضت بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالقروء لأنها قدرت على الأصل فيه فبطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإن قلنا القروء الحيض استأنفت ثلاث حيض وإن قلنا الأطهار فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرءا فيه وجهان أحدهما تعتد به لأنه طهر قبل حيض فاعتدت به كالذي بين الحيضتين والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرءين ثم يئست لم تعتد بالطهر قبل الإياس قرءا ثالثا وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهور لم يلتفت إليه لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة فلم يلتفت إليه

فصل

النوع الثاني المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حرة مدخولا بها أو غير مدخول بها لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال لأن الصحابة رضي الله عنهم

اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة فيجب أن تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة وهو ما ذكرنا ومن نصفها حرة فعدتها بالحساب من عدة حرة وعدة أمة وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليال لأن نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال ونصف عدة الأمة شهر وثلاث ليال

فصل

النوع الثالث ذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فعدتها سنة تسعة أشهر تتربص فيها ليعلم براءتها من الحمل لأنها غالب مدته ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر وقال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه فصار إجماعا فإن حاضت قبل انقضاء السنة ولو بلحظة لزمها الانتقال إلى القروء لأنها الأصل فبطل حكم البدل كالمتيمم إذا رأى الماء وإن عاد الحيض بعد انقضاء السنة وتزوجها لم تعد إلى الأقراء لأننا حكمنا بانقضاء عدتها وصحة نكاحها فلم تبطل كما لو حاضت الصغيرة بعد اعتدادها وتزوجها وإن حاضت بعد السنة وقبل تزوجها ففيه وجهان أحدهما لا عدة عليها كذلك والثاني عليها العدة لأنها من ذوات القروء وقد قدرت على المبدل قبل تعلق حق الزوج بها فلزمها العود كما لو حاضت في السنة وإن كانت أمة تربصت تسعة أشهر للحمل لأن مدته للحرة والأمة سواء وتضم إلى ذلك عدة الأمة على ما ذكرنا من

الخلاف فيها وإن شرعت في الحيض ثم ارتفع حيضها قبل قضاء عدتها لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض لأنها لا تنبني إحدى العدتين على الأخرى ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض أو الرضاع ونحوه لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به لأنها من ذوات القروء والعارض الذي منع الدم يزول فانتظر زواله إلا أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهر من وقت أن تصير في عداد الآيسات

فصل

إذا أتى على الجارية سن تحيض فيه السناء غالبا كخمسة عشر فلم تحض فعدتها ثلاثة أشهر في إحدى الروايتين لظاهر قوله تعالى ﴿ واللائي لم يحضن ﴾ والأخرى عدتها سنة لأنه أتى عليها زمن الحيض فلم تحض فأشبهت من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه ولو ولدت ولم تر دما قبل الولادة ولا بعدها ففيه والوجهان بناء على ما تقدم فأما المستحاضة فإن كان لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز فمتى مرت لها ثلاثة قروء انقضت عدتها لأنه حيض محكوم به أشبه غير المستحاضة وإن كانت مما لا عادة لها ولا تمييز إما مبتدأة وإما آيسة متحيرة ففيها روايتان إحداهما عدتها ثلاثة أشهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس من كل شهر ستة أيام أو سبعة فجعل لها حيضة في كل شهر لأننا نحكم لها بحيضة في [ج ٣ - ص ٣٠٩]

كل شهر تترك فيها الصلاة والصوم فيجب أن تنقضي العدة به والثانية تعتد سنة لأنها لم تتيقن بها حيضا مع أنها من ذوات الأقراء فأشبهت التي ارتفع حيضها والأول أولى

فصل

فإذا عتقت الأمة بعد قضاء عدتها لم يلزمها زيادة عليها لأن عدتها انقضت فأشبهت الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهر وإن عتقت في عدتها وكانت رجعية أتمت عدتها عدة حرة لأن الرجعية زوجة وقد عتقت في الزوجية فلزمتها عدة حرة كما لو عتقت قبل الشروع فيها وإن كانت بائنا أتمت عدة الأمة لأنها عتقت بعد البينونة أشبهت المعتقة بعد عدتها

فصل

وإن مات زوج المعتدة الرجعية فعليها عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت وتنقطع عدة الطلاق لأنها زوجة متوفى عنها فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق ولأنها أجنبية من نكاحه وميراثه فلم يلزمها الاعتداد من وفاته كما لو انقضت عدتها قبل موته وعلى قياس هذا [ج ٣ - ص ٣١٠]

المطلقة في المرض التي لا ترث كالذمية والأمة والمختلعة وزوجة العبد لأنها غير وارثة وإن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر لأنها مطلقة بائن فتدخل في الآية ومعتدة ترث بالزوجية فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية فإن كان طلاقه قبل الدخول أو موته بعد قضاء عدتها فلا عدة عليها وعنه عليها العدة من الوفاة لأنهما يرثانه بالزوجية والأول أصح لقوله تعالى ﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ ولأنها أجنبية تحل للأزواج فلم تلزمها العدة منه كما لو تزوجت غيره

فصل

وإذا وطئت المرأة بشبهة أو زنى لزمتها العدة لأن العدة تجب لاستبراء الرحم وحفظا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطىء بماء الزوج ولم يعلم لمن الولد منهما فيحصل الاشتباه وعدتها كعدة المطلقة لأنه استبراء لحرة أشبه عدة المطلقة وعنه أن الزانية تستبرأ بحيضة لأن النسب لا يلحق الزاني وإنما المقصود معرفة براءة رحمها فكان بحيضة كاستبراء أم الولد إذا مات سيدها [ج ٣ - ص ٣١١]

فصل

وإذا طلق أحد نسائه ثلاثا وأنسيها ثم مات قبل أن يبين المطلقة فعلى الجميع الاعتداد بأطول الأجلين من عدة الطلاق والوفاة ليسقط الفرض بيقين كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة فيلزمها ثلاثة قروء ويحتمل أن تكون غيرها فتلزمها عدة الوفاة فلا يحصل حلها يقينا إلا بهما والمنصوص أنه يقرع بينهن فتعتد واحدة منهن عدة الطلاق وسائرهن عدة الوفاة فأما إن طلق واحدة لا بعينها فإنه يقرع بينهن فتخرج بالقرعة المطلقة منهن فتعتد عدة الطلاق ويعتد سائرهن عدة الوفاة لأن الطلاق لم يقع في واحدة بعينها وإنما عينته القرعة بخلاف التي قبلها

فصل

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها أمارات الحمل من حركة ونحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة فإن تزوجت قبل زوالها لم يصح نكاحها لأنها تزوجت قبل العلم بقضاء عدتها وإن حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحها فالنكاح صحيح لأننا حكمنا بصحة ذلك بدليله فلا يزول عنه بالشك لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة لأننا شككنا في حل الوطء وإن حدثت بعد العدة وقبل النكاح ففيه وجهان أحدهما لا يحل لها أن تنكح لأنها

شاكة في انقضاء عدتها والثاني يحل لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك [ج ٣ - ص ٣١٢]

فصل

إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره عنها لم يخل من حالين أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته لأنها كانت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله وإذا أباح قسمة ماله أباح لزوجته أن تتزوج قال أصحابنا يعني تسعين سنة من حين ولد لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك فإذا اقترن به انقطاع خبره حكم بموته والأول أصح لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير توقيف

الثاني أن يكون ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة هلك فيها بعض رفقته أو بين الصفين أو ينكسر مركبا فيهلك بعض رفقته وأشباه ذلك فمذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج قال بعض أصحابنا لا يختلف قول أحمد في هذا فقال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القاضي عندي أن فيها رواية أخرى أن حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة والمذهب الأول قال أحمد يروى عن عمر من ثمانية وجوه ومن أحسنها ما روى عبيد بن عمير قال فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي اربع سنين [ج ٣ - ص ٣١٣]

ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال له طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا وهل يعتبر ابتداء المدة من حين يضربها الحاكم أو من حين ينقطع خبره على وجهين أحدهما من حين يضربها الحاكم لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة العنة والثاني من حين انقطع خبره لأن ذلك ظاهر في موته فأشبه ما لو قامت به بينة وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى ان يطلقها وليه فيه وجهان أحدهما يعتبر لأن ذلك يروى عن عمر وعلي والثاني لا يفتقر لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر

فصل

فإن قدم المفقود قبل تزوجها فهي زوجته لأننا تبينا حياته فأشبه ما لو شهد بموته شاهدان وتبين أنه حي وإن قدم بعد تزوجها وقبل دخوله بها فكذلك لما ذكرنا وقيل عنه إن حكمها حكم المدخول بها والصحيح

الأول وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير بينها وبين صداقها لإجماع الصحابة عليه فإن اختارها فهي زوجته بالعقد الأول ولم يحتج الثاني إلى طلاق لأننا تبينا بطلان عقده وإن اختار صداقها فله ذلك ويأخذ من الثاني صداقها الذي ساق إليها الأول اختاره أبو بكر لأن عليا وعثمان رضي الله عنهما قالا يخير بينها وبين صداقها الذي ساق ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا عنه وعنه يرجع بالصداق الآخر لأنه بذله عوضا عما هو مستحق للأول فكان أولى به وهل يرجع الثاني على المرأة بما غرمه للأول على روايتين وتكون زوجة الثاني من غير تجديد عقد لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أمر بتجديد عقد والقياس أن يلزمه تجديد العقد لأننا تبينا بطلان ما مضى من عقده بحياة صاحبه ولذلك ملك أخذها منه فعلى هذا الوجه الأول يؤمر بطلاقها ثم يعقد عليها الثاني عقدا وإن رجع الأول بعد موت الثاني ورثت واعتدت ورجعت إلى الأول قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهما رواه الجوزجاني في المترجم وقال أبو الخطاب قياس المذهب أنا إن حكمنا بوقوع الفرقة ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثاني ولا خيار للأول ولا ينفذ طلاقه لها ولا يتوارثان إذا مات أحدهما فإن لم يحكم بوقوعهما باطنا فهي زوجة الأول بكل حال ووطء الثاني لها وطء بشبهة [ج ٣ - ص ٣١٥]

فصل

فإن اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة والمسكن أبدا سواء ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيها أو لم يضربها لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب المدة فهي باقية على حكم الزوجية وإن حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لمفارقتها إياه حكما

فصل

وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين والأخرى إن ثبت ذلك البينة فكذلك وإن بلغها خبره فعدتها من حين بلغها الخبر

2 باب اجتماع العدتين 2

إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلا آخر لم تنقطع عدتها بالعقد لأنه عقد فاسد لا يصير به فراشا فإن وطئها انقطعت عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني فلا تبقى في عدة غيره فإذا فرق بينهما لزمها إتمام عدة الأول وعدة الثاني وتقدم عدة الأول لسبقها ولما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي

تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق الحاكم بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم يجز للثاني أن ينكحها أبدا رواه الشافعي في مسنده فإن كانت حاملا من الأول انقضت عدته بوضع الحمل ثم اعتدت للثاني ثلاثة قروء وإن حملت من وطء الثاني انقضت عدتها منه بوضع الحمل ثم أتمت عدة الأول بالقروء وتتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول لأنه لا يجوز أن تضع حملها منه ولا تنقضي عدتها منه وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه به واعتدت للآخر وإن ألحقوه بهما انقضت به عدتها منهما وإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروء لأنه يحتمل أن يكون من الأول فيلزمها ثلاثة قروء لعدة الثاني فلزمها ذلك لتقضي العدة بيقين

فصل

وروي عن أحمد أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر ثم لا ينكحها أبدا والصحيح في المذهب أنها تحل له لأنه وطء بشبهة فلم يحرمها على التأبيد كالنكاح بلا ولي وقد روي أن عليا قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني فقال عمر ردوا [ج ٣ - ص ٣١٧]

الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي قال الخرقي وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين فعلى هذا كل معتدة من وطء في نكاح فاسد أو وطء شبهة لا يجوز للواطئ ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدتها لأنها معتدة من وطء في غير ملك فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية ويحتمل أن يباح للواطئ نكاحها في كل موضع يلحقه النسب لأن العدة إنما وضعت لصيانة الماء وحفظا للنسب عن الاشتباه والنسب هو الأحق فلم يمنع الواطئ نكاحها كالمعتدة من نكاحه الصحيح

فصل

وإن وطئت المعتدة بشبهة أو زنى فلم تحمل أتمت عدة الأول ثم اعتدت للثاني لأنها لم تصر فراشا وإن حملت من الثاني أو أشكل الأمر فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان

فصل

وكل حمل لا يلحق بالزوج كحمل زوجة الطفل أو الخصي والمجبوب وأشباههم لا تنقضي عدتها من الزوج به لأننا تبينا أنه ولد لغيره فلم تنقض به عدة الزوج كما لو علمنا الواطئ وعنه أن عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل وذكر أصحابنا في التي ولدت بعد أربع سنين منذ فارقها زوجها أن عدتها تنقضي به في وجه والصحيح الأول لما ذكرنا

ولأننا إن لم نعلم الواطئ فالمرأة تعلمه فلم يسقط عنها الاعتداد لجهلنا بعينه كما لو أقرت فعلى هذا تنقطع عدة الأول بوطء الثاني وتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل فإذا وضعته بنت على عدة الأول على ما ذكرنا وإن كانت حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوضعه من الواطئ ثم تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشرا

فصل

إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانيا بنت على ما مضى من العدة لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فأشبها الطلقتين في وقت واحد وإن طلق العبد زوجته الأمة طلقة ثم أعتقت وفسخت النكاح بنت على العدة كذلك وإن طلق الرجل زوجته ثم طلقها ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان أ حدهما تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء فأشبه ما لو لم يرتجعها والثاني تستأنف عدة كاملة لأنه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق وإن طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة وسقطت بقية الأولى لأن حكم الطلقة انقطع بالزوجية والدخول وإن وطئ المطلق زوجته الرجعية في عدتها وقلنا ذلك رجعة فقد عادت الزوجية فإن طلقها بعد ذلك استأنفت عدة وسقط حكم العدة الأولى

كما ذكرنا فيما تقدم وإن قلنا ليس هو برجعة فعليها أن تعتد للوطء لأنه وطء بشبهة وتدخل فيها بقية العدة الأولى لأنهما من رجل واحد وإن كانت حاملا فهل تتداخل العدتان فيه وجهان أحدهما يتداخلان لأنهما من رجل واحد فتنقضي عدتها من الطلاق والوطء بوضع الحمل والثاني لا يتداخلان لأنهما من جنسين بل تعتد للطلاق بوضع الحمل ثم تستأنف عدة الوطء بثلاثة قروء كما لو كانا من رجلين وإن كانت حائلا فحملت من الوطء وقلنا يتداخلان انقضت العدتان بوضع الحمل وإن قلنا لايتداخلان يتداخلان انقضت عدة الوطء بالوضع ثم أتمت بقية عدة الطلاق بالقروء

فصل

وإذا خلع الرجل زوجته فله نكاحها في عدتها لأنها لحفظ مائه ونسبه ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيح فإن طلقها بعد أن وطئها فعليها استئناف العدة لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس ويسقط حكم بقية العدة الأولى وإن طلقها قبل أن يمسها ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية والأولى هاهنا أنها تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها لأن الطلاق الثاني طلاق من نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة كما لو لم يتقدمه نكاح ويلزمها بقية عدة الأول لأنها تنقطع بعقد [ج ٣ - ص ٣٢٠]

التزويج لكونها تصير به فراشا فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له وإذا طلقها لزمها إتمامها لأنه لو لم يجب ذلك أفضى إلى اختلاط المياه بأن يطأ زوجته ثم يخلعها ثم يتزوجها ويطلقها من يومه فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحد فإن كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل أن يمسها لم يكن عليها عدة لأنه لم يبق من العدة الأولى شيء لأنها كانت حاملا فلا تنقضي عدتها بغير الوضع

2 باب مكان المعتدات 2

وهن ثلاثة إحداهن الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها لأنها تجب لحق الزوجية الثانية البائن بفسخ أو طلاق تعتد حيث شاءت لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم رواه الامام أحمد ومسلم الثالثة المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به [ج ٣ - ص ٣٢١]

حين توفي زوجها لما روت فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف القدوم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن أملكه ولا نفقة فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو حولها صاحب المنزل أو لم تتمكن من سكناه إلا بأجرة فلها الانتقال حيث شاءت لأن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلم يجب وليس عليها بدل الأجرة وإن قدرت عليها لأنه إنما يلزمها فعل السكنى لا تحصيل المسكن

فصل

ولا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا رواية واحدة وإن كانت حاملا فعلى روايتين إحداهما لا سكنى لها لأن المال انتقل إلى الورثة فلم تستحق عليهم السكنى كما لو كانت حائلا والثانية لها السكنى لقوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ﴾ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة بنت مالك بالاعتداد في

المنزل الذي أسكنها فيه زوجها فإذا قلنا لا سكنى لها فتبرع

[ج ٣ - ص ٣٢٢]

الوارث بإسكانها أو تبرع غيره بتمكينها من السكنى في منزلها إما بأداء أجرتها أو غير ذلك لزمها السكنى به وإن لم يوجد ذلك سكنت حيث شاءت وإن قلنا لها السكنى فهي أحق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها لأن حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء كالمرتهن وإن تعذر ذلك المسكن أو كان المسكن لغير الميت استؤجر لها من مال الميت ويضرب بقدر أجرته مع الغرماء إن لم يف ماله بدينه فإن كانت عدتها بالحمل ضربت بأقل مدته لأنه اليقين فإن وضعت لأقل من ذلك ردت الفضل على الغرماء وإن وضعت لأكثر منه رجعت عليهم بالنقص كما ترد عليهم الفضل ويحتمل أن لا ترجع عليهم بشيء لأننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم ترد عليه

فصل

ولهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب لقوله تعالى ﴿ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ فسره ابن عباس بما ذكرنا وإن بذئ عليها أهل زوجها نقلوا عنها لأن الضرر منهم

فصل

وليس لها الخروج من منزلها ليلا ولها الخروج نهارا لحوائجها لما روى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن [ج ٣ - ص ٣٢٣]

يا رسول الله إنا نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عن إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج لغير ضرورة

فصل

وليس لها الخروج للحج لأنه لا يفوت والعدة تفوت فإن خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة رجعت لأنها في حكم الاقامة وإن تباعدت مضت في سفرها لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها كما لو كان أكثر من ثلاثة أيام قال القاضي حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة لأن ما دونه في حكم الحضر وإن خافت في الرجوع مضت في سفرها ولو كانت قريبة لأن عليها ضررا في الرجوع وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق فإذا استويا في خوف الفوت كان أحق بالتقديم وإن لم تخف فوته مضت في العدة في منزلها لأنه أمكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة لأن العدة أسبق [ج ٣ - ص ٣٢٤]

فصل

إذا أذن لها في السفر لغير نقله فخرجت ثم مات فحكمه حكم الخروج للحج سواء وإن كان لنقله فمات بعد مفارقة البنيان فهي مخيرة بين البلدين لأنه ليس واحد منهما مسكنا لها لخروجها منتقلة عن الأول وعدم وصولها إلى الثاني ويحتمل أن يلزمها المضي إلى الثاني لأنها مأمورة بالإقامة والسكنى والأول بخلافه وهذا ضعيف جدا لأن فيه إلزامها السفر مع مشقته ومؤنته وإبعادها عن أهلها ووطنها وربما لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات وسفرها بغير محرم حرام ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة لأن حكمة الاعتداد في منزلها سترها وصيانتها لزوم منزلها وسفرها تبذيل لها وإبراز لها فهو محصل لضد المقصود سيما إذا لم يكن معها من يحفظها ومقامها في البلد الذي يسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير مسكنه أشد لهلكتها ثم تحتاج إلى الرجوع وكلفته وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع منه والله أعلم وإن وجبت العدة بعد وصولها إلى مقصدها وسفرها لنقله لزمها الإقامة به وتعتد لأنه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه وإن كان لقضاء حاجة فلها الإقامة إلى أن تقضي حاجتها وإن كان لزيارة أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة أقامت ما قدر لها لأنه مأذون فيه وإن لم يقدر لها مدة فلها إقامة ثلاثة أيام لأنه لم يأذن لها في المقام على الدوام ثم إن علمت [ج ٣ - ص ٣٢٥]

أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها وإن أمكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن خافت في الرجوع سقط للعذر والحكم فيما إذا أذن لها في النقلة من دار إلى دار ومات وهي بينهما كذلك

2 باب الإحداد 2

وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة وهو واجب في عدة الوفاة لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار متفق عليه ويجب هذا على الحرة والأمة والكبيرة والصغيرة والمسلمة والذمية لعموم الحديث فيهن ولا يجب على الرجعية لأنها باقية على الزوجية فلها أن تتزين لزوجها وترغبه في نفسها ولا على أم ولد لوفاة سيدها ولا موطوءة بشبهة ولا زنى لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها وفي المطلقة المبتوتة

والمختلعة روايتان إحداهما لا إحداد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وهذه عدة الوفاة ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية والثانية يجب عليها لأنها معتدة بائن أشبهت المتوفى عنها زوجها

فصل

ويحرم على الحادة الكحل بالإثمد للخبر ولأنه يحسن الوجه ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتياء ونحوه لأنه لا يحسن العين بل يزيدها مرها وإن دعت الحاجة إلى الاكتحال بالصبر والاثمد اكتحلت ليلا وغسلته نهارا لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه لا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار رواه النسائي وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي إلا لما لا بد منه فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار رواه أبو داود والنسائي [ج ٣ - ص ٣٢٧]

فصل

ويحرم على الحادة الخضاب لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أبو داود والنسائي ويحرم عليها أن تمتشط بالحناء ولا يحرم عليها غسل رأسها بالسدر ولا المشط به لما روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر تغلفين به رأسك رواه أبو داود ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب ويجوز تقليم الأظافر والاستحداد لأنه يراد للتنظيف لا للتزيين ويحرم عليها تحمير وجهها بالكلكون وتبييضه باسفيذاج العرائس لأنه أبلغ في الزينة من الخضاب فهو بالتحريم أولى ولها أن تستعمل الصبر في جميع بدنها إلا وجهها لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفر فيشبه الخضاب

فصل

ويحرم عليها الطيب للخبر ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة ويحرم عليها استعمال الأدهان المطيبة لأنه طيب فأما ما ليس بمطيب من الأدهان كالزيت والشيرج فلا بأس به لأن التحريم من الشرع ولم يرد بتحريمه ولا هو في معنى المحرم [ج ٣ - ص ٣٢٨]

فصل

ويحرم عليها الحلي للخبر ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي للخبر فإن صبغ غزله ثم نسج ففيه وجهان أحدهما لا يحرم لقوله إلا ثوب عصب والعصب ما صبغ غزله بل نسجه والثاني يحرم لأنه أحسن وأرفع ولأنه صبغ للتحسين أشبه ما صبغ بعد النسيج وهذا هو الصحيح وقوله إلا ثوب عصب إنما أريد به ما صبغ بالعصب وهو نبت ينبت باليمن فأما كونه مصبوغ الغزل فلا معنى له في هذا ولا يحرم الأسود ولا الأخضر المشبع والأزرق المشبع لأنه لم يصبغ لزينة إنما قصد به دفع الوسخ أو اللبس في المصيبة ونحو ذلك ولا بأس بلبس ما نسج من غزله على جهته من غير صبغ وإن كان حسنا من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيره لأن حسنه من أصل خلقته لا لزينة أدخلت عليه فأشبه حسن المرأة في خلقها قال الخرقي وتجتنب النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب وقال القاضي كره أحمد النقاب للمتوفى عنها زوجها دون المطلقة قال الخرقي فإن احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة [ج ٣ - ص ٣٢٩]

2 باب الاستبراء 2

ومنم ملك أمة بسبب من الأسباب لم تحل له حتى يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت تحيض لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام سبايا أو طاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غيره حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد في المسند وروى الأثرم عن رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم خبير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضه ولأنها إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الانساب فإن كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة ولزمه استبراؤها بحيضة مستقبلة لأن الخبر يقتضي حيضة كاملة وإن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن ففيها ثلاث روايات إحداهن تستبرىء بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة والثانية بشهرين كعدة الأمة والثالثة بثلاثة أشهر وهي أصح قال أحمد بن القاسم قلت لابي عبد الله كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا فقال من أجل الحمل فإنه لا يبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك وجمع أهل العلم

والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك ثم قال ألا تسمع قول ابن مسعود إن النطفة تكون أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فتبين حينئذ وهذا معروف عند النساء فأما شهرا فلا معنى له ولا أعلم أحدا قاله فإن ارتفع حيضها لعارض تعلمه لم تزل في استبراء حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتستبرىء استبراء الآيسات وإن لم تعلم ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر في إحدى الروايتين وفي الأخرى بسنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة مكان الحيضة

فصل

ويجب استبراء الكبيرة والصغيرة لأنه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها لأنه يراد لبراءة الرحم ولا يحتمل الشغل في حقها وإن ملك من لا تحل له كالمجوسية والوثنية فأستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان للخبر ولأن الاستبراء براد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وإن أسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى

فصل

ولا يصح الاستبراء حتى يملكها لأن سببه الملك فلم يتقدم عليه كما

لا تتقدم العدة الفرقة فإن استبرأها في مدة الخيار صح لأن الملك ينتقل بالبيع وإن قلنا لا ينتقل حتى ينقضي الخيار لم يصح الاستبراء فيه وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء على وجهين أحدهما يشترط فلو حاضت في يد البائع بعد البيع لم يصح الاستبراء لأن المقصود معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده والثاني يصح لأن سببه الملك وقد وجد فيجب أن يعقبه حكمه وإن اشترى عبده التاجر أمة فأستبرأها ثم أخذها السيد لم تحتج إلى استبراء لأن ما في يد عبده ملكه وإن اشترى مكاتبة أمة ثم صارت إلى السيد لعجزه أو قبضها من نجوم كتابته لم تبح بغير استبراء لأنه يتجدد ملكه بأخذها من مكاتبه إلا أن يكون ذا رحم محرم للمكاتب فيحل لأن حكمها حكم المكاتب إن رق رقت وإن عتق عتقت والمكاتب مملوك فلو كاتب أمته ثم عجزت أو رهنها ثم فكها أو ارتدت ثم أسلمت أو ارتد سيدها ثم أسلم حلت بغير استبراء لأنها لم تخرج عن ملكه وإنما حرمت بعارض زال فأشبه ما لو حرمت ثم حلت

فصل

وإن باعها السيد ثم ردت عليه بفسخ أو مقايلة بعد قبض المشتري لها وافتراقهما وجب استبراؤها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وإن كان قبل افتراقهما ففيه روايتان إحداهما يجب

استبراؤها لأنه تجديد ملك فأشبه شراء الصغيرة والثانية لا يجب لأن تيقن البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول وإن زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول لم يجب استبراؤها لأن ملكه لم يتجدد عليها وإن فارقها بعد الدخول أو مات عنها لم تحل حتى تقضى العدة

فصل

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول وجب استبراؤها لأنه تجديد ملك وإن طلقها بعد دخوله بها أو مات عنها فعن أحمد ما يدل على أنه يكتفى بعدتها لأن براءتها تعلم بها وقال أبو الخطاب فيها وجهان أحدهما يدخل الاستبراء في العدة كذلك والثاني لا يدخل لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين من رجلين وإن اشتراها وهي معتدة فقال القاضي يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء لأن المقصود يحصل بذلك

فصل

ومن ملك زوجته لم يلزمه استبراؤها لأنه لصيانة الماء وحفظ النسب ولا يصان ماؤه عن مائة لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من نكاح عليه ولاء أو من ملك يمينه فلا ولاء عليه [ج ٣ - ص ٣٣٣]

فصل

وإن اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها لأنها محرمة عليه بملك اليمين فحرم نكاحها كأخته من الرضاع ولأن ذلك يفضي إلى اختلاط المياه وفساد النسب بأن يطأها البائع ثم يبيعها فيعتقها المشتري ويتزوجها ويطأها في يوم واحد ولها أن تتزوج غيره إن لم يكن البائع يطأها لأنها لم تكن فراشا فأبيح لها التزوج كما لو أعتقها البائع وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لزمها استبراء نفسها لأنها صارت بالوطء فراشا له فلزمها الاستبراء عند زوال الفراش كالزوجة إذا طلقت فإن أراد معتقها أن يتزوجها في استبرائها جاز لأنه لا يحفظ ماؤه عن مائه وإن أعتق أمة لم يكن يطؤها فليس عليها استبراء لأنها ليست فراشا وله أن يتزوجها عقيب عتقها لأنها مباحة لغيره فله أولى وعنه لا يتزوجها حتى يستبرئها قال ابن عقيل هذا محمول على الاستحباب لما ذكرنا

فصل

ومن ملك أمة يلزمه استبراؤها لم يحل له التلذذ بها بالنظر والقبلة ونحوه لأننا لا نأمن كونها حاملا من البائع فتكون أم ولده فيحصل مستمتعا بأم ولد غيره إلا أن يملكها بالسبي فيكون فيها روايتان إحداهما يباح له ذلك لأنه لا يخشى انفساخ ملكه لها بحملها فلا يكون مستمتعا إلا بمملوكته [ج ٣ - ص ٣٣٤]

والثانية يحرم لأن ما حرم به الوطء حرم دواعيه كالعدة وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة أو زنى لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها وفي التلذذ بغير الوطء وجهان بناء على الروايتين

فصل

ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤها لم يلزمه استبراؤها لأنه قد حصل يقين برائتها منه فإن كان يطؤها ففيها روايتان إحداهما يجب لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري والثانية لا يجب لأنه يجب 0 على المشتري فأغنى عن استبرائها البائع

فأما إن أراد تزوجها أو تزوج أم ولده لم يجز قبل استبرائها لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وله تزويج أمته التي لا يطؤها من غير استبراء لأنها ليست فراشا له

فصل

وإن مات عن أم ولده لزمها الاستبراء لأنها صارت فراشا وتستبرىء كما تستبرىء المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه تستبرىء بأربعة أشهر

وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا

[ج ٣ - ص ٣٣٥]

سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة اشهر وعشر ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فلزمها أربعة اشهر وعشر كعدة الزوجة والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد

فصل

وإن مات عنها أو أعتقها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها استبراء لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء فلم يجب كما لو طلق امرأته قبل الدخول وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه وقال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلى أن يعيدها إلى نفسه لأن الفراش زال بالتزويج فلا يعود إلا باعادتها إلى نفسه فإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما فعلى قول أبي بكر عليها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة لأنه يحتمل أن سيدها مات أولا ثم مات زوجها وهي حرة فلزمتها عدة الحرة لتبرأ بيقين وعلى القول الأول إن كان بينهما دون شهرين وخمسة أيام فليس عليها بعد الآخر منهما إلا عدة الحرة من الوفاة لأن الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال لكون موت سيدها إن كان أولا فقد مات وهي مزوجة وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها في الحالين وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين من عدة حرة من الوفاة أو [ج ٣ - ص ٣٣٦]

الاستبراء لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين ولا ترث الزوج لأن الأصل الرق فلا ترث مع الشك

فصل

وإذا كانت الأمة بين نفسين فوطئاها لزمها استبراءان لأنهما من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين

فصل

إذا اشترى أمة فظهر بها حمل فقال البائع هو مني وصدقه المشتري لحقه الولد والجارية أم ولد والبيع باطل وإن كذبه المشتري نظرنا فإن كان البائع أقر بوطئها عند البيع وأتت بالولد لدون ستة أشهر فهو ولده والبيع باطل وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا وكان البائع استبرأها قبل بيعها ولم يطأها المشتري أو وطئها لكن ولدته لدون ستة أشهر منذ وطئها لم يلحق بواحد منهما وكانت الجارية والولد مملوكين للمشتري وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حيث وطء المشتري فهو ولده والجارية أم ولده وإن لم يستبرئها واحد منهما فأتت بولد لدون أربع سنين منذ باعها ولأكثر من ستة أشهر منذ وطئها المشتري عرض على القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وقد روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف

جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصموه إلى عمر فقال له عمر كنت تقع عليها قال نعم قال فبعتها قبل أن تستبرئها قال نعم قال ما كنت لذلك بخليق فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به فإن لم يكن البائع أقر بوطئها حين بيعها فادعاه بعد ذلك وكذبه المشتري لم تقبل دعواه في الولد لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان عتقه والقول قول المشتري مع يمينه وهل يلحقه نسب الولد فيه وجهان أحدهما يلحقه لأنه يجوز أن يكون ابنا لواحد مملوكا لآخر كولد الأمة المزوجة والثاني لا يلحق لأن فيه ضررا على المشتري فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه منه والله سبحانه وتعالى أعلم [ج ٣ - ص ٣٣٨]

إذا ثاب للمرأة لبن على ولد فأرضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وصارت أمهاتها جداته وآباؤها أجداده وأولادها إخوته وأخواته وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته لقوله تعالى ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعه متفق عليهما

فصل

وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاد ولده وصار الرجل أبا له وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وأولاده إخوته وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته لما روت

عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أخيه فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك متفق عليه ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرضع بلبنه ولدهما فإن لم يكن الولد ثابت النسب من رجل كولد الزنى والمنفي باللعان فمفهوم كلام الخرقي أنه لا ينشر الحرمة بينهما لأن النسب لم يثبت فالتحريم المتفرع عليه أولى وهذا قول ابن حامد ولكن إن كان المرتضع أنثى حرمت تحريم المصاهرة لأنها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة الزاني وكذلك أولادها وأولاد الطفل ان كان ذكرا وقال أبو بكر ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ والزوج الملاعن لأن التحريم ثابت بينهما وبين المولود فكذلك في المرتضع لأنه فرعه ولأنه أحد المتواطئين فتنتشر الحرمة إليه كالمرأة ويحتمل أن ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتضع لأن الولد منه حقيقة فكان اللبن منه ولا ينشر من المرتضع والملاعن فإن اللبن لم يثبت منه حقيقة ولا حكما [ج ٣ - ص ٣٤٠]

فصل

وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سلفوا لأنهم أولاد أولاد المرضعة ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فللمرضعة نكاح أب الطفل وأخيه ولزوجها نكاح أمه وأخته ولأخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه كذلك الرضاع المتفرع عليه

فصل

ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد حولين لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فجعل تمامها في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي هذا حديث صحيح

فصل

واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع فروي أن قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصيام لقوله تعالى ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ﴾ وقوله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [ج ٣ - ص ٣٤١]

وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما مسلم وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب لما روي عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر الآخر لأنه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق أقوى منه فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك

فصل

واختلف أصحابنا في الرضعة فقال أبو بكر متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه فهي رضعة سواء قطع اختيارا أو لعارض من تنفس أو أمر يلهيه أو انتقال من ثدي إلى آخر أو قطعت المرضعة عليه فإذا عاد فهي رضعة ثانية وقال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس أو غيره سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج لأن

قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجه ولا [ج ٣ - ص ٣٤٢]

الإملاجتان يدل على أن لكل مصة أثرا ولأنه لو تباعد ما بينهما كانا رضعتين فكذلك إذا تقاربا ولأن القليل من الوجور والسعوط رضعة فالامتصاص أولى وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان لأن الآكل لو قطع الأكل لشرب أو عارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة فكذلك الرضاع

فصل

ويثبت التحريم بالوجور وهو أن يصب اللبن في حلقه لأنه ينشر العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع وبالسعوط وهو أن يصب في أنفه لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم وعنه لا يثبت التحريم بهما لأنهما ليسا برضاع وإن جمد اللبن فجعل جبنا وأكله الصبي فهو كالوجور ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عنه لأنها تراد للإسهال لا للتغذي فلا تنبت لحما ولا تنشر عظما وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود وقال ابن حامد وابن أبي موسى ينشر الحرمة لأنه واصل إلى الجوف أشبه الواصل إلى الأنف وإن قطر في إحليله لم ينشر الحرمة وجها واحدا لأنه ليس برضاع ولا في معناه [ج ٣ - ص ٣٤٣]

فصل

إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقته صبيا في أوقات خمسة فهو خمس رضعات وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة لأن الاعتبار بشرب الصبي فإن التحريم يثبت به فاعتبر تفرقه واجتماعه وإن سقت الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة فعلى قول ابن حامد هو رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاع وإن حلبت امرأتان في إناء واحد وسقتاه صبيا في خمسة أوقات صار ابنهما لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة

فصل

واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة ذكره الخرقي وهذا إذا كانت صفات اللبن باقية فإن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشر عظما ولا ينبت لحما وقال أبو بكر قياس قول أحمد أن المشوب لا ينشر الحرمة لأنه وجور وحكي عن ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإن غلب خلطه لم يحرم لأن الحكم للأغلب ويزول حكم المغلوب والأول أصح لأن ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة والخمر وسواء شيب بمائع كالماء والعسل أو بجامد مثل أن يعجن به أقراص ونحوها لأنه مشوب [ج ٣ - ص ٣٤٤]

فصل

ويحرم لبن الميتة لأنه لبن آدمية ثاب على ولد فأشبه لبن الحية وقال الخلال لا ينشر الحرمة لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة فلم تتعلق في حال الموت كالوطء وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتها كان حكمه كحكم ما لو سقي في حياتها لأنه انفصل عنها في الحياة

فصل

ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة لأن الأخوة فرع على الأمومة ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولا تثبت بلبن رجل لأنه لا يجعل غذاء للمولود فأشبه لبن البهيمة ولا بلبن خنثى مشكل لأنه لا يعلم أنه امرأة فلا يثبت التحريم بالشك وقال ابن حامد يقف الأمر حتى يتبين أمر الخنثى فإن أيس من انكشافه بموته أو غيره ثبت الحل لما ذكرنا وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال أبو الخطاب نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل وذكر ابن أبي موسى فيه روايتين إحداهما ينشر الحرمة لأنه لبن آدمية أشبه لبن ذات الحمل وهذا قول ابن حامد لأنه جعل لبن الخنثى موقوفا ولو كان تقدم الحمل شرطا في التحريم لما وقف أمره لأننا تيقنا عدمه [ج ٣ - ص ٣٤٥]

فصل

وإذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا إنه ينشر الحرمة فأرضعت به طفلا صار ابنا لها ولم يصر ابنا لزوجها لأنه لم يثب بوطئه فلم يكن منه وإن وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عمن ينتفي عنه سواء ثبت بالقافة أو بغيرها لأن اللبن تابع للولد فإن ألحقته القافة بهما فالمرتضع ولدهما وإن أشكل أو لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما لأنه ولد لهما أو ولد لأحدهما فتحرم عليه بنات من هو ولد له وقد اشتبهت الأنساب المحرمة بغيرها فيحرمان كما لو اختلطت أخته بأجنبيات ولا تثبت المحرمية بينه وبين واحدة منهن كذلك

فصل

ولو طلق الرجل زوجة له منها لبن فتزوجت صبيا رضيعا فأرضعته صار ابنها وابن مطلقها فينفسخ نكاحها لأنها صارت أمه وتحرم على المطلق لأنها صارت من حلائل أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته ولو زوج رجل أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها وحرمت على سيدها كذلك وإن زوجها صبيا حرا لم يصح نكاحه لأن من شرط نكاح الإماء خوف العنت وهو معدوم في الصبي فإن أرضعته لم تحرم على

سيدها لأنه ليس بزوج في الحقيقة وإن تزوجت صغيرا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فأولدها وأرضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه حرمت على زوجها على التأبيد لأنها صارت من حلائل أبنائه

فصل

وإن طلق الرجل زوجته وهي ذات لبن منه فتزوجت آخر ولم تحمل منه فاللبن للأول سواء زاد بوطء الثاني أو لم يزد لأن اللبن للولد وإن حملت من الثاني ولم تلد ولم ينقطع لبن الأول ولم يزد فهو للأول أيضا كذلك وإن ولدت من الثاني فاللبن له وحده انقطع لبن الأول أو اتصل زاد أو لم يزد لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه من غيره وإن لم تلد من الثاني واتصل لبن الأول وزاد بالحمل من الثاني فاللبن منهما لأن اتصال لبن الأول دليل على أنه منه وزيادته عند حدوث الحمل دليل على أنها منه فيضاف إليهما وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بالحمل من الثاني فقال أبو بكر هو منهما لأن الظاهر أن لبن الأول عاد وسببه وطء الثاني فيضاف إليهما كالتي قبلها وقال القاضي يحتمل أنه من الثاني وحده لأن لبن الاول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون منه وهذا اختيار أبي الخطاب [ج ٣ - ص ٣٤٧]

فصل

إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة أو ثلاث زوجات فارتضع من كل واحدة رضعتين لم يصرن أمهات له لأنه لم يكمل رضاعه من واحدة منهن وصار السيد والزوج أبا له في أصح الوجهين لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعه من لبنه فصار أبا له كما لو ارضعته واحدة خمسا والثاني لا يصير أبا له لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الابوة كلبن البهيمة ولو أرضعته بغير لبن السيد لم يصر السيد أبا له بحال ولا يحرم أحدهما على الآخر في أصح الوجهين لأن تحريمه عليه فرع كونه ولدا لهن ولم يثبت وفي الآخر يحرم لانه كمل له الرضاع من موطوآت السيد فحرم عليه كما لو كمل له من واحدة ولو كان للمرأة خمس بنات لهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وهل تصير المرأة جدة له والزوج جدا وابنها خالا له على الوجهين فإن قلنا بالوجه الاول حرمت أمهات الأولاد على الطفل في المسألة الاولى لأنهن موطوآت أبيه وبنات المرأة في الثانية لأنهن بنات جده وجدته وإن كن ستا فارتضع من كل واحدة رضعة صارت كل واحدة خالته لأنه قد ارتضع من أخواتها خمس رضعات وإن قلنا بالوجه الثاني لم يحرمن لعدم الأسباب المحرمة وإن كمل الطفل خمس

رضعات من أم رجل وأخته وزوجته وابنته وزوجة ابنه وزوجة أبيه خرج على الوجهين فأما إن أرضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج ثم انقطع لبنها وتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت له أما وجها واحدا لأنه كمل رضاعه من لبنها ولم يصر الرجلان أبوين له لأنه لم يكمل رضاعه من لبن واحد منهما لكنه يحرم عليهما لأنه ربيبهما

فصل

إذا تزوج رجل صغيرة فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه حرمتا عليه على التأبيد لأن الصغرى بنته والكبرى من أمهات نسائه وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بها حرمتا أيضا على التأبيد لأن الكبرى من أمهات نسائه والصغرى ربيبته المدخول بأمها وإن كان ذلك بعد طلاقهما أو طلاق إحداهما فكذلك لما ذكرنا ولو تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما لأنهما من أمهات نسائها وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لأنها ربيبته مدخول بأمها ولا تحرم على الآخر لعدم دخوله بأمها وإن أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بلبن غيره ولم يكن دخل بالكبرى حرمت الكبرى وفي الصغرى وجهان أحدهما

ينفسخ نكاحها لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح فانفسخ نكاحها كما لو صارتا أختين والثاني لا ينفسخ نكاحها اختاره الخرقي لأن الكبرى أولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد فتبقى هذه منفردة به بخلاف الأختين فإنه ليس واحدة منهما أولى من الأخرى

فصل

وإن أرضعتها بنت الكبرى فهو كرضاع الكبرى سواء لأنهما صارت بنت بنتها وإن أرضعتها أمها صارت زوجتاه أختين فانفسخ نكاحهما كذلك وإن أرضعتها جدتها صارت الصغرى خالة الكبرى أو عمتها وإن أرضعتها أختها صارت الكبرى خالتها وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه صارت عمتهما وينفسخ نكاحها في جميع ذلك وله نكاح من شاء منهما

فصل

وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معا أو إحداهما بعد الأخرى انفسخ نكاحهما معا لأنهما صارتا أختين وله أن ينكح من شاء منهما وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها حرم الكل عليه على الأبد وإن لم يدخل بها فأرضعتهما معا انفسخ نكاحهما وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى ففيه وجهان أحدهما ينفسخ نكاح الأولى لأنها [ج ٣ - ص ٣٥٠]

اجتمعت مع أمها في النكاح ويثبت نكاح الثانية لأنها لم تصر أختا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها والثاني لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها فإذا أرضعت الثانية صارتا أختين فانفسخ نكاحهما وإن تزوج ثلاث صغار فأرضعتهن امرأة معا أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاحهن جميعا لأنهن صرن أخوات وإن أرضعتهن منفردات انفسخ نكاح الأوليين لأنهما صارتا أختين في نكاحه وثبت نكاح الثالثة لأنها لم تصر أختا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها فكذلك في قول الخرقي وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع

فصل

وكل من تحرم عليه ابنتها كأمه وابنته وأخته وجدته وزوجة أخيه بلبن أخيه إذا أرضعت زوجته الصغرى حرمتها عليه على التأبيد وفسخت نكاحها كذلك لأنها تجعلها بنتا لها ومن لا تحرم ابنتها كعمته وخالته وامرأة عمه وخاله لا يضر رضاعها شيئا لأن ابنتها حلال له ولو تزوج ابنة عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو خالته وهما صغيران فارتضع أحدهما من جدتهما انفسخ نكاحهما لأن أحدهما يصير عم صاحبه أو خاله

فصل

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها وهو النصف لأنه قرره عليه بعد أن كان يعرض للسقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا وإن اشترك في الإفساد جماعة فالضمان بينهم مقسوما على عدد الرضعات لاشتراكهم في السبب وإن كانت المرأة هي المفسدة لنكاحها فلا صداق لها فإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما فلا مهر للكبرى ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى وإن دبت الصغرى ارتضعت من الكبرى وهي نائمة فلا مهر للصغرى ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى وإن ارضتعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعات فعليه للصغرى خمس صداقها وعشره يرجع به على الكبرى والكبرى خمس صداقها برجع به على الصغرى وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر لأنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت وإن أفسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه كذلك والمنصوص عن أحمد أنه يرجع عليه بصداقها لأنه نكاح أفسد فوجب على المفسد غرامة ما وجب على الزوج كقبل الدخول

فصل

إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ نكاحه لأنه مقر على نفسه ثم إن صدقته وكان قبل الدخول فلا مهر لها لأنه نكاح باطل لا دخول فيه وإن كذبته لم يسقط صداقها ولزمه نصفه لأن الأصل الحل وصحة النكاح وإن كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها فهي زوجته في الحكم ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه لأنه حق له عليها لكن إن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها بسقوطه وإن قال الزوج هذه ابنتي من الرضاع وهي مثله أو أكبر منه لم تحرم عليه لأننا نتحقق كذبه

[ج ٣ - ص ٣٥٣]

1 كتاب النفقات 1

2 باب نفقة الزوجات 2

يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد ولم تكن شرطت دارها ولا بلدها فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكين التام فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو من تسليمه في موضع دون موضع وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لأنها بذلت الواجب عليها وإن كان غائبا لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمن لوسار لقدر على أخذها لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلك وإن لم تسلم إليه ولم تعرض عليه فلا نفقة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فلم ينفق عليها [ج ٣ - ص ٣٥٤]

حتى أدخلت عليه ولأنه لم يوجد التمكين فلم تجب النفقة كما لو منعت نفسها

فصل

ولو عرضت عليه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها وإن كانت كبيرة والزوج صغير وجبت نفقتها لأن التمكين وجب من جهتها وإنما تعذر من جهته فوجبت النفقة كما لو سلمت إليه وهو كبير فهرب منها وإن سلمت إليه وهو مجبوب أو مريض لا يمكنه الوطء وجبت النفقة كذلك وإن سلمت إليه وهي رتقاء أو نحيفة أو مريضة لا يمكن وطؤها وجبت نفقتها لأن تعذر الاستمتاع لسبب لا تنسب إلى التفريط فيه

فصل

وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لها وإن كان غائبا لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فأشبهت الناشز وإن سافرت بإذنه فعلى ما ذكرناه في القسم وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب من الميقات لم تسقط نفقتها لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع فأشبه ما لو صامت رمضان وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها

منعته الاستمتاع بما لا يجب عليها فهو كسفرها بغير إذنه وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجتها وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا لها النفقة وينبغي أن يقال إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه فأشبه السفر لحاجتها

فصل

وصوم رمضان لا يسقط النفقة لأنه واجب معين والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلك وأما قضاء رمضان فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة لأنه واجب مضيق أشبه رمضان وإن كان وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت

فصل

وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة لأن الإسلام واجب عليها مضيق أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته وإن أسلم هو دونها وهي غير كتابية فلا نفقة لها لأنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرها وإن ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك وإن كان هو المرتد فعليه النفقة لأنه الممتنع بردته وإن عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت [ج ٣ - ص ٣٥٦]

ولو كان غائبا لأن سقوط نفقتها لردتها فعادت بزوالها وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لوسار فيه لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة

فصل

وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه فإن سلمت إليه ليلا ونهارا فلها النفقة كلها كالحرة وان سلمت ليلا دون النهار فلها نصف نفقتها لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه فكان لها نفقتها فيه كالحرة في جميع الزمان

فصل

ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لأنه ليس بنكاح شرعي

2 باب نفقة المعتدة 2

وهي ثمانية أقسام أحدها الرجعية فلها النفقة والسكنى لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع أشبه ما قبل الطلاق

الثاني البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى

لقوله تعالى ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل فيه وجهان أحدهما للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه والثاني تجب لها بسببه لأنها تجب مع الإعسار ونفقة الولد لا تجب على معسر وإن كانت حائلا فلا نفقة لها لدلالة الآية بدليل خطابها على عدمها وفي السكنى روايتان إحداهما تجب للآية والأخرى لا تجب لحديث فاطمة بنت قيس وهو مفسر للآية فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد ولا للأمة الحامل لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه وإن قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب النكاح

فصل

الثالث المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة وإن كانت حاملا ففي وجوبها روايتان إحداهما لا تجبان كذلك والثانية تجبان لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة [ج ٣ - ص ٣٥٨]

فصل

الرابع المعتدة من اللعان فإن كانت حائلا أو منفيا حملها فلا نفقة لها ولا سكنى لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت رواه أبو داود ولأنها بائن لا ولد له معها أشبهت المختلعة الحائل وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلها النفقة والسكنى لأن ذلك يجب للحمل أو لسببه وهو موجود فإن نفاه فأنفقت وسكتت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت وأجرة رضاعها ومسكنها لأنها فعلت ذلك على انه لا أب له وقد بان خلافه

فصل

الخامس المعتدة من وطء شبهة أو نكاح فاسد إذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال لانه إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاح هاهنا ولا نفقة لها إن كانت حائلا وإن كانت حاملا وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت لأن الحمل هاهنا لا حق به فأشبه الحمل في النكاح الصحيح وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها لأن حرمته هاهنا غير كاملة

فصل

السادس الزانية لا نفقة لها ولا سكنى بحال لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها [ج ٣ - ص ٣٥٩]

فصل

السابع زوجة المفقود لها النفقة لمدة التربص لأنها محبوسة عليه في بيته فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته فلا تجب إلا بعودها إليه وإن لم ترد إليه فلا نفقة لها بحال

فصل

الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة وقد تقدم بيان حكمها

فصل

ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم لقوله تعالى ﴿ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ في الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعيب فكذلك في وجوب النفقة لها وقال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يجب دفع النفقة إليها حتى تضع الحمل لأنه لا يتحقق ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين والمذهب الأول فإن أنفق عليها ثم تبين أنها غير حامل رجع عليها لأنه دفعها إليها على أنها واجبة فرجع عليها كما لو قضاها دينا ثم تبين براءته منه وعنه لا يرجع عليها لأنه لو كان النكاح [ج ٣ - ص ٣٦٠]

فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما لم يرجع كذا هاهنا وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل ثم تبين أنها حامل رجعت عليه لأننا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم ترى القوابل فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها وإن بان خلافه رجع عليها

2 باب قدر النفقة 2

يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه ولأن الله قال ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ والمعروف قدر الكفاية ولأنها نفقة واجبة لدفع الحاجة فتقدرت بالكفاية كنفقة المملوك فإذا ثبت أنها غير مقدرة فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم وقال القاضي هي مقدرة برطلي خبز بالعراقي وما يكفيها من الأدم لأن الواجب للمسكين في الكفارة رطلان ويجب لها في القوت الخبز لأنه المقتات في العادة وقال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ الخبز والزيت وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم ويجب لها من

الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد من الزيت والشيرج والسمن واللبن واللحم وسائر ما يؤندم به لأن ذلك من النفقة بالمعروف وقد أمر الله تعالى ورسوله به

فصل

ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره لقوله تعالى ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾ وتعتبر حال المرأة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما وللمتوسطة تحت المتوسط وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته لأن إيجاب نفقة الموسرين على المعسر وإنفاق الموسر نفقة المعسرين ليس من المعروف وفيه إضرار بصاحبه وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر لأنهما ليسا بأحسن حالا منه ومن نصفه حر إن كان معسرا فهو كالمعسرين وإن كان موسرا فهو كالمتوسطين

فصل

فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدم أو الحب والدقيق لم يلزمها قبوله لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع فلم يجب أخذ عوضه [ج ٣ - ص ٣٦٢]

كالكفارة وإن اتفقا على ذلك جاز لأنه حق آدمي فجاز أخذ عوضه باتفاقهما كالقرض

فصل

ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والماء والسدر لغسله وما يعود بنظافتها لأنه يراد للتنظيف فيجب عليه كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها ولا يلزمه ثمن الخضاب لأنه للزينة فأشبه الحلي ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب لأنه ليس من النفقة الراتبة إنما يحتاج إليه لعارض وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهك والريح الكريهة والعرق لزمه لأنه يراد للتنظيف وما يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه

فصل

وتجب الكسوة للآية والخبر ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمته كالنفقة ويجب للموسرة تحت الموسر من رفيع ما يلبس في البلد من الإبريسم والخز والقطن والكتان وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس كما قلنا في النفقة وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل وجبة للشتاء لأن ذلك من

الكسوة بالمعروف وملحفة وكساء أو مضربة محشوة للنوم وبساط ولبد أو حصير للنهار ويكون ذلك من الرفيع للأولى ومن الأدون للثانية ومن المتوسط للثالثة لأنه من المعروف

فصل

ويجب لها مسكن لأنها لا تستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون للتصرف والاستمتاع ويكون ذلك على قدرهن كما ذكرنا في النفقة

فصل

وإن كانت ممن لا يخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وإخدامها من العشرة بالمعروف ولا يجب لها أكثر من خادم لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة أو ذا رحم محرم أو صغير وهل يجوز أن تكون كتابية فيه وجهان بناء على إباحة النظر لهن فإن قلنا بجوازه فهل يلزم المرأة قبولها فيه وجهان أحدهما يلزمها قبولها لأنهن يصلحن للخدمة والثاني لا يلزمها لأن النفس تعافهن وإن قالت المرأة أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم لم يلزم الزوج لأن القصد بالخدمة ترفيهها وتوفيرها على حقه وذلك يفوت بخدمتها وإن قال أنا أخدمك بنفسي ففيه وجهان أحدهما يلزمها الرضى به لأن الكفاية

تحصل به والثاني لا يلزمها لأنها تحتشمه فلا تستوفي حقها من الخدمة ولا يلزمه أن يملكها خادما بل إن كان له أو استأجره جاز وإن كان مملوكا لها فاتفقا على خدمته لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين في القوت والأدم والكسوة ولا يجب له مشط ولا سدر ولا دهن للرأس لأنه يراد للتنظيف والزينة ولا يراد ذلك من الخادم ويجب للخادمة خف إذا كانت تخرج إلى الحاجات لحاجتها إليه

فصل

وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمس لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تعجيلها أو تأخيرها أو تسليفها النفقة لشهر أو عام أو أكثر جاز لأن الحق لا يخرج عنهما فجاز فيه ما تراضيا عليه كالدين فإن دفع إليها نفقة يوم فبانت فيه لم يرجع بما بقي لأنها أخذت ما تستحقه وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها لأنه غير مستحق لها وذكر القاضي ما يدل على أن حكم ذلك حكم الرجوع في معجل الزكاة على ما ذكر في موضعه فأما إن غاب عن زوجته زمنا ولم ينفق عليها فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إن طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى ولأنه حق لها عليه بحكم العوض فرجعت به عليه كالدين وعنه لا ترجع عليه إلا أن [ج ٣ - ص ٣٦٥]

يكون الحاكم قد فرضها لها لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب

فصل

وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله لأنه العادة فإن تلفت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها لأنه من تفريطها فأشبه ما لو أتلفتها وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل ففيه وجهان أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة والثاني يجب لأن الاعتبار بالمدة بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة لم يلزمه بدلها وإن كساها ثم أبانها ففيه وجهان أحدهما لا يرجع لأنه دفع ما تستحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم والثاني يرجع لأنه دفع لزمن مستقبل أشبه ما لو أسلفها النفقة ثم أبانها

فصل

وإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرها لأنها حق لها فملكت التصرف فيها كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه وكذلك الحكم في النفقة والكسوة في أحد الوجهين وفي الآخر ليس لها التصرف فيها بحال لأنه يملك استرجاعها بطلاقها بخلاف النفقة [ج ٣ - ص ٣٦٦]

فصل

وإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها لأنها تستحقها في مقابلة التمكين من استمتاعها وقد فات ذلك بنشوزها وإن كان لها ولد لم تسقط نفقته لأن ذلك حق له فلا تسقط بنشوزها

2 باب قطع النفقة 2

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها فسخ النكاح لقوله تعالى ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بإحسان وكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ولأنه إذا ثبت لها الفسخ لعجزه عن الوطء فلأن يثبت بالعجز عن النفقة أولى لأن الضرر فيه أكثر وإن أعسر ببعضها فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها وإن أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها فأشبهت القوت وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها لأنها تسقط بإعساره ولأن البدن يقوم بدونها وإن أعسر بالأدم أو نفقة الخادم فلا خيار لها لأن البدن يقوم بدونها ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن هذا هو الواجب وإن كان يجد في أول النهار

ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها لأنها تصل إلى كفايتها وإن كان يجد قوت يوم دون يوم فلها الخيار لأنها لا تصل إلى كفايتها وإن كان صانعا يعمل في كل أسبوع ثوبا يكفيه ثمنه للأسبوع كله فلا خيار لها لأنها تصل إلى كفايتها ومتى أعوز أمكنه الاقتراض ثم يقضيه فلا تنقطع النفقة فإن كانت نفقته من عمل عجز عنه لمرض مرجو الزوال أو غيبة ماله وأمكنه الاقتراض إلى زوال المرض وفعل فلا خيار لها وإن عجز عن الاقتراض وكان العارض يزول في ثلاثة أيام فما دون فلا خيار لها لأن ذلك قريب وإن كثر فلها الفسخ لأن الضرر يكثر وان أعسر بالمسكن ففيه وجهان أحدهما لا خيار لها لأن البدن يقوم بدونه والثاني لها الخيار لأنه مما لا بد منه أشبه النفقة والكسوة

فصل

فإن منع النفقة مع يساره وقدرت له على ما أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف لما روي أن هندا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه وإن منعها بعض الكفاية فلها أخذه للخبر ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير للخبر فإن وجدت من جنس الواجب لها أخذته وإن لم تجد أخذت بقدره من غيره [ج ٣ - ص ٣٦٨]

متحرية للعدل في ذلك فإن لم تجد ما تأخذه رفعته إلى الحاكم ليأمره بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه وإن لم يجد إلا عروضا باعها وأنفق منها فإن تعذر ذلك فلها الفسخ لما ذكرنا من حديث عمر ولأنه إذا ثبت الفسخ مع العذر دفعا للضرر فمع عدمه أولى وإن كان الزوج غائبا كتب الحاكم إليه كما كتب عمر إلى الذين غابوا عن نسائهم فإن لم يعلم خبره أو تعذرت النفقة منه ولم يوجد له مال فلها الفسخ لما ذكرنا وهذا اختيار الخرقي وأبي الخطاب وذكر القاضي أن الفسخ لا يثبت مع اليسار لأن الخيار لعيب الإعسار ولم يثبت ذلك فيه وما ذكرناه أصح فإن الإعسار ليس بعيب وإنما الفسخ لدفع الضرر وهما فيه سواء ومن كان له دين يتمكن من استيفائه فهو كالموسر لأنه قادر عليه وإن لم يتمكن من استيفائه فهو كالمعدوم لأنه عاجز عنه

فصل

فإذا كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة فأراد أن يحتسب به عليها وهي موسرة فله ذلك لأن له أن يقضي دينه من أي ماله شاء وهذا منه وإن كانت معسرة لم يملك ذلك لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لها [ج ٣ - ص ٣٦٩]

فصل

ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والأدم والكسوة والمسكن والخادم تطالبه بها إذا أيسر لأنها حقوق واجبة عجز عنها فثبتت في ذمته كالدين وقال القاضي لا يثبت في ذمته شيء قياسا على الزائد عن نفقة المعسر والفرق ظاهر فإن الزائد غير واجب على معسر وهذا معسر بخلاف هذا ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الإقامة في منزله لأن ذلك في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها ومتى عن لها الفسخ فلها الفسخ لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد حق الفسخ ولو تزوجت معسرا عالمة بإعساره ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ لما ذكرنا وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ في الموضعين لأنها رضيت بعيبه فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعنته

فصل

وإن اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ بالعنة ولها المطالبة بالفسخ في الحال لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري

فصل

وإن أعسر زوج الأمة فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لأن الحق لها فلم يكن له الفسخ كالفسخ للعنة وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليها الفسخ لأنه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب وحكي عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخ لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن

فصل

وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر ولأنه مال يجب على سبيل البدل في حق معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق وإن أعسر بقضائها لم تملك الفسخ لأنها دين يقوم البدن بدونه فأشبهت دين القرض وعنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لأنها نفقة تجب يوما بيوم فإذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمان كنفقة الأقارب فعلى هذا لا يصح ضمانها لأنها ليس مآلها إلى الوجوب وعلى الرواية الأولى يصح ضمان ما وجب منها ومايجب في المستقبل لأن مآله إلى الوجوب [ج ٣ - ص ٣٧١]

فصل

وإذا ادعى الزوج أنه دفع إليها نفقتها فأنكرته فالقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم القبض وإن مضت مدة لم ينفق فيها فادعت أنه كان موسرا فأنكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدمه وإن عرف له مال فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه وإن قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر فالقول قوله كذلك وإن ادعى نشوزها فأنكرته فالقول قولها كذلك وإن طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا فقال الزوج طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به وقالت بل بعده لم يبق له رجعة لإقراره بانقضاء عدتها ولزمتها العدة لإقرارها بها والقول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لأن الأصل بقاؤها [ج ٣ - ص ٣٧٢]

2 باب نفقة الأقارب 2

وهم صنفان عمود النسب وهم الوالدان وإن علوا والولد وولده وإن سفل فتجب نفقتهم لقوله تعالى ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه وقال الله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة وثبتت نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لدخولهم في اسم الآباء والأولاد قال الله تعالى ﴿ ملة أبيكم إبراهيم ﴾ وقال تعالى ﴿ يا بني آدم ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين إن ابني هذا سيد وسواء كان وارثا أو غير وارث لأن أحمد قال لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإذا منع دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم وذكر القاضي مايدل على هذا وذكر في موضع آخر أنه لا تجب النفقة إلا على وارث وهو ظاهر قول الخرقي وغيره من أصحابنا

الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج لقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ إلى قوله [ج ٣ - ص ٣٧٣]

﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول رواه أبو داود وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد

فصل

فأما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم في المنصوص لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم على المنصوص لضعف قرابتهم ويتخرج وجوبها عليهم لأنهم يرثون في حال فتجب النفقة عليهم في تلك الحال وإن كان الوارث غير موروث كالمعتقة وعم المرأة وابن عمها وابن أخيها والمعتق وجب عليهم الإنفاق في المنصوص لأنهم وارثون فيدخلون في العموم وعنه لا نفقة عليهم لأنهم غير موروثين أشبهوا ذوي الأرحام

فصل

ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط أحدها فقر من تجب نفقته فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة وإن قدر على الكسب من

غير حرفة ففيه روايتان إحداهما لا نفقة له لأنه يستغني بكسبه أشبه المحترف والثانية له النفقة لأنه لا مال له ولا حرفة أشبه الزمن

الثاني أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية وكذلك نفقة زوجته لأنها تجب لحاجته فأشبهت نفقة نفسه وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدم كذلك

الثالث اتفاقهما في الدين والحرية فلا يجب على الإنسان الإنفاق على من ليس على دينه لأنه لا ولاية بينهما ولا يرث أحدهما صاحبه ولأنها تجب على سبيل المواساة والصلة فلم تجب له مع اختلاف الدين كالزكاة وعنه في عمودي النسب أنها تجب مع اختلاف الدين لأنهم يعتقون عليه فينفق عليهم كما لو أنفق دينهما واما العبد فلا نفقة عليه لأنه لا شيء له يواسي به فلا تجب نفقته على قريبه لأن نفقته على سيده ولأنه لا توارث بينهما ولا ولاية فلم ينفق أحدهما على صاحبه كالأجانب

فصل

ولا يتشرط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمانة أو صغر أو

جنون لعموم الخبر وعن أحمد أنه يشترط ذلك في غير الوالدين لأن من علم ذلك فيه في مظنة التكسب فكان في مظنة الغنى ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبهما إذا كانا موسرين لأنهما من الحقوق المالية فتجب عليهما كأرش جنايتهما

فصل

ومن كان له أب لم تجب نفقته على غيره لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا الأمهات أجرة الرضاع بقوله ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ وقوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ ما يكفي ولدها من مال أبيهم فإن لم يكن لهم أب ولم يكن له إلا وارث واحد فالنفقة عليه وإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كان له جدة وأخ فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ وإن كان له أخوان أو أختان فالنفقة عليهما نصفين وإن كان له أخ وأخت فالنفقة عليهما أثلاثا وإن كان له أخت وأم فعلى الاخت ثلاثة أخماس النفقة وعلى الأم الخمسان لأنه مال يستحق بالقرابة فكان على ما ذكرناه كالميراث وإن كان له من الورثة ثلاثة أو اكثر

فنفقته عليهم على قدر إرثهم لما ذكرنا وإن اجتمع أم أم وأبو أم فالنفقة على أم الأم لأنها الوارثة

فصل

ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به كعم معسر وابن عم موسر وأخ فقير وابن أخ موسر فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي وأبو الخطاب لأن علة الوجوب الإرث فيسقط بحجبه كما يسقط ميراثه وإن كانا من عمودي النسب كأب معسر وجد موسر فالنفقة على الجد لأن وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجب ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلها لأن الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لانفس الميراث وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه

فصل

ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة بدأ بالأقرب فالأقرب لأنه أولى فإذا كان له أب وجد فالنفقة للأب وإن كان له ابن وابن ابن فهي للابن وإن اجتمع أب وابن صغير أو زمن فالنفقة للابن لأن نفقته وجبت بالنص وإن كان كبيرا ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقدم الابن كذلك والثاني يقدم الأب لأن حرمته آكد والثالث هما سواء لتساويهما في القرب لأن كل واحد يدلي بنفسه وإن اجتمع أبوان ففيهما [ج ٣ - ص ٣٧٧]

ثلاثة أوجه أحدها هما سواء لتساويهما في القرابة والثاني الأم أ حق لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك والثالث الأب لأنه ساواها في القرابة وهي الولادة وانفرد بالتعصيب وإن اجتمع أخ وجد احتمل أن يقدم الجد لأنه آكد حرمة وقرابته قرابة ولادة ولهذا لا يقاد به ويحتمل تساويهما لتساويهما في التعصيب والإرث وإن كان مع الجد عم أو ابن عم قدم الجد لتقديمه في الحرمة والإرث ولأنهما يدليان به فقدم عليهما كالأب مع الاخ

فصل

وعلى المعتق نفقة عتيقه إذا وجدت الشروط لأنه وارثه ولا نفقة للمعتق على عتيقه لأنه لا يرثه

فصل

وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية لأنها تجب للحاجة فيجب ما تندفع به وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته لأنه من تمام الكفاية وعنه لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب لأن الواجب نفقته لا نفقة غيره [ج ٣ - ص ٣٧٨]

فصل

ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة وهو مخير بين أن يزوجه حرة أو بسريه بأمة ولا يجوز أن يزوجه أمة لأنه بوجوب إعفافه يستغني عن الأمة ونكاحها ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة لأن القصد الاستمتاع ولا يحصل ذلك بهما وإن أعفه بزوجة فطلقها أو بأمة فأعتقها لم يلزمه إعفافه ثانيا لأنه ضيع على نفسه وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعها لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه فلم يملك استرجاعها كالزكاة ويجيء على قول أصحابنا أن يلزمه إعفاف كل من لزمه نفقته لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة

فصل

وإن احتاج الطفل إلى الرضاع لزم إرضاعه لأن الرضاع في حق الصغير كنفقة الكبير ولا يجب إلا في حولين لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فإن امتنعت الأم من رضاعه لم تجبر سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة لقوله تعالى ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ﴾ ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب فلا تجبر على الرضاع إلا أن يضطر [ج ٣ - ص ٣٧٩]

إليها ويخشى عليه فيلزمها إرضاعه كما لو لم يكن له أحد غيرها ومتى بذلت الأم إرضاعه متبرعة أو بأجرة مثلها فهي أحق به سواء وجد الأب متبرعة برضاعه أو لم يجد لقوله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ إلى قوله ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ وقوله تعالى ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ ولأنها أحق بحضانته فوجب تقديمها وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها لم يلزمه ذلك ويسقط حقها لأنها أسقطته بإسقاطها ولأن مالا يوجد بثمن المثل كالمعدوم مثل الرقبة في الكفارة وإن كانت ذات زوج أجنبي من الطفل فمنعها زوجها الرضاع سقط حقها وإن أذن لها فهي على حقها من ذلك

فصل

وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء أحدها أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل لقوله تعالى ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ الثاني أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا ونفقة القريب لا تجب لما مضى لأنها وجبت لإحياء النفس ودفع الحاجة وقد حصل ذلك في الماضي بدونها الثالث إذا دفع إلى الزوجة نفقة [ج ٣ - ص ٣٨٠]

يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية والقريب بخلاف ذلك والرابع أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه عوضه والقريب بخلافه لما ذكرنا

2 باب الحضانة 2

إذا اقترن الزوجان وبينهما طفل أو مجنون وجبت حضانته لأنه إن ترك ضاع وهلك فيجب إحياؤه وأحق الناس بالحضانة الأم لأن أبا بكر الصديق قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك رواه سعيد واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا ولأن الأم أقرب وأشفق ولا يشاركها في قربها إلا الأب وليس له شفقتها ولا يلي الحضانة بنفسه فإن عدمت الأم أو لم تكن من أهل الحضانة فأحقهم بها أمهاتها الأقرب فالاقرب لأنهن أمهات ولا يشاركهن إلا أمهات الاب وهن أضعف منهن ميراثا ثم الأب لأنه أحد الأبوين ثم أمهاته وإن علون ثم الجد ثم أمهاته وعنه أن أمهات الأب أولى من أمهات الأم لأنهن يدلين بعصبة فعلى هذا يكون الأب بعد الأم ثم أمهاته ثم أمهات الأم وعنه أن الخالة والاخت من الأم [ج ٣ - ص ٣٨١]

أحق من الأب لقوله عليه السلام الخالة أم فعلى هذا الأخت من الابوين أحق منه ومنهما لأنها أدلت بالام وزادت بقرابة الأب والأول المشهور في المذهب فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت إلى الأخت من الأبوين ويحتمل أن ينتقل إلى الأخ لانه عصبة والأول أولى لأنها امرأة فتقدم على من في درجتها من الذكور كالأم والجدة ولأنها تلي الحضانه بنفسها ثم الأخت من الأب لأنها تقوم مقام الأخت من الأبوين وترث ميراثها ثم الأخت من الأم لأنها ركضت معه في الرحم ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم بنوهم كذلك فإذا انقرض الأخوة والأخوات فالحضانة للخالات ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات لأنهن يدلين بعصبة فقدمن كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم والأولى أولى لأنهن استوين في عدم الميراث فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات ولأن الخاله أم ثم العمات وتقدم التي من الأبوين ثم التي من الأب ثم التي من الأم ثم الأعمام ثم بنوهم

فصل

وللرجال من العصبات حق في الحضانة بدليل ما روي أن عليا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة فقال علي بنت عمي وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بنت أخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى [ج ٣ - ص ٣٨٢]

بين زيد وحمزة وقال جعفر بنت عمي وعندي خالتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة أم وسلمها إلى جعفر رواه أبو داود إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية لأنه ليس بمحرم لها فلا تسلم إليه وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم و وأب الأم والعم من الام فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة لأنهم لا يحضنون بأنفسهم وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء لأنه إذا لم يثبت لهم حضانة فمن أدلى بهم أولى فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تنتقل إليهم لأنهم يرثون عند عدم الوارث فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى الحاكم لما ذكرنا أولا

فصل

ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة المولى ولا المعتوه لعجزه عنها ولا الفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته ولا لكافر على مسلم كذلك ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبيا من الطفل لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت

أحق به ما لم تنكحي رواه أبو داود ولأنها تشتغل عن الحضانة بالاستمتاع وقد روى منها عن أحمد إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له فالجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين لأن رسول صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها إلى سبع وهي مزوجة والأول المذهب وإنما تركت بنت حمزة عند خالتها لأن زوجها من أهل الحضانة وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا فمع اجتماعهما أولى ومتى زالت الموانع منهم مثل أن طلقت المرأة المزوجة أو عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع

فصل

ومن ثبتت له الحضانة فتركها سقط حقه منها وهل يسقط حق من يدلي به على وجهين أحدهما يسقط لأنه فرع عليه فإذا سقط الاصل سقط التبع والثاني لا يسقط لأن حق القريب سقط لمعنى اختص به فاختص السقوط به كما لو سقط لمانع فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة فهي لأمها وعلى الأول تنتقل إلى الأب وإذا استوى اثنان من أهل [ج ٣ - ص ٣٨٤]

الحضانة كالأختين والعمتين أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قدم لأنهما استويا من غير ترجيح فقدم أحدهما بالقرعة كالعبدين في العتق والزوجتين في السفر بإحداهما

فصل

وإذا بلغ الغلام سبعا وهو غير معتوه خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد وروى أبو داود بإسناده عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يريد زوجي أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به فإن لم يختر واحدا منهما أو اختارهما معا قدم أحدهما بالقرعة لأنهما تساويا وتعذر الجمع فصرنا إلى القرعة وإن اختار الأم أو صار لها بالقرعة كان عندها ليلا ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب أو صناعة لأن القصد حظ الولد وحظه فيما ذكرنا وإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضه لأنه صار كالصغيرة في حاجته إلى من يقوم بأمره وإن مرض أحد الأبوين وهو عند الآخر لم يمنع من عيادته وحضوره عنده لما ذكرنا وإن [ج ٣ - ص ٣٨٥]

اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر سلم إليه ثم إن اختار الأول رد إليه لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون وقت فأتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب وإن لم يكن له أب خير بين أمه وعصبته لما روى عامر بن عبد الله قال خاصم عمي أمي وأراد أن يأخذني فاختصما إلى علي رضي الله عنه فخيرني على ثلاث مرات فاخترت أمي فدفعني إليها

فصل

وإذا بلغت الجارية سبعا تركت عند الأب بلا تخيير لأن حظها في الكون عند أبيها لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى به ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها وتكون عنده ليلا ونهارا لأن تأديبها وتخريجها في البيت ولا تمنع الأم من زيارتها من غير أن يخلو بها الزوج ولا تطيل ولا تتبسط لأن الفرقة بين الزوجين تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيتها لما ذكرناه في الغلام وإن مرضت الأم لم تمنع الجارية من عيادتها لما ذكرنا

فصل

وإن كان الولد بالغا رشيدا فلا حضانة عليه والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما وإن أراد الانفراد وهو رجل فله ذلك لأنه مستغن

[ج ٣ - ص ٣٨٦]

عن الحضانة ويتسحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره لهما لقوله تعالى ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ وإن كانت جارية فلأبيها منعها من الانفراد لأنه لا يأمن عليها دخول المفسدين

فصل

وإن أراد أحد أبوي الطفل السفر والآخر الإقامة والطريق أو البلد الذي يسافر إليه مخوف أو كان السفر لحاجة ثم يعود فالمقيم أحق بالولد لأن في السفر ضررا وفي تكليفه السفر مع العود إتعاب له ومشقة عليه وإن كان السفر لنقلة إلى بلد آمن بعيد في طريق آمن فالأب أحق بالولد لأن كونه مع أبيه أحفظ لنسبه وأحوط عليه وأبلغ في تأديبه وتخريجه وإن انتقلا جميعا فالأم على حقها من الحضانة وإن كانت النقلة إلى مكان قريب بحيث يمكن الأب رؤيتهم كل يوم فالأم على حضانتها لأن مراعاة الأب له ممكنة وإن كان أبعد من ذلك فظاهر كلام أحمد انقطاع حق أمه من الحضانة لعجز الأب عن مراعاة ولده فهو كالسفر البعيد وقال القاضي إن كان دون مسافة القصر فالأم على حضانتها لأنه في حكم القريب

2 باب نفقة المماليك 2

ويجب على الرجل نفقة مملوكه مما لا غنى له عنه وكسوته لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق متفق عليه وتجب نفقته من قوت بلده لأنه المتعارف ويستحق أن يطعمه مما يأكل ويكسوه مما يلبس لما روى أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه متفق عليه وإن ولي طعامه استحب له أن يطعمه منه لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه متفق عليه وهو مخير بين أن يجعل نفقته في كسبه وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته لأن الكل خدمته فإن جعل نفقته في كسبه وكان وفق الكسب فحسن وإن كان في الكسب فضل فهو لسيده وإن كان فيه عوز فعلى سيده تمامه ويستحب التسوية بين عبيده وإمائه في النفقة والكسوة ويجوز له التفضيل وإن كان في بعض إمائه من يعدها للتسري فلا بأس بزيادتها في الكسوة لأن ذلك هو العادة [ج ٣ - ص ٣٨٨]

فصل

وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب ذلك وإن طلبت الأمة التزويج وكان يستمتع بها لم يجبر على تزويجها لأنه يكفيها وعليه في تزويجها ضرر وإن لم يستمتع بها لزمه إجابتها أو بيعها وإن كان لعبده زوجة مكنه من الاستمتاع بها ليلا لأن إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع

فصل

ولا يجوز أن يكلفه من العمل ما يغلبه أو يشق عليه للخبر وإن سافر به أركبه عقبه ولا يجبر العبد على المخارجة لأنه معاوضة فلم يجبر عليها كالكتابة وإن طلب العبد ذلك لم يجبر عليه المولى كذلك وإن اتفقا عليها وله كسب جاز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يخففوا عنه من خراجه وإن لم يكن له كسب لم يجز لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة حل فلم يجز وإن مرض العبد أو الأمة أو زمنا أو عميا لزمه نفقتهما لأن نفقتهما بالملك وهو موجود [ج ٣ - ص ٣٨٩]

فصل

وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه لأن فيه إضرار بولدها واللبن مخلوق له فوجب أن يقدم فيه على غيره

فصل

ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ولا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق لأنه إضرار بها فمنع منه كترك الإنفاق ولا يحلب منها إلا ما فضل عن ولدها لأنها غذاء للولد فلم يملك منعه منه فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على بيعها فإن أبى أكتريت وأنفق عليها فإن أمكن وإلا بيعت كما يزال ملكه عن زوجته إذا أعسر بنفقتها